

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН

1



Ниш, 2014. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН

Бр. 1



Ниш, 2014. године

БИЛТЕН

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Драган Јоцић,
председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА:

Слађана Ђуричковић,
судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКЕ ГРУПЕ

За кривично право: судија Снежана Милошевић - руководица групе
судија Мирјана Ђорђевић - члан

За грађанско право: судија Слађана Ђуричковић - руководица групе
судија Мирослава Миловановић - члан
судија Ивана Рађеновић - члан

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Златица Петровић, судијски помоћник

ШТАМПАРИЈА: "DIS Public", Београд

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34

БИЛТЕН Апелационог суда у Нишу / главни и
одговорни уредник Новица Стефановић. - бр. 1, 2013-
.. - Београд (Булевар војводе Мишића 37/II) : Intermex,
2013- (Београд : "DIS Public"). - 22 cm

Три пута годишње. - Је наставак: Билтен судске
праксе - Окружни суд у Нишу = ISSN 1452-6603
ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу -
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног закона).

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

С А Д Р Ж А Ј

НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ПРЕМА НОВОЈ ПРАВОСУДНОЈ МРЕЖИ	5
---	----------

РАСПОРЕД ПОСЛОВА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2014. ГОДИНУ	7
---	----------

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Др Дијана Јанковић

Кривична дела против имовине након измена и допуна Кривичног законика	17
--	----

ПРАВНА СХВАТАЊА усвојена на заједничким седницама свих апелационих судова	43
--	-----------

ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА ОСНОВНИХ СУДОВА	69
--	-----------

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО	93
Кривично материјално право	95
Кривично процесно право	107
ГРАЂАНСКО ПРАВО	141
Процесно право	143
Радни спорови	153

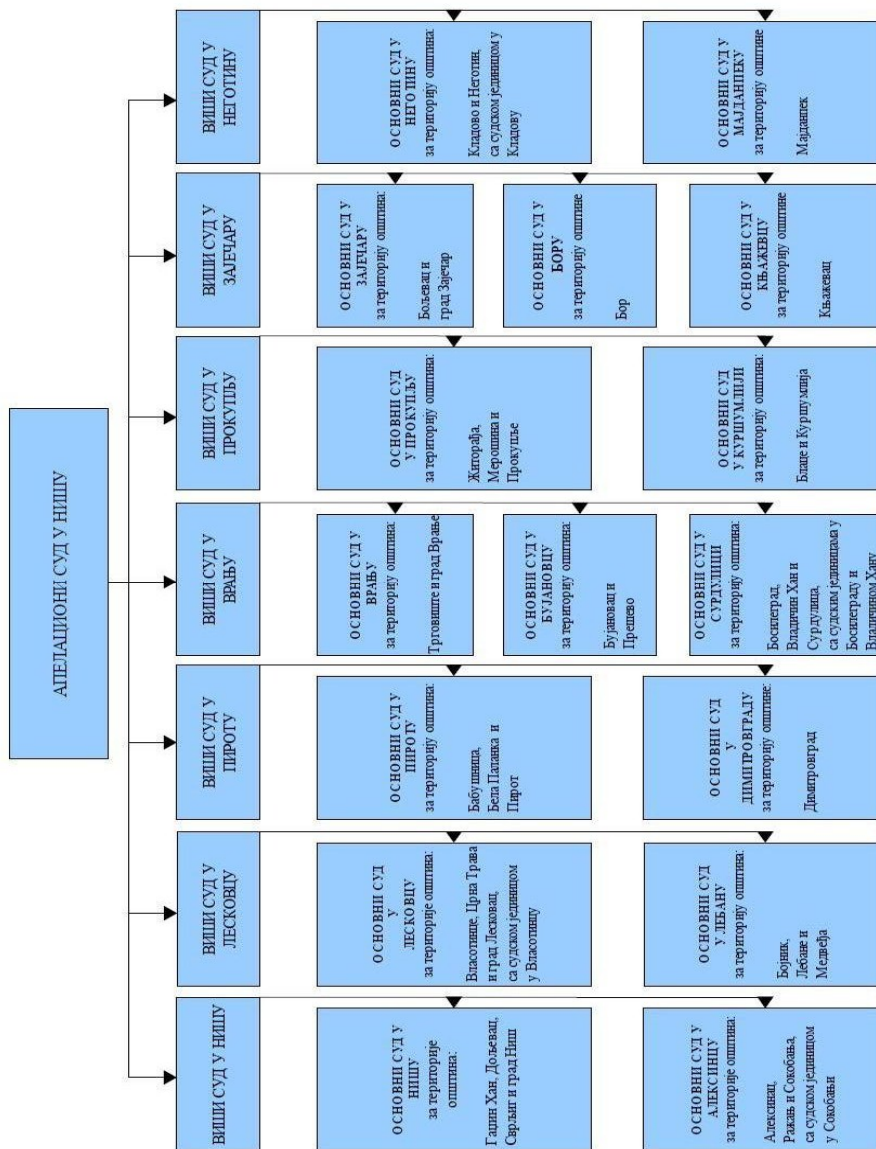
НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ПРЕМА НОВОЈ ПРАВОСУДНОЈ МРЕЖИ

Формирањем нове правосудне мреже, 1. јануара 2014. године, надлежност Апелационог суда у Нишу је измењена у одређеном делу.

Апелациони суд у Нишу је надлежан:

1. да одлучује о жалбама на одлуке виших судова;
2. да одлучује о жалбама на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (виши суд у другом степену је надлежан да одлучује о жалбама на одлуке основних судова о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног, за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година);
3. да одлучује о жалбама на пресуде основних судова у грађанско-правним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (виши суд у другом степену је надлежан да одлучује о жалбама на следеће одлуке основних судова: на решења у грађанскоправним споровима, пресуде у споровима мале вредности и ванпарничним поступцима);
4. да одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд;
5. да одлучује о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари;
6. да врши друге послове одређене законом.

Од 1.1.2014. године Апелациони суд у Нишу надлежан је и за подручје виших судова у Неготину и Зајечару.





Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
СУ I-2-11/13
12.12.2013. године
Н и ш

РАСПОРЕД ПОСЛОВА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и члана 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија и судијских помоћника Апелационог суда у Нишу за 2014. годину.

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи Драган Јоцић председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије Снежана Милошевић и Слађана Ђуричковић.

Председника суда замењиваће судија Снежана Милошевић, којој се поверавају и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се Биљана Мистрић виши судијски помоћник.

II**СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА**

За председнике судских одељења одређују се и то:

7. У Одељењу судске праксе: председник Драган Јоцић, заменици судија Вера Милошевић, Мирослава Миловановић и судија Ивана Рађеновић.

8. У Кривичном одељењу: председник, судија Братислав Крстић, а заменик Зоран Поповић.

9. У Грађанском одељењу: председник, судија Слађана Ђуричковић, заменик судија Миомир Митровић.

У Одељењу радних спорова: председник судија Ивана Рађеновић, заменик судија Зоран Ђорђевић.

Главни и одговорни уредник билтена судске праксе је Председник суда Драган Јоцић, а заменик главног и одговорног уредника судија Братислав Крстић.

III**КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ****I – ВЕЋЕ**

1. Вера Милошевић, председник већа,
2. Љиљана Миљковић, члан,
3. Слободан Љубић, члан

Судијски помоћници:

- Ивана Лазовић, Миљана Радовановић и Додић Јелена

II – ВЕЋЕ

1. Братислав Крстић, председник већа,
2. Весна Стевановић, члан
3. Иван Булатовић, члан

Судијски помоћници:

- Зоран Ђурђевић и Марија Димитријевић

III – ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа,
2. Љубомир Јовановић, члан
3. Дијана Јанковић, члан

Судијски помоћници:

- Милош Увалин и Марија Петровић

IV – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа,
2. Слободан Стојилковић, члан
3. Јасмина Јововић, члан

Судијски помоћници:

- Иван Калезић, Ивана Милошевић

V – ВЕЋЕ

1. Горана Митић, председник већа,
2. Гордана Павловић, члан,
3. Ранко Банковић, члан

Судијски помоћници:

- Слађана Лендра, Ана Јовичић и Милан Ђорђевић

VI – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа,
2. Драгана Живадиновић члан,
3. Саша Бошковић члан

Судијски помоћници:

- Милица Алексић и Миодраг Перуновић

Одређује се и посебно веће за поступање искључиво у старим предметима

1. Драган Јоцић, председник већа,
2. Братислав Крстић, члан
3. Снежана Милошевић, члан,

с тим што ће члана овог већа чинити и судија који реферише старе предмете. Ово веће се не задужује новим предметима.

За поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица одређују се II веће и IV.

За предмете у којима већа поступају у петорном саставу веће које је задужено предметима ће се допунити члановима првог наредног већа, до потребног броја.

Већа за одлучивање у трећем степену предметима се задужују према овом распореду послова, с тим да исто веће не задужује два узастопна предмета, већ се наредним предметом задужује наредно веће.

Председника већа замењује први члан већа.

Дежурна већа за време годишњих одмора у кривичном одељењу су у

- јулу месецу V веће,
- у августу VI веће.

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Слађана Ђуричковић, председник већа,
2. Љиљана Јовановић, члан,
3. Миомир Митровић, члан

Судијски помоћници:

- Бети Лазаревић и Сандра Стефановић

II – ВЕЋЕ

1. Мирослава Миловановић, председник већа,
2. Данијела Николић, члан,
3. Слободанка Китановић, члан

Судијски помоћници:

- Милена Симоновић, Миљана Поповић Ђурић и Мирјана Милутиновић

Судије I и II већа примаће и предмете у вези породичних и статусних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

III – ВЕЋЕ

1. Миодраг Марјановић, председник већа,
2. Александар Пантић, члан,
3. Јасмина Андрејевић, члан

Судијски помоћници:

- Јелена Јанчетовић, Јелена Увалин и Горан Драгоман

IV – ВЕЋЕ

1. Марина Милановић председник већа,
2. Сузана Ђурић, члан

Судијски помоћници:

- Јелена Божиловић и Јелена Голубовић

Председника већа замењује први члан већа.

V**ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА****V – ВЕЋЕ**

1. Зоран Ђорђевић, председник већа
2. Весна Вукас, члан
3. Вера Милошевић, члан

Судијски помоћници:

- Драгана Вељковић и Весна Јовановић-Јанковић

VI – ВЕЋЕ

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Ружица Јовановић, члан
3. Зорица Цветковић, члан

Судијски помоћници:

- Ивана Ђурђић Митровић и Јелена Станковић

VII – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа,
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Слађана Стојановић, члан

Судијски помоћници:

- Слађана Љубеновић и Наташа Митковић

VIII – ВЕЋЕ

1. Милица Манић, председник већа,
2. Тања Ристић, члан

Судијски помоћници:

- Слађанка Тасић,

Председника већа замењује први члан већа.

Va**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ**

За одлучивање о првостепеној заштити права на суђење у разумном року, одређују се све судије Апелационог суда у Нишу, изузев председника суда, које ће се задуживати предметима из оне области у којој поступају према важећем Годишњем распореду послова у Апелационом суду у Нишу за 2014. годину.

Ова допуна годишњег распоредa послова ступа на снагу 21.05.2014. године, од дана примене чл. 8а Закона о уређењу судова.

VI**ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ**

Одељење судске праксе чине судије:

1. Драган Јоцић, председник суда,
2. Снежана Милошевић, Заменик председника суда ,
3. Слађана Ђуричковић, председник Грађанског одељења,
4. Ивана Рађеновић, преседник Одељења радних спорова,
5. Вера Милошевић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу,
6. Мирослава Миловановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу,

Судијски помоћник Горан Димитријевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Милан Ђорђевић,

Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мења судијски помоћник Јелена Станковић.

VII

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно судија и судијских помоћника.

Овај распоред је саопштен на седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 16.12.2013. године.

Судије имају право приговора председнику Врховног касационог суда у Београду у року од три дана од дана саопштавања на седници свих судија.

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Драган Јоцић

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Др Дијана Јанковић,
судија Апелационог суда у Нишу

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ НАКОН ИЗМЕНА И ДОПУНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Уводне напомене

У структури криминалитета у скоро свим савременим државама, значајно место заузима имовински криминалитет. Кривична дела против имовине најчешће улазе у круг тзв. "класичних" кривичних дела и била су предмет инкриминације и у најстаријим законодавствима. Међутим, без обзира на проток времена и развој друштва, имовинска кривична дела у свом основном облику не губе на својој актуелности, те представљају и даље дела која су уско везана за социјалну структуру заједнице и модалитете друштвеног организовања, тако да у оквиру скоро истих обележја која их прате од првих кривичних кодекса до данас, проналазе нове облике и начине извршења и отварају дилеме у судској пракси.

Када је у питању домаће законодавство и судска пракса у овој кривичноправној области, може се уочити да је у нашој законској регулативи ова група кривичних дела претрпела значајне измене последњих година, почев од нових инкриминација које наше раније кривично право није познавало, преко измена битних обележја појединих кривичних дела и запрећених казни, до нових законских израза који су умногоме променили тумачење појединих облика кривичних дела. Са друге стране, у домаћој судској пракси кривична дела против имовине дела несумњиво представљају најзаступљенију и најбројнију групу кривичних дела, поводом којих се воде кривични поступци.

Проучавањем наведене теме указали бисмо, пре свега, на измене Кривичног законика у области кривичних дела против имовине, а затим и на домаћу судску праксу и закључке судова у правноснажним одлукама, у погледу спорних питања, као и на уочене проблеме који се јављају у једном делу пресуда.

Осим тога, уочена је и појава у домаћој судској пракси да казнена политика судова не прати увек казнену политику законодавца, тако да у

периоду када су за кривична дела против имовине, биле прописане строже казне, судови су претежно изрицали блаже кривичне санкције, најчешће условне осуде, а након законских измена којима су за наведена кривична дела прописане знатно блаже казне, у много већој мери се изричу затворске казне.

Кривична дела против имовине након законских измена и допуна

Ступањем на снагу снагу Закона о изменама и допунама Кривичног законика¹ септембра месеца 2009. године, као и каснијим изменама Кривичног законика закључно са изменама из 2014. године², посматрајући у целини кривична дела против имовине, а у односу на претходни Кривични законик из 2006. године³, могу се издвојити одређене карактеристике:

Прво, дошло је до прописивања строжих казни за један број кривичних дела против имовине, уз додавање за поједина дела и кумулативно прописане новчане казне.

Друго, извршено је проширење групе кривичних дела против имовине и то како законским прописивањем нових кривичних дела, тако и додавањем нових квалификованих облика дела, већ раније прописаним.

Треће, уведени су нови законски изрази у квалификоване облике појединих кривичних дела против имовине.

Пооштравање прописаних казни за кривична дела против имовине

Посматрајући законске измене и допуне које су пратиле домаће кривично право у последњих десет година у погледу кривичних дела против имовине, могу се приметити варијације, које су за један број кривичних дела против имовине (не за сва дела), почев од измена КЗ из 2006. године, ишле - од строже ка блаже прописаним казнама, а затим почев од измена и допуна КЗ из 2009. године - од блаже ка строже прописаним казнама.

¹ Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр.72/09).

² Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) - у даљем тексту КЗ.

³ Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/2005, 107/2005) - ступио је на снагу 01.01.2006. године.

Ако направимо краћи осврт на КЗ из 2006. године, може се уочити, да су његовим ступањем на снагу биле прописане знатно блаже казне за поједина кривична дела против имовине у односу на казне које су биле прописане претходним кривичним законом, тако да је у том периоду дошло и до промене стварне надлежности у поступању судова, управо у односу на један број кривичних дела против имовине.

На пример, када су питању кривична дела крађа (чл. 203. КЗ) и тешка крађа (чл. 204. КЗ), као најзаступљенија кривична дела против имовине у судским поступцима, КЗ из 2006. године, је знатно смањио висину раније прописаних казни за наведена дела (тј. прописао је знатно блаже казне у односу на претходни закон)⁴, при чему је за кривично дело крађа увео и могућност изрицања новчане казне (која је неспорно блажа врста казне у односу на казну затвора), тиме што није одредио доњи посебни законски минимум.

Наведене измене КЗ из 2006. године, су утицале значајно и на кривични поступак, јер су довеле до тога, да је нпр. у случају кривичног дела крађа (чл. 203. КЗ) кривични поступак почео да се води по правилима за скарањени поступак.

У случају кривичног дела тешка крађа (чл. 204. КЗ), поменута измена закона, је утицала, на промену стварне надлежности, тако што је надлежност за поступање, прешла са судова више надлежности, тада Окружних судова, на судове ниже надлежности, тада Општинских судова.

⁴ Кривични закон Републике Србије („Службени гласник СРС“, бр.26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90, „Службени гласник РС“, бр.16/90, 49/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002, 11/2002, 80/2002, 39/2003, 67/2003), је за кривично дело крађа у чл. 165. прописивао казну затвора од три месеца до пет година.

За кривично дело тешка крађа из чл. 166. ст. 1. и ст. 2. КЗРС била је прописана казна затвора од једне до десет година, и најтежи облик наведеног кривичног дела, имајући у виду износ прибављене противправне имовинске користи у ст. 3. била је прописана казна затвора од најмање три године.

Кривични законик из 2006. године, је за кривично дело крађа из чл. 203. КЗ, прописао новчану казну или казну затвора до три године, а за кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. КЗ, казну затвора у трајању од једне до осам година, а за његов најтежи облик из чл. 204. ст. 3. казну затвора од две до десет година - те је јасно да је КЗ из 2006. године био знатно блажи по запрећеним казнама за наведена кривична дела у односу на претходни закон.

Међутим, изменама и допунама КЗ из 2009. године (које су највећим делом и данас на снази), су за знатан број кривичних дела против имовине, прописане строже казне, у односу на казне које су биле прописане КЗ из 2006. године, уз додавање за поједина дела и кумулативно прописаних новчаних казни.

Тако је нпр. за кривично дело превара из чл. 208. ст. 1. КЗ, према КЗ из 2006. године била прописана новчана казна или затвор до три године, а након измена КЗ из 2009. године је прописана казна затвора од шест месеци до пет година и кумулативно новчана казна.

Поред тога, за поједине квалификоване облике кривичних дела, као што су нпр. разбојничка крађа из чл. 205. ст. 4 КЗ и разбојништво из чл. 206. ст. 3 КЗ, прописане су казне затвора од најмање пет година, што их истовремено сврстава у ред најтежих кривичних дела која прописује наш Кривични законик и за која се може изрећи максимална казна затвора од двадесет година, у оквиру општег максимума, сходно одредби чл. 45. ст. 1. КЗ.

Можемо рећи, да овим изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године, усмереним у правцу прописивања строжих казни, законодавац свакако указује на већу криминалну опасност кривичних дела против имовине, али се исто тако запажа да поједина дела из ове групе кривичних дела, не само строже санкционишу, већ и допуњују, прецизирају, термилолошки и граматички појашњавају и усклађују са другим законским изворима.

Нова кривична дела у групи кривичних дела против имовине

Једна од најзначајнијих новина, коју су измене и допуне КЗ из 2009. године, као и касније измене и допуне КЗ, унеле у групу кривичних дела против имовине, су потпуно нова кривична дела, која раније домаће кривично право није познавало, а такође су поједине инкриминације проширене тако што су им додати нови квалификовани облици или уведени нови заштитни објекти.

Када су питању нова кривична дела, може се уочити да је у КЗ уведено ново кривично дело против имовине, којим се појачава кривично-правна заштита културних добара, а то је кривично дело неовлашћено изношење културног добра у иностранство из чл. 221а. КЗ. Конкретно, сам

назив кривичног дела говори о радњи извршења, односно да је за постојање дела потребно, да учинилац, без претходног одобрења надлежних органа изнесе или извезе у иностранство културно добро или добро које ужива претходну заштиту.

Значајно за наведено дело је, да се мора утврдити у сваком конкретном случају, да ли постоји потребно одобрење, за извоз или изношење у иностранство културног добра или добра које ужива претходну заштиту, што такође подразумева да би суд морао у сваком конкретном случају утврдити и да ли се ради о културном добру или добру које ужива посебну заштиту и при томе наведене појмове (културно добро или добро које ужива посебну заштиту), тумачити сходно Закону о културним добрима,⁵ односно сходно посебним прописима, актима и сл. који том добру дају такво својство. Прописан је у другом ставу истог члана (чл. 221а. ст. 2. КЗ) и квалификовани облик наведеног кривичног дела, који се односи на "културно добро од изузетног или великог значаја", што би такође значило да наведена чињеница мора бити посебно утврђена, и то на основу одговарајућег прописа или акта државног органа.

Поред тога прописана су и два кривична дела, која су раније била предвиђена казним одредбама Закона о планирању и изградњи⁶: кривично дело грађење без грађевинске дозволе из чл. 219а. КЗ и кривично дело прикључење објекта који је изграђен без грађевинске дозволе из чл. 219б. КЗ.

Карактеристично за поменута дела је, да иста поред тога што нису била раније прописана Кривичним закоником, представљају потпуно спе-

⁵ Појам културног или природног добра треба утврђивати према одговарајућим прописима. Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену прописима о заштити културног добра. Културна добра, у зависности од свог значаја, разврставају се у категорије: културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја. Ствари и творевине за које се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју, представљају добра која уживају претходну заштиту и заштићена су у складу с одредбама Закона о културним добрима. Заштићеним природним добром сматра се добро које по прописима о заштити природних добара ужива претходну заштиту. Видети: Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.7/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закони“).

⁶ Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС“).

цифичне инкриминације у овој групи кривичних дела, јер одступају од "класичног" концепта "прибављања имовинске користи", које карактерише и преставаља битно обележје већине имовинских кривичних дела.

Дакле, ради се о потпуно новом концепту инкриминације имовинских кривичних дела, која у оквиру групе кривичних дела против имовине, представљају једну специфичну и другачију категорију, у односу на остала кривична дела из ове групе.

Када се ради о тзв. "класичним" имовинским кривичним делима, такође је прописано једно сасвим ново кривично дело, а то је кривично дело превара у осигурању из чл. 208а. КЗ. Наведеном инкриминацијом су у првом ставу (208а. ст. 1. КЗ), прописана битна обележја за основни облик дела⁷, при чему је другим ставом (чл. 208а. ст. 2. КЗ) прописан и лакши облик дела, уколико је дело учињено само у намери да се други оштети, а у трећем и четвртном ставу (чл. 208а ст. 3. и ст. 4. КЗ) и два квалификована облика дела, градацијски по тежини дела, у зависности од висине прибављене имовинске користи или нанете штете.

Из самог законског текста наведене икриминације произилази да кривично дело превара у осигурању из чл. 208а. КЗ, представља специјални облик кривичног дела превара из чл. 208. КЗ,⁸ те да се приликом утврђивања постојања кривичног дела превара у осигурању из чл. 208а. КЗ, полази од истих чињеница као код кривичног дела превара из чл. 208. КЗ, посебно када су у питању субјективни елементи дела, с тим што се у случају кривичног дела превара у осигурању из чл. 208а. КЗ, морају утврдити и посебни елементи дела, односно мора се у сваком конкретном случају утврдити да ли је извршена и нека од алтернативно прописаних радњи (лажно приказивање или прикривање чињеница, давање лажних мишљења и извештаја, давање лажне

⁷ „Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница, давањем лажних мишљења и извештаја, давањем лажне процене, подношењем неистините документације или га на други начин доведе у заблуду или га одржава у заблуди, а у вези са осигурањем и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, казниће се затвором од шест месеци до пет година или новчаном казном“, (чл. 208а. ст. 1.КЗ).

⁸ Између кривичних дела превара из чл. 208а. КЗ и кривичног дела превара у осигурању из чл. 208а. КЗ, уколико има елемента оба дела, поводом истог учиниоца и истог догађаја, увек ће постојати привидни идеални стицај, по основу специјалитета, те иако има свих елемената оба дела, увек ће постојати само кривично дело превара у осигурању из чл. 208а. КЗ.

процене, подношење неистините документације или на други начин), као и да ли је нека од инкриминисаних радњи предузета у вези са осигурањем, а што све чини посебна обележје тог дела.

Уочава се, да је додата нова инкриминација и кривичном делу прикривање из чл. 221.КЗ. Прописано је у трећем ставу наведеног кривичног дела (чл. 221. ст. 3.КЗ), да кривично дело врши и онај учинилац који у "намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, захтева накнаду за повраћај ствари за које зна или је могао или био дужан да зна да су прибављене кривичним делом, уколико нису остварена обележја неког другог тежег дела". На овај начин обухваћена је широка зона могућег деловања учиниоца конкретног кривичног дела, а која је у савременим животним околностима доста распрострањена.

Кривичноправна заштита културних и других добара је проширена и додатим инкриминацијама кривичним делима тешка крађа (чл. 204. ст. 3. КЗ) и утаја (чл. 207. ст. 4.), тако што је квалификованим облицима наведених кривичних дела иза речи "културно добро" додато и "односно добро које ужива претходну заштиту или природно добро".

Поред тога, кривичном делу тешка крађа (чл. 204. ст. 3. КЗ), истим ставом, је додато "или украдена ствар представља јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја, делове тих уређаја".

На поменути начин је код наведених кривичних дела, посебни заштитни објект у једном делу прецизније одређен, а другом проширен, иако би се наведени појмови, као и у случају кривичног дела неовлашћено изношење културног добра у иностранство из чл. 221а. КЗ, морали тумачити у складу са одредбама посебних закона (нпр. Закон о културним добрима и др), односно у складу са одредбама посебних закона и акта, који ближе дефинишу и описују наведене предмете извршења.

Законодавац је проширио и заштитни објект кривичног дела тешка крађа чл. 204. КЗ, на "станове собе, касе и ормане" (чл. 204. ст. 1. тач. 1. КЗ), а проширен је и начин извршења дела, тако да је наведени став допуњен речима "савлађивањем механичких, електронских или других" већих препрека. Међутим, прописане казне за кривично дело прикривање (чл. 221. КЗ) и тешка крађа (чл. 204. КЗ) у погледу посебног законског минимума и максимума су остале неизмењене.

Увођење нових инкриминација односно нових кривичних дела у Кривични законик, свакако представља једну од најзначајнијих новина које се уведене у домаће кривично право изменама и допунама КЗ из 2009. године, и каснијим изменама. Са аспекта кривичних дела против имовине, уочава се, да је законодавац у појединим већ постојећим кривичним делима детаљније регулисао одређена противправна понашања, затим у неким кривичним делима проширио заштитни објекат и што је најважније прописоа и потпуно нова кривична дела, при чему сматрамо значајним што су поједине инкриминације које су биле садржане у неким другим посебним ванкривичним законима (нпр. у Закону о планирању и изградњи) уведене у Кривични законик, јер то преставља пут концентрисања свих кривичних дела у једном Кривичном закону, који је већ започет и на овај начин се наставља.

Нови законски изрази "група" и "организована криминална група" у квалификованим облицима кривичних дела против имовине

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године, дошло до веома битне измене у одређивању појмова и законских израза код квалификованих облика кривичних дела против имовине.

У законским одредбама кривичног дела разбојништво из чл. 205. ст. 4. КЗ и кривичног дела разбојничка крађа из чл. 206. ст. 3 КЗ, законски израз "више лица" замењен је законским изразом "група". Осим тога, може се приметити да је извршено и усаглашавање постојећих законских решења, са новим законским одредбама, те је за кривично дело прикривање из чл. 221. ст. 4. КЗ ранији законски израз "ако је дело извршено од стране организоване групе" замењен поменути новим изразом "групе".

Такође је наведеним изменама и допунама КЗ из 2009. године, дошло до измене и у делу "значење израза", те је измењен и чл. 112. ст. 22 КЗ и по законским изменама из 2009. године, група представља: "најмање три лица повезаних ради трајног или повременог вршења кривичних дела, која не мора да има дефинисане улоге својих чланова, континуитет чланства или развијену структуру".

Наведена измена представља веома значајну измену у односу на ранију законску одредбу (која је била предвиђена КЗ из 2006. године) чл. 112. ст. 22. КЗ која се односила на значење израза "организована група", а

који законски израз је изменама и допунама КЗ из 2009. године, практично изостављен из законског текста.

Поред тога, наведеним законским изменама се прописује још један нови законски израз "организована криминална група", којим су квалификовани најтежи облици имовинских кривичних дела, тешка крађа из чл. 204. ст. 4. КЗ, разбојништво из чл. 205. ст. 4. КЗ, разбојничка крађа из чл. 206. ст. 3 КЗ, изнуда из 214. ст. 5. КЗ, уцена из чл. 215. ст. 5. КЗ. При томе законски израз "организована криминална група" има потпуно другачије значење од ранијег законског израза "организована група" који је био предвиђен у чл. 112. тач. 22. КЗ из 2006. године.

Дефинисање "организоване криминалне групе" дато је у одредби чл. 112. тач. 35. КЗ којом је предвиђено да је "организована криминална група, група од три или више лица, која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела за која је прописана казна затвора од четири године или тежа казна, ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи или ради остваривања и задржавања утицаја на привредне или друге важне структуре".

Такође је значајно, да је идентичан израз "организована криминална група" прописан и одредбом чл. 2. тач.33. Законика о кривичном поступку⁹ као и чл. 3. ст. 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела¹⁰, те је практично извршено усклађивање одредбе чл. 112. ст. 35 КЗ, којом је дефинисан појам "организоване криминалне групе" са значењем наведеног законског израза из поменутих закона.

Може се закључити, да се код наведених квалификованих облика кривичних дела против имовине, јављају два потпуно нова законска израза, а то су "група" и "организована криминална група", при чему је "група" дефинисана само одредбама материјалног права, а "организована криминална група" одредбама како материјалног тако и процесног права и

⁹ Законик о кривичном поступку, „Службени гласник РС“, бр.72/2011, 10/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014), у тексту означен са ЗКП.

¹⁰ Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр.42/02, 27/03, 39/2003, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05, 61/05, 72/09, 72/2011-др.закон, 101/2011-др.закон и 32/2013).

ради се о сасвим новим дефиницијама облика криминалног удруживања у односу на раније законске одредбе.

Пре законских измена КЗ из 2009. године, као квалификаторну околност у случају криминалног удруживања, закон је прописивао да је дело учињено од стране "више лица", која су се удружила ради вршења кривичних дела.

Ранији коментари Кривичног законика указивали су на то, да постојање ових квалификованих облика кривичних дела претпоставља, да су у "извршењу дела учествовала најмање два или више лица која су се удружила за вршење ових кривичних дела, што практично значи претходни ранији договор".¹¹

Међутим, ранији законски израз "више лица" и нови законски изрази "група" и "организована криминална група", иако блиски, нису идентични и највише дилема у судској пракси изазвало је управо тумачење појма "групе" из чл. 112. ст. 22. КЗ из 2009. године. Такође, законским одредбама КЗ из 2009. године, у сам појам групе из чл. 112. ст. 22. није децидирано наведено "удруживање" нити "претходни договор", већ се наводи да је потребно да су лица повезана ради трајног или повременог вршења кривичног дела.

У том правцу се отворило питање утврђења, да ли у појединим конкретним случајевима "постоји повезаност лица ради вршења кривичних дела", у субјективном и објективном смислу и на основу којих доказа утврдити да је та повезаност била ради трајног или повременог вршења кривичног дела. Посебно је постојала у судској пракси велика разноликост у изрекама пресуда, односно у описима дела која су учињена од стране "групе" и то као у погледу објективних радњи које су навођене тако и у погледу субјективних елемената дела.

У судској пракси и кривичноправној литератури могу се, наравно наћи, тумачења сличних и блиских законских израза, међутим наведеним појмовима се ипак више у ранијем периоду бавила теорија кривичног права и поменути законски изрази и појмови који означавају различите облике криминалног удруживања нису имали своју законску дефиницију и одређење које им је дато законским изменама из 2009. године.

¹¹ Лазаревић, Љ., *Коментар кривичног законика Републике Србије*, Савремена администрација, Београд 2006, стр.653.

Значајно је и то да се, дефиниција групе у смислу чл. 112. ст. 22. КЗ умногоме разликује од дефиниције "организоване криминалне групе" из чл. 112. ст. 35 КЗ, која је детаљније законски одређена. Поред тога, има далеко више судске праксе која се бави проблемом "организоване криминалне групе" у односу на "групу", а с друге стране група из чл. 112. ст. 22. КЗ је прописана законом у веома уопштеној дефиницији и судској пракси је дата велика ширина у тумачењу.

У вези са наведеним, може се приметити, да законско дефинисање "групе" у чл. 112. ст. 22 КЗ, створило одређене дилеме у погледу тумачења наведене одредбе, јер су се у судским одлукама сретала веома различита и неуједначена тумачења појмова "повезаности", "трајног", "повременог" и сл. Наведено је у одређеној мери и последица тога јер је долазило до недовољног разграничења ранијих законских израза "више лица", "организована група", "удруживање ради вршења кривичних дела" и др., са новим законским изразима "група" и "организована криминална група", при чему су се ранија тумачења покушавала применити на нове законске појмове, посебно на "групу", као уопштеније дефинисану, али то није доводило увек до правилних закључака, јер је група изменама и допунама КЗ из 2009. године, у многим суштинским сегментима другачије законски одређена у односу на раније блиске законске појмове.

Неке карактеристике кривичних дела против имовине

Основна карактеристика свих кривичних дела против имовине је, да је предмет кривичноправне заштите управо имовина. Међутим, домаће кривично право у дужем временском периоду није дефинисало имовину са кривичноправног аспекта, већ се у ширем смислу и у кривичном праву узимао грађанскоправни појам имовине, а који се свакако не може изједначити са кривичноправним појмом.

Значајну новину су у том смислу донеле измене и допуне КЗ из 2009. године, јер су у домаће кривично право увеле и кривичноправни појам имовине, тако што је имовина дефинисана и законски одређена одредбом чл. 112. ст. 36. КЗ.

Тако је чл. 112. ст. 36. КЗ прописано, да се "имовином сматра добро сваке врсте, материјално и нематеријално, покретно или непокретно, процењиво или непроцењиво и исправа у било ком облику којим се доказује право или интерес у односу на такво добро. Имовином се сматра и

приход или друга корист остварена, непосредно или посредно, из кривичног дела, као и добро у које је она претворена или са којим је помешана".

Имовина се такође дефинише и Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела¹², која дефиниција се након последњих законских измена Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела из 2013. године, у одређеној мери сада разликује од законске дефиниције имовине у чл. 112. ст. 36. КЗ, али ће извесно бити извршено усклађивање наведених законских одредби.

Карактеристично је за кривична дела против имовине да имају веома различите посебне заштитне објекте, и да их је веома тешко по том основу на било који начин груписати. Групни заштитни објект код кривичних дела против имовине је несумњиво имовина, међутим када се ради о конкретним заштитним објектима за појединачно посматрана дела из наведене групе, могу се уочити суштинске разлике.

На пример, када су у питању кривична дела крађа (чл. 203. КЗ), разбојништво (чл. 206. КЗ), утаја (чл. 207. КЗ), одузимање туђе ствари (чл. 211. КЗ), код ових дела је групни посебни заштитни објект конкретизован тако што је одређен као "покретна ствар".

При томе, означавање заштитног објекта као "покретна ствар", код наведених дела, није једнака заштитном објекту код кривичног дела уништење и оштећење туђе ствари (чл. 212. КЗ), где је заштитни објект означен као "ствар", што би значило да се може радити и о покретној и о непокретној ствари.

Са друге стране, када су у питању кривична дела нпр. злоупотреба поверења (чл. 216. КЗ) или оштећење туђих права (чл. 220. КЗ), ради о сасвим другачијој природи заштитног објекта у односу на претходно наведена дела иако спадају у исту групу кривичних дела.

Поред тога, напомињемо да се кривичноправно схватање покретне ствари разликује од истог схватања у грађанском праву.

Тако, извесне ствари које се у грађанском праву сматрају као непокретне, зато што служе главној - непокретној ствари или су везане за непокретне ствари (нпр. скеле, чамци, железничке шине итд) у кривично-

¹² Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС“, бр.32/2013).

правном смислу се сматрају за покретне. При томе, у кривичноправном смислу, као покретна ствар се сматра свака она ствар која се може покретнути и одвојити од главне ствари без повреде њене субстанције (на пример, зграда као целина не може бити предмет крађе али врата и прозори могу, земљиште не може бити предмет крађе, али то могу бити његови плодови и делови: хумус, шљунак итд). Као покретне ствари у кривичном праву се сматрају и делови неке покретне ствари, ако се од ње одвоје или се могу одвојити без повреде њене субстанције, (нпр. делови машина, шина, итд).

Заједничка карактеристика кривичног дела крађа, разбојништво, разбојничка крађа, утаја, превара, изнуда, уцена, је и то да се врше у намери прибављања противправне имовинске користи, а која намера је уско повезана са поменутиим објектима ових дела, јер су то предмети који имају материјалну вредност, тако да се њиховим одузимањем или присвајањем остварује нека материјална корист.

У вези са наведеним је и заједничко обележје кривичних дела против имовине да имају и вредносни елемент, јер се штета проузрокована њиховим извршењем може новчано изразити, а што је с друге стране посебно значајно код одређивања блажих и квалификованих облика појединих кривичних дела из наведене групе.

Такође бисмо поменули и кривично дело изнуда из чл. 214. ст. 4. КЗ и кривично дело прикривање из чл. 221. ст. 4.КЗ, где је између осталог као радња извршења прописано: "ко се бави вршењем дела из ст. 1. до ст. 3. овог члана...". Наведено помињемо из разлога јер долази до одређених промена у схватањима, у вези тога колико је радњи извршења потребно предузети да би постојало дело чија је радња одређена законским изразом "ко се бави...".

У до сада преовлађујућим схватањима наше теорије а и судске праксе законски израз употребљен за радњу извршења кривичног дела: "ко се бави..." упућивао је на то да се ради о колективном кривичном делу, које се врши у виду занимања, из чега би даље произишлаго да је за остварење ове радње извршења битно, да је извршилац поступао са спремношћу да инкриминисане радње понавља, а да није од значаја да ли

је извршио једну или више радњи.¹³ Дакле, дело би постојало и случају када је учинилац предузео само једну радњу, уколико би се утврдио одговарајући психички однос учиниоца, односно спремност да инкриминисану радњу понавља.¹⁴

Међутим, у погледу наведеног питања има и другачијих схватања,¹⁵ у којима се наводи да "бављење" представља трајније и чешће предузимање неке делатности, које је по правилу праћено спремношћу учиниоца да ту делатност понавља, те да је за постојање дела неопходно да је учинилац најмање два или више пута, предузео радњу извршења кривичног дела.¹⁶

Сумирајући овај кратки осврт на неке опште карактеристике кривичних дела против имовине, можемо рећи, да је једно од обележја кривичних дела против имовине, управо њихова хетерогеност. Хетерогеност, долази до изражаја кроз различите посебне заштитне објекте појединих дела из ове групе, затим кроз различите облике у којима се дела јављају, различита својства учиниоца која закон прописује (нпр. учинилац кривичног дела прикључење објекта без грађевинске дозволе из чл. 219б. КЗ, може бити лице које прикључи објекат или одговорно лице у правном лицу које дозволи прикључење објекта) и др.

¹³ Група аутора: *Коментар Кривичног закона Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 1995. стр.484.

¹⁴ Поменути став је био прихваћен и у судској пракси, тако да је у пресуди Савезног врховног суда КЗ.103/57 наведено да је "надрилекарство кривично дело, без обзира на број случајева лечења болесника". Такође, је и у пресуди Врховног суда Кж.1465/52 дошло до изражаја схватање, да се „психички однос према понављању дела сматра битним за постојање колективног кривичног дела, па ако он постоји онда нема значаја, да ли је понављање дела вршено или је дело учињено једном али са спремношћу да га понавља“.

¹⁵ У коментатарима наведеног института може се срести став да за постојање кривичних дела, код којих је радња извршења описана у закону као „бављење“ одређеном делатношћу, није довољно једнократно извршење те радње, без обзира на евентуалну спремност извршиоца да овакве радње и даље врши. Наиме, по таквом становишту, ако је извршено кривично дело само једанпут, односно предузета само једна радња извршења, онда нема никаквог привидног стицаја, тако да нема ни колективног кривичног дела, као случаја привидног реалног стицаја. Друго, по наведеном схватању је неприхватљиво, да се тамо, где закон, изричитом формулацијом радње извршења, захтева да она буде предузета више пута, има узети да је тај услов остварен, само због тога што је извршилац показао готовост да дело понавља, јер би се тако у ствари кажњавало за саму намеру, према: Стојановић, З.: *Кривично право општи део*, Службени гласник, Београд, 2000 година, стр.222.

¹⁶ Лазаревић, Јб.: *op.cit.* стр.671.

Кривична дела против имовине у судској пракси

Кривична дела против имовине се веома често јављају у судској пракси, тако да се континуирано отварају нова питања и увек је значајно и корисно указати поводом тога на неке нове закључке у судским одлукама, па и поновити већ познате и заузете ставове, управо због учесталости њихове примене.

У вези са тим су увек актуелана питања која се тичу примене института стицаја, покушаја, саизвршилаштва, застарелости, који институти се најчешће примењују у предметима кривичних дела против имовине, као и примена одређених кривично-процесних одредби, посебно оних које се тичу дозвољености доказа.

Кривично дело превара и застарелост

Питање које се веома често поставља у судској пракси је питање утврђивања застарелости када је у питању кривично дело превара из чл. 208. ст. 1. КЗ.

Имајући у виду законска обележја кривичног дела превара, која прописују као елемент радње извршења, да је учинилац у намери прибављања противправне имовинске користи лажним приказивањем чињеница "довео у заблуду или одржавао у заблуди" оштећено лице, поставља се питање:

- уколико су у конкретном случају код кривичног дела превара предузете обе радње и довођење у заблуду и одржавање у заблуди, да ли се рок застарелости код кривичног дела превара рачуна од тренутка када је оштећени доведен у заблуду или од тренутка када је престало и одржавање у заблуди тог лица?

У овом случају, мора се поћи од одредбе чл. 104. ст 1. КЗ, којом је прописано да застарелост кривичног гоњења почиње да тече од дана када је кривично дело извршено. Такође је одредбом чл. 16. ст. 1. КЗ прописано је да је кривично дело извршено у време кад је извршилац радио или био дужан да ради, без обзира кад је последица дела наступила.

Затим, битно је, да је радња извршења кривичног дела преваре, довођења у заблуду - тренутног карактера, а радња одржавања у заблуди - трајног карактера, што је такође значајно са аспекта рачунања рока застарелости кривичног гоњења, јер код радњи трајног карактера застарелост

не тече све док траје противправно стање и рок за застарелост почиње тећи престанком противправног стања.

Сходно томе, почетак застарелости кривичног гоњења, у конкретном случају кривичног дела превара, рачунаће се од дана када је престало одржавање у заблуди оштећеног лица, а не од дана када је оштећени доведен у заблуду. Дакле, ако је окривљени, оштећеног довео у заблуду, нпр. дана 10.05.2008. године и одржавао га у заблуди до маја 2013. године (без обзира на протек времена и дужину трајања противправног стања), рок за застарелост рачунаће се од задњег дана априла 2013. године (дакле пре почетка маја, јер је радња одређена "до маја").

Одговор на поменуто питање може се наћи и у одлуци Врховног касационог суда, Кзз.2/12 од 25.01.2012. године¹⁷, у којој је наведено:

"Радња кривичног дела из чл. 208. ст. 1. КЗ која представља "одржавање у заблуди" значи активно обнављање и учвршћивање заблуде створене код другог лица, даљим и новим лажним приказивањем чињеница и траје до тренутка када је престало противправно стање. Имајући у виду чињенице у списима предмета окривљени је поступао управо тако, новим и лажно датим гаранцијама да ће оштећеном измирити дугове за неплаћене закупнине простора, једном из имовине свог предузећа, други пут из личне покретне или непокретне имовине, те затим изнова обећавао ово оштећеном у наведеном периоду, све до раскида уговора о закупу. Окривљени је кривично дело преваре из члана 208. став 1. КЗ извршио на оба алтернативно прописана начина извршења кривичног дела у питању и то лажним приказивањем чињеница, дана 12.05.2005. године, оштећеном Д.М. да ће му заостале закупнине (неплаћене од марта до јула 2005. године) платити одједном и да ће убудуће исте редовно и уредно измиривати, чиме је оштећеног довео у заблуду, а потом га све до новембра 2008. године одржавао у заблуди тако што му је то исто обећавао на описани начин сваког месеца. Дакле, окривљени је радње извршења кривичног дела у питању предузимао у периоду од 12.07.2005. године до новембра 2008. године, па се у овом случају почетак застарелости кривичног гоњења ра-

¹⁷ Пресуда Врховног касационог суда, Кзз.2/12 од 25.01.2012. године. Видети сајт: Судска пракса Врховног касационог суда у Београду, <http://www.vk.sud.rs/sr/solr-search-page>, 02.11.2014.

чуна од краја октобра 2008. године, као времена престанка радње извршења и апсолутна застарелост наступа крајем октобра 2014. године, кад, сходно одредбама чл. 104. ст. 6. у вези са чл. 103. тач. 6. КЗ, истиче време од шест година за застарелост гоњења за кривично дело из члана 208. став 1. КЗ, за које је окривљени оглашен кривим првостепеном пресудом."

***Дозвољеност доказа - увид сведока у фотографију
предочену у ПУ***

Питање које се такође јавља у судској пракси, код кривичних дела против имовине, у случајевима када је потребно утврдити идентитет извршиоца је:

- да ли је дозвољен доказ то што је сведок препознао окривљеног као извршиоца дела на фотографији која му је предочена у просторијама полиције.

Веома често је од стране одбране истицано, на главном претресу или у жалбеном поступку да је првостепена пресуда заснована на доказу на коме се према одредбама Законика о кривичном поступку не може заснивати, јер препознавање окривљеног од стране сведока није обављено у складу са одредбама Законика о кривичном поступку које прописују начин препознавања нити је сачињен записник о препознавању, тако да исто не може бити коришћено као доказ, нити на таквом доказу пресуда може бити заснована.

Према ставу Врховног касационог суда у пресуди Кзз.249/2013 од 23.01.2014. године¹⁸:

"Предочавање фотографија окривљеног сведоку С.М. од стране радника полиције, сведока М.М., није доказна радња препознавања лица у смислу чл. 104. раније важећег ЗКП, па се законитост ове радње и не може оцењивати према наведеној одредби. Као процесна радња, предочавање фотографије окривљеног (осумњиченог) лицу које може имати сазнања о физичком изгледу учиниоца кривичног дела, није забрањено ни ис-

¹⁸ Пресуда Врховног касационог суда, Кзз.249/2013 од 23.01.2014. године. Видети сајт: Судска пракса Врховног касационог суда у Београду, <http://www.vk.sud.rs/sr/solr-search-page>, 02.11.2014

кључено ни једном одредбом раније важећег ЗКП, а изван тога суд није везан ни ограничен посебним формалним доказним правилима (чл. 18. раније важећег ЗКП). Стога се ова радња у конкретном случају, ни изјашњење сведока С.М. поводом показане фотографије окр. И.Ћ. (да га је препознала на тој фотографији), које је саставни део њеног исказа датог у својству сведока током поступка, сами по себи не могу сматрати недозвољеним по закону. Самим тим ни законитост доказа – исказа сведока С.М. на коме се, између осталих, заснива утврђено чињенично стање, није доведена у питање."

Сматрамо да се наведени став, може применити и на одредбе новог ЗКП, јер исте такође не забрањују, нити искључују могућност предочавања фотографије евентуалног учиниоца дела, или пак оштећеног, или неког другог учесника у кривичном поступку, сведоку који може имати сазнања о физичком изгледу тог лица.

Кривично дело разбојништво и продужено дело

Указали бисмо и на питање које се такође постављало у судској пракси:

- да ли је могућа конструкција продуженог кривичног дела, у случају кривичног дела разбојништво из чл. 206. ст. 1. КЗ.

У погледу наведеног питања, су се могле срести различите одлуке у судској пракси, али је у коначном ипак прихваћен став, да кривично-правни институт продуженог кривичног дела, код кривичног дела разбојништва, није могућ по закону, с обзиром на одредбу чл. 61. ст. 2. КЗ. Ово из разлога, што је кривично дело разбојништва сложено кривично дело, састављено од два кривична дела: принуде (чл. 135. КЗ) - кривичног дела против слобода и права човека и грађанина и крађе (чл. 203.КЗ) – кривичног дела против имовине, где принуда претходи крађи и представља средство за њено извршење.

Истоветност оштећеног, у смислу чл. 61. ст. 1. КЗ, као факултативни елеменат за постојање продуженог кривичног дела у начелу, није услов да се једна континуирана делатност учиниоца правно оцени као јединствено дело, али представља важан елемент за оцену - да ли више истоврсних дела са становишта животног и логичног резоновања чини јединствену целину.

Међутим, чл. 61. ст. 2. КЗ прописано је да кривична дела управљена против личности, што је случај са кривичним делом принуда, могу чинити продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу, а како су у овом кривичном предмету дела извршена према различитим лицима у просторно и временски одвојеним догађајима, то свака радња за себе садржи сва битна законска обележја кривичног дела разбојништва из чл. 206. ст. 1. КЗ, тако да са другом истом таквом радњом не може чинити једно продужено кривично дело.¹⁹

Стицај кривичног дела превара са другим кривичним делима

У судској пракси и теорији, је нарочито расправљано питање стицаја између кривичног дела превара (чл. 208. КЗ) и других кривичних дела, јер је кривично дело превара врло често у дотицају са другим кривичним делима, те се јавило питање њиховог међусобног односа.

Посебно је предмет анализа, било и постојање стицаја између кривичног дела превара (чл. 208. КЗ) и кривичног дела фалсификовања исправе (чл. 355. КЗ), управо због изузетно честих случајева да се у пракси преплићу радње, које обухватају битна обележја оба наведена дела.

Тако је на пример, у пресуди Врховног суда Војводине Кж.351/69, изражен став "да је могућ стицај кривичног дела преваре и фалсификовање исправе (сада чл. 355. КЗ), јер је кривично дело преваре, посебно кривично дело са посебним заштитним објектом, а што би се односило и на кривично дело фалсификовање исправе, које такође има засебан заштитни објекат у односу на кривично дело превара, па се према томе ради о два различита заштитна објекта, што оправдава постојање стицаја између предметних дела".²⁰

Наведени став је заснован на закључку суда, да је кривично дело фалсификовања исправе је свршено самим прављењем лажне или преиначењем праве исправе, у намери да се тако фалсификована исправа употреби као права и да је за његово постојање ирелевантно, у ком циљу је учинилац намеравао да употреби фалсификовану исправу.

¹⁹ Више о наведеном: Пресуда Врховног касационог суда, Кзз.3/10 од 03.03.2010. године и пресуда Кзз.40/10 од 31.03.2010. године. Видети сајт: <http://www.vk.sud.rs/sr/solr-search-page>, 02.11.2014.

²⁰ Група аутора: стр. 622.

Дакле, ирелевантно је, да ли је учинилац таквом исправом и њеном употребом, намеравао да себи или другом прибави какву корист, другоме нанесе штету или оствари неки други циљ. У том односу кривично дело преваре представља самостално кривично дело, јер оно спада у кривична дела против имовине и његова радња извршења састоји у довођењу у заблуду неког лица и његовом навођењу, од стране учиниоца, на одређено чињење или пропуштање, којим оштећује своју или имовину другог лица, те како су предметна дела разнородна кривична дела, са различитим заштитним објектом и посебним радњама извршења, то је могућ и њихов стицај.

Међутим, у судској пракси ипак има ставова да постоји могућност привидног стицаја између кривичних дела фалсификовање исправе и превара, у случају ако би употреба лажне или преиначене праве исправе, као облика кривичног дела фалсификовање исправе, истовремено представљала радњу извршења кривичног дела преваре, али само у случају уколико је исправу фалсификовало неко друго лице, а не учинилац, те би у том случају постојало само кривично дело превара. Сходно наведеном, привидни стицај би могао постојати између ових дела, када би се кривично дело превара вршило употребом фалсификоване исправе, у случају уколико је исправу фалсификовало неко друго лице, а не учинилац.²¹

Кривично дело одузимање туђе ствари

Према ставу судске праксе, кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл. 213 КЗ (према ранијем закону кривично дело одузимање возила чл. 174. КЗРС сада према КЗ је прописано и кривично дело одузимање туђе ствари из чл. 211 КЗ) када је у дотицају са другим кривичним делима против имовине у великом броју случајева баш због свог заштитиног објекта, који се разликује у односу на друга кривична, налази се у стицају.

Тако су према налажењу у одлуци Врховног суда Србије²² "учиниоци који претњом да ће напасти на живот оштећеног таксисте у чије возило су ушли, одузму разне ствари које су затекли у возилу оштећеног у намери да тим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист, па затим возило које су одузели пошто су принудили таксисту да напусти

²¹ Пресуда Врховног суда Србије, Кж.І.1267/87 од 12.01.1988. објављена „Интермех Судска Пракса“, 2008.

²² Пресуда Врховног суда Србије, Кж.І.1173/02 од 30.01.2003. „Интермех Судска Пракса“, 2010

возило, употребе за возњу, извршили у стицају кривично дело разбојништво (раније чл. 168. ст. 1. КЗ) и одузимање возила".

Такође, наведено кривично дело и у односу са кривичним делом уништење и оштећење туђе ствари из чл. 212 КЗ, стоји у стицају, те у случају "када окривљени користи за возњу туђе моторно возило без пристанка овлашћеног лица, којом приликом слети са пута па га полије бензином и запали и тада учини неупотребљивом туђу ствар, па је оваквим радњама извршио у стицају кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила и уништење и оштећење туђе ствари".²³

***Својство учиниоца дела и правна квалификација
кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. КЗ
или кривичног дело превара из члана 208. КЗ***

Често је постављано питање у судској пракси, да ли се у конкретним случајевима радило о кривичном делу злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. КЗ или кривичном делу превара из члана 208. КЗ, имајући у виду блиске и сличне радње извршења, којима се по правилу ова дела остварују.

Поводом овог питања указујемо на сентенцу утврђену на седници Кривичног одељења 25.06.2010. године, Врховног касационог суда која гласи:

"Кад је осуђени у својству власника и директора приватног предузећа у намери прибављања противправне имовинске користи за своје предузеће довео у заблуду директора оштећеног предузећа прикривањем чињенице да на рачуну свог предузећа нема средстава и лажним приказивањем да је у стању да у уговореном року плати робу купљену од оштећеног предузећа и на тај начин га навео да му на штету имовине свог предузећа испоручи робу у одређеној вредности, у ком износу је прибавио имовинску корист за своје предузеће, извршио је кривично дело злоупотреба

²³ Пресуда Окружног суда у Београду, Кж.23/05 од 25.01.2005, „Инг-Про Пакет прописа“, 2011.

овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 2. КЗ, а не кривично дело превара из члана 208. став 4. у вези са ставом 1. КЗ."²⁴

У конкретном случају је утврђено да је окривљени приликом куповине робе од оштећеног предузећа поступао у својству власника и директора приватног предузећа и да је прикривањем чињенице да на рачуну свог предузећа нема средстава и лажним приказивањем да је у стању да плати купљену робу у уговореном року довео у заблуду директора оштећеног предузећа и на тај начин га навео да му на штету свог предузећа испоручи робу у вредности од 2.046.809,38 динара, те у том износу прибавио имовинску корист за своје предузеће.

Како из утврђених одлучних чињеница произилази да је окривљени критичном приликом поступао у својству одговорног лица у предузећу (које својство има као власник и директор приватног предузећа сходно одредби чл. 112. ст. 5. КЗ) и да је инкриминисаним радњама, које представљају неистинито приказивање стања и кретања средстава и резултата пословања предузећа и које је било од утицаја на доношење пословне одлуке на штету оштећеног предузећа (да се прода и испоручи роба предузећу осуђеног) осуђени прибавио имовинску корист за своје предузеће у означеном износу, што му је и била намера, то у радњама окривљеног стоје законска обележја (а имајући у виду износ прибављене имовинске користи као квалификаторну околност) кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из чл. 238. ст. 1. тач. 2. КЗ, а не кривичног дела превара из чл. 208. став 4. у вези са ставом 1. КЗ.

Оно што пре свега разликује наведена кривична дела, тиче се својства извршиоца и лица коме се прибавља имовинска корист јер су то код кривичног дела преваре физичка лица, а код кривичног дела злоупотребе овлашћења у привреди извршилац је одговорно лице у правном лицу, док се имовинска корист прибавља правном лицу.

Овим примерима из судске праксе је указано на решења појединих спорних питања која су се постављала у свакодневном раду у конкретним предметима, али истовремено је указано и да кривична дела про-

²⁴ Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзп. 197/10 од 16.03.2010. године, утврђена на седници Кривичног одељења 25.06.2010. године, Видети сајт: <http://www.vk.sud.rs/sr/кривична-материја-0>, 06.11.2014.

тив имовине увек представљају актуелну тему која је и даље предмет сталног разматрања судске праксе и теорије кривичног права.

Закључак

На основу нових законских одредби и обрађених карактеристичних решења из судске праксе, поменутих теоријских становишта и блиских института, може се закључити да се кривична дела против имовине у домаћем кривичном праву унапређују, допуњују, прецизирају, термилолошки и граматички појашњавају и усклађују са другим законским изворима.

У односу на домаће кривично право може се приметити да је Кривични законик из 2006. године пре доношења Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године, показао извесно ублажавање у погледу законом прописаних казни у односу на претходни Кривични закон Републике Србије. Међутим, Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године и каснијим изменама, долази до пооштравања законом прописаних казни за поједина кривична дела против имовине, нових инкриминација и допуна низа ранијих инкриминација, увођења нових законских термина и квалификованих облика и исти је у целини у целини гледано "строжи" у односу на претходни Кривични законик.

Учешће извршених имовинских деликата у укупном криминалиту како код нас тако и у другим замљама је веома високо, те долази до њиховог испољавања у најразличитијим модалитетима и облицима, што стално отвара нова питања у области теорије и практичне примене датих законских решења. Управо из тих разлога је увек значајно да се изврши резимирање усаглашених судских и теоријских ставова у односу на кривична дела против имовине и појединих дела из те групе, као и њихових међусобних односа, јер то омогућава да се лакше уоче нове ситуације, које су део свеукупног развоја друштва, а у чијим оквирима се и пружа кривичноправна заштита.

Литература

1. Група аутора: *Коментар Кривичног закона Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 1995.
2. Јовановић, Љубиша, *Кривично право, Општи део*, Научна књига, Београд, 1973.
3. Јовашевић, Драган, *Кривично право-општи део*, Београд, 2006.

4. Лазаревић, Љубиша, *Казне и мере безбедности у савременом кривичном праву*, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1969.
5. Лазаревић, Љубиша *Коментар Кривичног законика Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 2006.
6. Радовановић, Милош, *Кривично право СФРЈ, Општо део*, Савремена администрација, Београд, 1972.
7. Стојановић, Зоран, *Кривично право, општи део*, Правна књига, Београд, 2006.
8. Стојановић, Зоран, *Коментар Кривичног законика*, Службени гласник, Београд, 2009.
9. Таховић, Јанко, *Коментар Кривичног законика*, Савремена администрација, Београд, 1956.
10. Таховић, Јанко, *Кривично право, Општи део*, Савремена администрација, Београд, 1961.
11. Таховић, Јанко, *Кривично право-општи део*, Савремена администрација, Београд, 1966.
12. Чејовић, Бора, *Кривично право у судској пракси - Општо део*, Светозар Марковић, Београд, 1983.

ПРАВНА СХВАТАЊА
усвојена на заједничким седницама
свих Апелационих судова

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПРОВЕ

Правна схватања

ВИСИНА ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

У погледу висине дневница за службена путовања у иностранство примењује се Уредба о издацима за службена путовања у земљи и селидбе у иностранство који се Савезним органима управе признају у материјалне трошкове до 29.09.2007. године, а од овог датума Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, као посебан пропис на који упућује члан 118 тачка 3 Закона о раду. Општи акт послодавца не може прописивати нижу вредност ино дневница од вредности прописаних уредбом.

Из образложења:

"Одредба члана 118. Закона о раду: Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду и то:

- за време проведено на службеном путу у земљи;
- за време проведено на службеном путу у иностранству, најмање у висини утврђеној посебним прописима.

Поштујући ову правну норму слово закона, када је реч о накнади трошкова на службеном путу у иностранству, одређује да та накнада мора бити најмање у висини утврђеној посебним прописима. На тај начин дефинисан је начин одређивања доњег минимума назначене накнаде: то је учињено упућивањем на посебан пропис који се мора поштовати. При томе се тај пропис не дефинише. Међутим, то са становишта правог значења може бити само Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника пошто други пропис то питање не уређује.

Тачно је да ова Уредба садржи говор о правима запослених у одређеној радној средини (државним органима): и у односу на одређену категорију запослених: намештеници и службеници у државним органима и да је у њеним прелазним одредбама садржана норма о проширеном њеном дејству на аутономну покрајину и јединице локалне самоуправе. Међутим, и није био њен задатак да одреди своје проширено дејство и на

друге радне средине где важи општи радно правни режим. То је могао да учини ЗОР. Закон је то учинио:

- прописујући да доњи минимум одређује посебан пропис;
- употребљавајући атрибут посебни уз реч пропис и на тај начин указујући на његову индивидуалност;

Томе у прилог и ови разлози:

- што појам пропис својим садржајем обухвата и подзаконске акте, а међу њима и Уредбу као акт ниже правне снаге;
- што не постоји други пропис на исту тему;
- што употреба исказа: посебни пропис у тексту ове норме показује да то не може бити општи акт у значењу из одредбе члана 8. ЗОР;

На то упућује и то што неопорезиви износ дневница за службено путовање у иностранство, за запослене је до износа прописаног Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. У том смислу се у одредби чл. 18. став 1. тачка 2. Закона о порезу на доходак грађана прописује да се не плаћа порез на износ дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног државног органа.

Из овога и закључак: да је Уредба донета ради примене на државне службенике и намештенике, али се по наведеној одредби Закона о раду примењује и на све остале запослене код свих послодаваца. Исто у теорији.

Када би се прихватило супротно правно схватање тада би била створена дискриминација у односу на категорију запослених у општем радно правном режиму у односу на државне службенике и намештенике;

То чини основаним закључак: да из наведене одредбе Закона произилази да послодавац својим колективним уговором, правилником о раду односно уговором о раду запосленом не може утврдити мање право од права утврђеног Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. То практично значи да се Уредба непосредно примењује и да послодавац није обавезан да у колективном уговору, правилнику о раду или уговор о раду уноси одредбе о издацима за службено путовање у иностранство, изузев ако се запосленом не утврде већа права од права утврђених Уредбом.

Ради тога неупотребљиви су разлози:

- Да је међународни друмски теретни саобраћај специфична делатност;
- Боравак возача у више земаља у току руте;
- Ценовник за услуге транспорта и однос понуде и тражње;
- Однос трошкова - наплаћене цене превоза;
- Ризик пословања;
- Пређена километража;
- Специфично висок удео трошкова у бруто приходима;
- Специфичан ризик окружења;
- Разликовање права и правде;
- Ефекат који транспортна предузећа имају на друге привредне субјекте;
- Дужина трајања транспорта за одређене дестинације и с тим у вези преглед ценовника услуга транспорта те да зато недостаје вредност за подмирење ових трошкова.

Сви ти разлози су ванправног карактера и не указују на погрешну примену права код заузетог правног схватања. Одређени разлози и ако не утичу на поштовање доњег минимума могу утицати на висину обима ове накнаде као што је на пример време проведено на службеном путу и ништа више од тога.

Разлог да дневнице за службено путовање (у земљи или иностранству) не представљају законску категорију је правно погрешан.

Томе се противи цитирана одредба чл. 118. став 1. тач. 2. и 3. ЗОР. Истина у овој норми се не користи појам дневница али користе појмови трошкови, накнада за службени пут, земља иностранство и посебан пропис, као меродаван извор права који у свом садржају обухвата и дневнице и одређује њихов обим зависно од земље. То што је вредност дневница фиксно одређена независно од врсте трошкова занемарује њихову сврху да буду паушална накнада за друге трошкове који нису индивидуално исказани али постоје због обављања посла у иностранству. Зато је без значаја аргумент да ЗОР не познаје појам дневница;

Позивање на одредбу члана 32. став 1. ал. 2. и 3. Општег колективног уговора ("Сл. гласник РС" 50/08, 104/08 и Анекс 8/09) је ирелевантно из разлога:

- што одредба чл. 118. тачка 3. ЗОР не упућује на општи акт већ на посебан пропис и што тај општи акт више није у правном саобраћају.

Тврдња да су одредбе ЗОР недовољно јасне не користи код целине изнетих разлога.

Који су то посебни прописи образложено је у претходном тексту. У присуству тих разлога остаје без значаја позивање на одредбу чл. 37. Закона о платама државних службеника и намештеника. Ово и зато што је упућујућа норма садржана у одредби чл. 118. став 1. тачка 3. ЗОР као општем радно правном пропису.

То што послодавац у општем радноправном режиму послује по тржишним принципима је без значаја из два разлога:

- што га то не ослобађа обавезе да покрије трошкове пословања у које спадају и трошкови службеног путовања;

- и што је контрола општих норми у надлежности Уставног суда.

Позивање на Самоуправни споразум о највишем износу дневница возачког особља у међународном друмском теретном саобраћају за време проведено у иностранству није од значаја. Претходно тај текст није досатављен али и да јесте није посебан пропис, а и не може заменити посебан пропис јер се не сврстава у његов садржај са становишта доњег минимума. Разлог да се транспортна делатност не може сматрати службеним путовањем тиче се основа, а не обима права на накнаду из овог основа.

То исто важи и за употребљени разлог који се односи на опис послова возача. При томе сама дефиниција службеног путовања као путовања из Републике Србије у страну државу и обратно, службено путовање из једне у другу страну државу и службено путовање из једног у друго место у другој држави указује да запослени и тада обавља послове.

Када се ради о примени Уредбе и у односу на запослене који се налазе у општем радноправном режиму упућује и одговор дат од стране Министарства рада и социјалне политике на питање: Да ли се на запослене код послодавца са статусом привредног друштва примењује Уредба о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и намештеника, односно да ли послодавац има право да запосленом умањи износ дневнице за службено путовање у иностранство за 60% у случају када обезбеди тзв. ланч пакет за сва три obroка?

Право запосленог код послодавца са статусом привредног друштва на накнаду трошкова за службено путовање у иностранство утврђено је одредбом члана 118. тачка 3) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 - даље: Закон) и одредбом члана 32. алинеја 3. Општег колективног уговора ("Сл. гласник РС", бр. 50/2008, 104/2008 - Анекс I и 8/2009 - Анекс II).

Према члану 118. тачка 3) Закона, запослени има право на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у иностранству, у складу са општим актом и уговором о раду, а најмање у висини утврђеној посебним прописима, при чему се под посебним прописом сматра Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/2007- пречишћен текст - даље: Уредба).

Према одредбама члана 32. Општег колективног уговора, послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у иностранству под условима и на начин утврђен одговарајућим прописима, где се под одговарајућим прописима сматра Закон и Уредба.

Наведеним одредбама Закона и Општег колективног уговора прописано је право запосленог, односно обавеза послодавца да запосленом надокнади трошкове службеног путовања у иностранство у висини, под условима и на начин утврђен посебним прописом, а то је у складу са наведеном уредбом. Овим одредбама није направљена разлика у односу на делатност послодавца или у односу на радна места запосленог. На основу тога сматрамо да се наведене одредбе примењују подједнако на све послодавце и запослене на територији Републике Србије, независно од делатности којом се послодавац бави или специфичности послова које обавља, као и независно од радног места или послова на којима је запослени распоређен да ради. То би значило да у сваком случају када послодавац упути запосленог на службени пут у иностранство да за његов рачун обави одређени посао, дужан је том запосленом да надокнади трошкове службеног путовања најмање у висини утврђеној наведеним прописима (Уредбом). Према члану 22. Уредбе, износ утврђене дневнице за службено путовање у иностранство умањује се ако је обезбеђена бесплатна исхрана и то у одређеном проценту зависно од тога да ли су обезбеђена бесплатно сва три obroка или сваки појединачно. У ставу 4. овог члана, прописано је шта се сматра обезбеђеном бесплатном исхраном за државне службенике

и намештенике, што се, прописаном обавезом примене Уредбе преноси и на послодавца са статусом привредног друштва. Ставом 4. наведеног члана утврђено је да је државном службенику и намештенику који службено путује у иностранство обезбеђена бесплатна исхрана ако се она не финансира из буџета Републике Србије.

Применом Уредбе на запослене у привредном друштву ова одредба би значила да је запосленом у привредном друштву обезбеђена бесплатна исхрана на службеном путу у иностранству ако се она не финансира из средстава привредног друштва. У смислу ове одредбе, најчешћи случај када је на службеном путу у иностранству обезбеђена бесплатна исхрана је када послодавац упути запосленог на службени пут у иностранство код пословног партнера или другог лица ради преговора и договора о пословној или сличној сарадњи или склапања пословних уговора, којим поводом страни послодавац приређује пословни ручак или вечеру или у случају других свечаних манифестација када запослени присуствује свечаном ручку или вечери и сл. У том случају трошкови исхране запосленог на службеном путу обезбеђују се на терет страног партнера, односно другог лица, што значи да се не плаћају из средстава послодавца. О овоме је обично послодавац унапред информисан, те је из тих разлога у члану 16. став 2. Уредбе прописано да послодавац приликом издавања путног налога запосленом у путном налогу обавезно стави напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана. То значи да је умањење дневнице запосленом по основу обезбеђене бесплатне исхране могуће само изузетно када се за то стекну прописани услови и када то послодавац посебно назначи у путном налогу. Такође, чланом 20. Уредбе је прописано да се трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству накнађују запосленом у износу који је утврђен у Списку дневница по страним државама. Прописани износи дневница се исплаћују без обавезе запосленог да достави доказ о коришћењу obroka или градског превоза. Овом одредбом је прописана висина дневнице за службено путовање у иностранство у новчаном износу према валути земље у коју запослени путује. Дакле, нема законског основа, односно Уредбом није прописана могућност да се дневница запосленом исплаћује у натури, путем тзв. ланч пакета или на други начин давањем намирница, те да се по том основу умањи дневница као да је обезбеђена бесплатна исхрана. Мишљења смо да овакву могућност послодавац не може да примењује и када је то утврдио својим општим актом, јер би то према члану 8. Закона, зна-

чило да је запосленом утврдио мање право од права утврђеног законом, те се у том случају, сходно члану 9. овог закона, мора примењивати закон.

На основу свега напред наведеног мишљења смо да:

- према члану 118. тачка 3) Закона и члану 32. Општег колективног уговора, запослени има право на накнаду трошкова за службено путовање у иностранство најмање у висини, под условима и на начин утврђен Уредбом;

- се Уредба сходно члану 118. тачка 3) Закона, примењује на све послодавце и запослене, што значи и на послодавце са статусом привредног друштва као и на запосленог на радном месту возача у међународном транспорту;

- не постоји законски основ да се запосленом у конкретном случају на радном месту возача, који је од стране послодавца са статусом привредног друштва упућен на службени пут у иностранство, уместо дневнице за службени пут која је прописана Уредбом, обезбеди исхрана на службеном путу давањем тзв. ланч пакета за сва три obroка на терет средстава послодавца, и да му се по том основу умањи дневница за 60% као да је обезбеђена бесплатна исхрана сходно члану 22. Уредбе."

(Коначно правно схватање усвојено једногласно на заједничкој седници апелационих судова и то: Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Нишу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 11. априла 2014. године у просторијама Апелационог суда у Новом Саду)

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НЕИЗАБРАНИХ СУДИЈА

1. Доношење незаконите одлуке о неизбору судија само по себи није узрок чија је последица повреда части, угледа и достојанства личности;

2. Одсуство образложења одлуке о неизбору судије, односно негативни вредносни и стручни суд исказан у тој одлуци и када немају чињеничну заснованост представљају правно погрешан суд али сам

по себи не даје право на накнаду штете по основу повреде части и угледа и достојанства личности;

3. Искизи у одлуци о неизбору *in concreto* судије који нису правно потребни за ту врсту одлуке, већ су безразложно употребљени, а задиру у приватност, лични и породични живот личности су основ за повреду части и угледа;

4. Послодавац не одговара за повреду части и угледа која је настала због објављене непотпуне или неистините информације о неизбраном судији када постоји солидарна одговорност новинара, одговорног уредника и правног лица које је оснивач јавног гласила у коме је та информација објављена;

5. Постоји одговорност послодавца ако је у јавном гласилу овлашћено лице у име његовог органа изрекло информацију која превазилази оквире разумно оправданих разлога за објашњење донете одлуке, а по садржају је таква да доводи до повреде назначених нематеријалних добара.

Нека појмовна разјашњења

Право на накнаду нематеријалне штете условљено је повредом правно заштићених добара: части, угледа слободе, достојанства односно других права личности. Видови накнаде нематеријалне штете су таксативно одређени. То су претрпљени и будући физички болови, претрпљени и будући страх, умањење животне активности, повреда части и угледа, повреда слободе и права личности.¹

Накнада нематеријалне штете која је остварена у виду повреде моралног интегритета оштећеног испољава се у повреди части, угледа или права личности као сатисфакција за душевни бол који оштећени трпи због тога. У теорији се разликује накнада нематеријалне штете нанесена у облику повреде осећања оштећеног од повреде угледа и части, јер је у овом другом случају могућ и повраћај, док се у првом случају повреде осећаја може применити само новчана накнада као сатисфакција.²

¹ Видети одредбу члана 200. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, (22/99,23/99, 35/99, 44/99)

² Видети: Борислав Т. Благојевић, Проф. др. Врлета Круљ Коментар Закона о облигационим односима, стр. 536

За нашу тему меродавни су и искази из одредбе члана 200. Закона о облигационим односима: суд ће ако нађе да околности случаја и то оправдава.

Капацитет одлуке о неизбору да буде узрок настанка ове врсте штете

Одлука о неизбору судије нема сама по себи капацитет да буде узрок настанка назначених видова нематеријалне штете из одредбе члана 200 ЗОО, па ни онда када садржи стручни односно вредносни суд о судији у односу на кога се односи. Услов је да њен аутор није изашао из оквира своје надлежности и има за циљ повреду ових добара. То важи и онда када је одлука о неизбору судије поништена. Томе у прилог ови разлози:

1) Одлуку о неизбору судије донео је надлежни орган;

2) Наведено мешање тежило је легитимном циљу: да се донесе одлука о избору по расписаном конкурс. Мешање о коме је реч одговарало је "актуелној друштвеној потреби". На то упућује одредба члана 100. Закона о судијама чији је наслов: "Избор судија" која гласи: Избор судија, у складу са овим законом, извршиће се најкасније до 1. децембра 2009. године, изузев судија Врховног касационог суда који ће бити изабрани у року од 90 дана од дана конституисања Високог савета судства.³

Судије изабране у складу са овим законом ступају на функцију 1. јануара 2010. године.

Првим избором судије се сматра избор на дужност судије у складу са раније важећим законима. Именовање судије за прекршаје не сматра се првим избором.

3) То мешање у виду стручног, односно вредносног суда било је са становишта примене права неопходно за такву врсту одлуке. Исказани судови су са становишта примене права били средство – начин да се дође до циља материјализованог у виду одговарајуће одлуке о (не)избору, а не да се оствари повреда части и угледа *in concreto* лица које је узело учешће у поступку оглашеног избора. На то упућује Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и пред-

³ Закон о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009)

седника судова.⁴ У њеном наслову дати су са становишта права меродавни критеријуми. Такође, одредбама члана 7, 8 и 9 ове Одлуке дефинисане су моралне особине које чине судију достојним ове функције, у члану 11 мерила за избор судије за суд вишег степена, а у њеној одредби члана 14 разлози за сумњу у стручност и оспособљеност кандидата који се образују од елемената дефинисаних у њеном садржају.

Ради тога, са становишта примене права Високи савет судства имао је нормативно овлашћење да испита стручност, оспособљеност и достојност судије. Друго је питање да ли је утврдио чињенице на основу којих је дао правно и чињенично разумно прихватљив суд у односу на сваки од тих критеријума и да ли је оборио, или не постојање достојности судије. Резултати по жалбама дали су на то питање негативан одговор, али то је погрешна примена права и зато не може бити повреда части, угледа, достојанства која заслужује право на накнаду штете по тим основима.

4) Одсуство образложења и с тим у вези чињеничне базе за исказани стручни односно вредносни суд наведен у том појединачном правном акту и други дефекти одлуке о неизбору па и они који се односе на вредносну оцену неизабраног судије представљају повреду права на правично суђење. О томе се изјаснио и Уставни суд у бројним одлукама донетима по уставним жалбама. Ту повреду права не треба мешати за повредом части и угледа односно повредом достојанства. Ради се о различитим основима накнаде нематеријалне штете.

Томе у прилог и значење појма правично суђење према Правној пракси Европског суда за људска права. Појам право на правично суђење својим садржајем обухвата:

- право на поштено суђење-случај Вејан против Румуније 30658/05 од 06. децембра 2007. године;

- право на приступ суду и правну помоћ у грађанским стварима што подразумева право на независтан и непристрасан суд, односно одсуство тела на кога се не би примењивали стандарди поштењеног суђења - Голдер против Велике Британије 4451/70, пресуда од 21.02.1975;

- право на процесну равноправност у смислу једнакости оружја (equality of arms) - Kaufman против Белгије 10938/84 ДР 50 п.115;

⁴ Видети Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова ("Службени гласник РС", бр. 49/2009)

- право на образложену одлуку - Одлука Уставног суда Републике Србије Уж. бр. 1177/2010 од 23.02.2012. године и Салов против Украјине;

- право на делотворно правно средство;

- право на делотворно извршење судске одлуке;

У садржај појма повреде права на правично суђење зато се сврставају и искази: да се у одлукама о приговору појединим од незабраних судија ставља на терет да су нестручни, неспособни или недостојни за вршење судијске функције, јер ти по карактеру вредносни судови нису потврђени у поступку контроле тих појединачних аката.⁵

Ради тога, ове и повреде права на суђење у разумном року и с тим у вези искази наведени примера ради и слични искази не могу се успешно користити као разлог за повреду части, угледа односно достојанства личности.

5) Судија је подносећи пријаву пристао да буде изложен конкуренцији провером применом назначених мерила. Друго је питање то што он није очекивао неправилну примену права, али то не очекује ни странка која је грешком судије добила судску одлуку *contra et praeter legem* и то доказала употребом одговарајућег правног средства. У тој ситуацији се говори искључиво о судијској грешци али нема основа да је та грешка произвела као последицу повреду части и угледа.

Такав карактер има и негативна вредносна оцена у донетој одлуци о неизбору. То подразумева не само одлуку о утврђењу да је одређено лице незабрано на судијску дужност већ и накнадно донету одлуку која садржи паушално и/или чињенично правно незасновано образложење. Та одлука је код незабраног судије могла да изазове осећај разочарања, али не и увређености и понижености. Не, пошто незабрани судија зна да је такав стручни односно вредносни суд о њему погрешан и лако оборив. Томе у прилог и то што зна и свој вредносни и стручни квалитет. То је оно што се у теорији овако квалификује: "Љутња и нерасположење не оправдавају досуђене болнине".⁶ Томе у прилог то што он добро зна своју стручност морални и људски квалитет и своје резултате рада за меродавни период.

⁵ Одлука Уставног суда У бр. 534/2011 од 18.07.2012. године

⁶ Редактори: проф. др. Слободан Перовић и проф. др Драгољуб Стојановић: Коментар Закона о облигационим односима, књига прва, стр. 600

Сведочанство за то је и његов успех у поступку по жалби одлуке о његовом неизбору.

Приговор да је овде реч о судији не користи, јер је једнако вредан и значајан систем вредности сваког лица о себи или других о њему, а лица која су поднела пријаву на оглашени избор прихватила су као једну од могућности да по слову надлежан орган који о томе одлучује заузме и негативан вредносни односно стручни суд, па и да погреши.

У овој ситуацији Високи савет судства је донео одлуку у вршењу службе, а не у циљу остваривања намере омаловажавања. Подразумева се да *in concreto* одлука нема изразе који су одступили од уобичајеног изражавања односно оне који би били злонамерно употребљени.

Присутни искази у образложењу одлуке о неизбору на пример: да *in concreto* судија не испуњава критеријум стручности, оспособљености и достојности је вредносни и стручни суд. Он има негативно значење, али његов циљ није да се повреди част и углед, већ да се изврши избор и претходно одговарајућа селекција.

Околност да неизабрани судија у прво време није добио одлуку о неизбору и да зато није знао разлоге зашто није изабран такође се сврстава у садржај повреде права на правично суђење али нема капацитет да доведе до повреде части, угледа односно достојанства личности. Нема, јер у том случају ни неизбрани судија незна узрок зашто није изабран. Тада он може бити спречен да користи једнакост оружја, бити субјективно збуњен и разочаран у право односно правду које је и сам применио, али он тада на назначени начин није претрпео напад на назначена нематеријална добра.

Приговор да та селекција није била чињенично заснована и да одговарајуће правне норме нису правилно примењене је тачан али у овом амбијенту није од користи. Ради се о дефектима који се дефинишу као повреда права на правично суђење. Томе у прилог и то што њен циљ није да се нападне вредности које образују част, углед и достојанство већ да се искаже стручни и вредносни суд о том лицу као судији са становишта услова за његов избор. Ти пропусти када су необразложени као у конкретном случају сврставају се у погрешну примену права чија је последица касирање таквог акта. То је овде и остварено, али то не може довести до повреде части и угледа. Не може, јер је оно са становишта правила поступка и *ex lege* дефинисане надлежности Високог савета судства тежило леги-

тимном циљу. У присуству ових разлога неспорне чињенично правне погрешке на којима је заснован вредносни суд (без образложења најчешће у виду паушалних тврдњи) је друга врста повреде, а не повреда неког од назначених нематеријалних добара.

Покажимо то на примеру из истоврсне ситуације (суд, погрешна одлука о одговорности, њен садржај који по значењу има капацитет да угрози назначена нематеријална добра, поништај те одлуке и коначна одлука о одсуству одговорности конкретног лица). Тако у случају грешке судије који је уз повреду материјалних и процесних правила донео осуђујућу кривичну пресуду којом је окривљени оглашен кривим на пример за: кривично дело против живота и тела, имовине брака или породице уз присутне повреде процесног и материјалног закона последица је по слову закона укидање таквог акта, а коначан резултат је ослобађајућа кривична пресуда.⁷ Тада судија осим када је свесно кршио закон неће бити изложен грађанско правној одговорности за накнаду штете по назначеним основима, а Република Србија ће тада одговарати само у поступцима за остваривање права на накнаду штете и других права лица неосновано лишеног слободе или неосновано осуђеног примењиваће се одредбе чл. 584. до 595. Законика о кривичном поступку.⁸ Када се рангирају нападне вредности у ове две ситуације очигледно је да су у овој другој ситуацији угрожена добра веће вредности. Међутим, није разумно оправдано изложити грађанско правној санкцији радњу судије која је донета у вршењу службе, а не примарно са намером да се нападне част угледа, достојанство личности односно друга права личности.

Код одговора на питање да ли је стручна односно вредносна оцена исказана у одлуци о избору водила повреди части и угледа или је тек само била погрешна, треба поћи од чињенице да је ту одлуку донео надлежни орган да је он у присуству назначених разлога био овлашћен да изрекне такав суд.

б) Са субјективне стране циљ доношења такве одлуке није био усмерен да се повреди систем вредности који *in concreto* судија има о себи или ко-

⁷ Лице према коме је одбијена оптужба због одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења нема право на накнаду штете због повреде угледа (Врховни суд Србије Рев. 4528/96 од 13.11.1996. године)

⁸ Видети одредбу члана чл. 584. до 595. Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013)

ји друга лица о њему имају. Само доношење одлуке о неизбору судије није имало за циљ да произведе последицу у виду повреде назначених вредности. О томе се изјашњава и правна пракса у истоврсним ситуацијама.⁹

Од тога треба разликовати случај изласка из оквира овлашћења који чине садржај надлежности назначеног органа. Тада погрешка није само повреда права на правично суђење, већ има за циљ да се повреде назначене вредности неизабраног судије. Да би се извео тај закључак морају се показати и доказати чињенице које дају потврдан одговор на постојање таквог понашања и да је њихов циљ био да се повреди част, углед и достојанство конкретног оштећеног.¹⁰ То је ситуација када излазак из оквира

⁹ Ево примера из судске праксе: "У конкретном случају повреда права тужиоца није продукт шикане, злоупотребе права или другог малициозног поступка, с обзром да у поступку поништаја решења ниједан од ових услова није доказан, нити је из тих разлога решење поништено. Такође, код тужиоца није постојао озбиљан поремећај психичке равнотеже, а што проистиче из налаза и мишљења вештака неуропсихијатра да код тужиоца постоји појачана напетост, нерасположење и осећај да га људи из радне средине избегавају (а истовремено тужилац и не ради јер је на боловању од 05.02.2003. године до 10.06.2006. године). Нити повреда части, нити повреда угледа тужиоца ничим није доказана. Тужиоцу не припада право на накнаду за претрпљене душевне болове услед незаконитог распоређивања, јер је његова сатисфакција у томе што је правноснажном судском одлуком поништено решење којим је тужилац разрешен дужности директора за правне и економске послове и распоређен на радно место дипл.правник, а посебно имајући у виду да је тужилац распоређен на радно место које је у складу са његовом стручном спремом дипл.правника. (Пресуда Окружног суда у Новом Саду Гж.5582/06 од 30.11.2006. Билтен Окружног суда у Новом Саду број 11/2007 Интермекс Београд аутор сенценце Сања Гојковић стручни сарадник);

У Пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Гж-4126/10 од 05.01.2011. године заступа се исти став: "Чињеница да се име тужиоца коме је иначе изречена мера престанка радног односа и покренут кривични поступак који још није окончан, а поводом догађаја интерпретираних у наведеном саопштењу, нашло у оквиру наведеног чланка заједно са његовом фотографијом, у мноштву имена других лица и њихових фотографија поводом интерпретације докумената надлежног државног органа, није истовремено и доказ супротно закључку првостепеног суда да је тужилац објављивањем спорног текста означен као корумпирани полицајац и да је прејудиицирана његова кривица као извршиоца кривичног дела и да му је на такав начин повређена част и углед, да је омаловажена његова личност, да је трпео понижења, као и његова породица и да му са тог разлога следује досуђена новчана сатисфакција;

¹⁰ О овоме и ова судска одлука цитирана у изводу: У конкретном случају повреда права тужиоца није продукт шикане, злоупотребе права или других малициозних поступака, с обзиром да у поступку поништаја решења о нераспоређивању ниједан од ових услова није доказан нити је из тих разлога решење поништено (Пресуда Окружног суда у Но-

надлежности није само погрешка већ је та радња извршена са циљем да се повреде назначена нематеријална добра. Подразумева се да то потврђује конкретни догађај и чињенице из његовог садржаја.

Да би се овде остварио основ за грађанско правну одговорност оштећени коме је проузрокована нематеријална штета по неком од назначених основа мора бити индивидуално препознат као лице чије су вредности о себе или других о њему повређене.¹¹

Коначно објављивањем одлуке о поништавању одлуке о неизбору и избору тих лица за судију остварена је натурална реституција али и јавности учињено доступним сазнање да су одлуке о неизбору биле правно погрешне и чињенично без основа. Тако је остварен и одговарајући вид сатисфакције. Тако је остварена и позитивна рехабилитација.

Посебно о изјавама чланова Високог савета судства

Изјаве у јавним гласилима чланова Високог савета судства су основ за грађанско правну одговорност Републике због повреде части и угледа незабраног судије ако се остваре кумулативни услови:

- да су дате у име органа;
- да њихов садржај излази изван оквира остваривања права на информацију од јавног значаја и да не исказује само вредносни и стручни суд о незабраном судији који је већ исказан у садржају одлуке о неизбору (тада се ради о презентацији одлуке и ништа више од тога);

вом Саду Гж. 5582/06 од 30.11.2006, Билтен судске праксе Окружног суда у Новом Саду број 11/2007 Интермекс аутор сентенце Сања Гојковић струћни сарадник)

¹¹ На значај те чињенице указује и ова судска одлука: Нису од значаја наводи жалбе да су новинари туженог за наведену информацију сазнали од сведока А. К. која је била бивши радник Централног затвора, а имајући у виду да је она приликом давања исказа то порекла наводећи да није видела да је неки притвореник предао тужиоцу сат, као и да је исти омогућио уношење мобилних телефона, те да јој је суд правилном оценом доказа поклатио своју веру. Такође, нису основани ни наводи жалбе да наведеним текстом није повређена част и углед тужиоца због тога што није поменут својим пуним именом и презименом, а имајући у виду да је и по налажењу овог суда у тексту објављено довољно података да се тужилац идентификује, јер је поред имена и почетног слова и презимена означена и функција коју је обављао у време објављивања спорног чланка у установи у којој је запослен."

(Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж1. 5512/2012(1) од 19.9.2012. године Параграф лекс)

– да се у тој изјави износе за ту намену непотребне вредносне квалификације које су по свом садржају способне да доведу до повреде назначених нематеријалних добара;

– да се на основу садржаја изјаве може препознати њено персонално ограничење на одређено лице као оштећеног или да је персонално без ограничења тако да се односи на све судије;

– да те изјаве нису биле потребне са становишта разумно потребне информације.

То је у складу са основом ослобођења одговорности прописаног одредбом члана 82. Закона о јавном информисању новинара, одговорног уредника и правног лица које је оснивач јавног гласила.

Употреба исказа: да су неке неизабране судије вршиле одређене противправне или неморалне радње сама по себи није довољна за закључак да то важи за све неизабране судије. Није јасно зашто би судија у питању себе препознао у том исказу или зашто би други који га познају извели на основу те информације закључак да се управо о њему ради. Други је случај када је таква негативна вредносна конотација употребљена са значењем на све неизабране судије. Тада под осталим претходно назначеним условима те негативне вредносне конотације могу се узети у обзир код одговора на питање да ли постоји или не повреда назначених нематеријалних добара.

Mutatis mutandis исто важи и када се износе такве негативне вредносне квалификације о одређеном судији на сајту Високог савета судства које прелазе оквир разумно прихватљивих разлога које служе намени коју закон захтева и одговарају правилима демократског друштва.

Објављене информације које нису изјаве чланова Високог савета судства

Послодавац не одговара за повреду части и угледа која је настала због нетачне и непотпуне или неистините информације. Тада постоји солидарна одговорност новинара, одговорног уредника и правног лица које је оснивач јавног гласила. О томе сведочи одредба члана 80. Закона о јавном информисању.¹² У присуству ових разлога не може се правно основа-

¹² Према одредби члана 80. Закона о јавном информисању чији је наслов Солидарна одговорност: Новинар, одговорни уредник и правно лице које је оснивач јавног гласила

но образовати основ грађанскоправне одговорности Републике Србије за објављену нетачну, непотпуну или неистиниту информацију у јавном гласилу. Тврдити супротно значи погрешно помешати ауторе противправне радње која је узрок повреде назначених нематеријалних добара.

који су пре објављивања с пажњом примереном околностима могли утврдити неистинитост или непотпуност информације, солидарно одговарају за материјалну и нематеријалну штету проузроковану објављивањем информације.

Иста обавеза постоји када је штета проузрокована недопуштеним објављивањем истините информације (из приватног живота, пребацивање за извршено кривично дело и друго), као и у другим случајевима недопуштеног објављивања информација.

О томе се изјашњава и ова Одлука Уставног суда: Одлучујући о жалби тужиле, Апелациони суд у Београду је 30. децембра 2010. године донео оспорену пресуду Гж1.5515/10, којом је одбио жалбу као неосновану и потврдио првостепену пресуду. У образложењу оспорене другостепене пресуде је, поред осталог, истакнуто: да је првостепени суд на правилно и потпуно утврђено чињенично стање правилно применио материјално право и да је супротно наводима жалбе, правилно првостепени суд закључио да у конкретном случају не постоји одговорност туженог и да зато тужила нема право на новчану накнаду нематеријалне штете због незаконитог удаљења са посла и претрпљеног страха због неизвесне будућности, у смислу одредбе члана 200. Закона о облигационим односима, јер су дисциплински органи овлашћени да спроведу дисциплински поступак у коме важи претпоставка невиности, а делимичном пресудом Првог општинског суда у Београду П. 2423/2004 од 20. јуна 2005. године је тужила враћена на рад, чиме је она доживела сатисфакцију због незаконитог престанка радног односа, те дисциплинске одлуке туженог нису могле произвести повреду угледа и части, односно страх као афективну реакцију на овај догађај; да тужени не може да одговара за нетачну вест из разлога што он није аутор текста, нити аутор информације, нити оснивач медија у коме су те информације објављене; да је тачно да је спорну фотографију сачинила надлежна служба туженог, али да другостепени суд налази да је фотографија истакнута у унутрашњем делу портирнице управо из разлога како би портيري могли знати којим лицима је престао радни однос ради спречавања уласка неовлашћених лица у погон; да нема узрочно-последичне везе између радњи туженог који је спровео дисциплински поступак против тужиле и информација објављених путем медија где је тужила означена као један од организатора штрајка. И даље:" Будући да се оспорене пресуде заснивају на уставноправно прихватљивом тумачењу материјалног права и да подносиатеља уставне жалбе није тражила да се одлука по овој уставној жалби објави у "Службеном гласнику Републике Србије", Суд је, у смислу одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, нашао да не постоји начин на који би се остварило правично задовољење подносиатељке због повреде њеног права на правично суђење." (Одлука Уставног суда Уж.4642/2011 од 20.01.2014. године)

Од тога треба разликовати основ ослобођења одговорности ових лица прописан одредбом члана 82. Закона о јавном информисању.¹³ То је случај када је остварена материјална претпоставка да је неистинита или непотпуна информација верно пренета из поступка или из документа надлежног државног органа. У том смислу одговорност за повреду части и угледа односно достојанство личности не сме правазилазити стварно изговорено односно на други начин материјално исказано поштујући и правило да нико не може бити сматран одговорним за изјаве и тврдње које су изнела друга лица.¹⁴

(Правно схватање усвојено једногласно на заједничкој седници Апелационих судова и то: Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Нишу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 11. дана 2014. године у просторијама Апелационог суда у Новом Саду).

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА КОД ТУЖБЕ ЗАПОСЛЕНОГ ПОДНЕТОЈ ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

По тужби запосленог поднетој по Закону о спречавању злостављања на раду искључиво је пасивно легитимисан послодавац.¹⁵

Из образложења:

Одговор на правно питање пасивне легитимације у спору ради спречавања злостављања на раду даје на потпун и прецизан начин одредба члана 29. овог закона. Према њеном садржају: Запослени који сматра да је изложен злостављању од стране послодавца са својством физичког лица или одговор-

¹³ Видети одредбу члана 82. Закона о јавном информисању која гласи: Новинар, одговорни уредник и правно лице које је оснивач јавног гласила не одговарају за штету ако је неистинита или непотпуна информација верно пренета из јавне скупштинске расправе или јавне расправе у скупштинском телу или из судског поступка или из документа надлежног државног органа.

¹⁴ Пресуда у случају Стојановић против Хрватске (Представка број 23160/09 19. септембар 2013. објављена у часопису Људска права у Европи, Правни билтен број 4/2013, стр. 24/7)

¹⁵ Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС" бр. 36/2010). У тексту: Закон

ног лица у правном лицу може против послодавца да поднесе тужбу пред надлежним судом у року из члана 14. став 2. овог закона.

Право да поднесе тужбу против послодавца због злостављања на раду или у вези са радом има и запослени који није задовољан исходом поступка заштите од злостављања код послодавца, у року од 15 дана од дана достављања обавештења, односно одлуке из члана 20. ст. 2. и 3. и члана 23. овог закона.

Тужбом из ст. 1. и 2. овог члана не може се побијати законитост појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима запосленог из радног односа. Против тог акта запослени има право на судску заштиту - у складу са посебним законом којим је прописана судска заштита.

Спор из ст. 1. и 2. овог члана јесте радни спор.

Ако овим законом нису предвиђена посебна правила, у споровима за остваривање судске заштите због злостављања на раду или у вези са радом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује парнични поступак.

Кључни искази из ове норме су: запослени који сматра да је изложен злостављању на раду, право да поднесе тужбу, против послодавца. Прва два исказа дају одговор на питање ко је титулар права на подношење ове тужбе док последњи исказ даје одговор на питање против кога се подноси тужба. Пасивно легитимисан је искључиво послодавац, док активну легитимацију има запослени који сматра да је изложен злостављању.

При томе за одговор на ово питање ирелевантно је да ли је у поступку интерне заштите који је иницирао запослени који сматра да је изложен злостављању послодавац активирао поступак утврђивања одговорности мобера и донео одговарајућу одлуку.

Словом Закона је изричито из предмета заштите од злостављања изостављено право на тужбу запосленог који сматра да је изложен злостављању против појединачног акта којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима запосленог. О томе се решава по посебном закону за судску заштиту, као о појединачном праву запосленог. У том значењу и исказ из одредбе члана 29 став 3. који гласи: тужбом из ст. 1. и 2. овог члана који гласи: не може се побијати законитост појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима запосленог из радног односа. Против

тог акта запослени има право на судску заштиту - у складу са посебним законом којим је прописана судска заштита.¹⁶

Законски разлог овог решења је у обавези послодавца да створи услове за здраву и безбедну средину и с тим у вези организује рад којим се спречава појава злостављања на раду-аргумент из одредбе чл. 4. овог закона. При томе се не искључује право на тужбу ради накнаде штете запосленог који се нашао у овој ситуацији, али као оштећеног против штетника-лица које је непосредни извршилац радњи из истог чињеничног догађаја као на пример по основу повреде части, угледа односно права личности, али не по овом Закону.

(Правно схватање усвојено једногласно на заједничкој седници Апелационих судова и то: Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Нишу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 11. априла 2014. године у просторијама Апелационог суда у Новом Саду)

КОЕФИЦИЈЕНТ ЗАПОСЛЕНОГ НА ПОСЛОВИМА ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

Запослени на пословима возача санитетског возила у здравственој установи није здравствени радник, ни здравствени сарадник у смислу Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13) због чега нема право на коефицијент 13,58 и да му се применом коефицијента за обрачун плата здравственим радницима који је утврђен Уредбом о коефицијенти-

¹⁶ У том се у теорији наводи и ово: "Послодавац је пасивно легитимисан у поступку за остваривање судске заштите због злостављања на раду и само он може бити тужени у том спору без обзира ко је извршилац злостављања (одговорно лице, односно предузетник или запослени, односно група запослених). Да се тужба подноси само против послодавца изричито је наведено у Закону о спречавању злостављања на раду (члан 29 став 1. и 2.) и посебно наглашено да послодавац одговара за штету коју одговорно лице или запослени проузрокују другом запосленом вршећи злостављање (члан 9 став 1.)"; Цитирано према чланку "Правна заштита због злостављања на раду (МОБИНГА)" аутора Лидије Ђукић. Чланак је објављен у "Билтену Врховног касационог суда" број 3/2012 стр.129

ма за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама обрачуна плата ("Службени гласник РС" бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02...11/12).

Стога није ништава одредба уговора о раду, односно његовог анекса којом је запосленом на пословима возача санитетског возила утврђен коефицијент за обрачун плате у складу са чланом 2 тачка 13 Уредбе.

Из образложења:

Према садржају правилника о систематизацији радних места код послодавца здравствених установа по правилу за обављање послова радног места возач санитетског возила прописани су услови – III или IV степен стручне спреме, KB возач, положен испит за возача Б, Ц и Д категорије. Правилником је предвиђено да возач санитетског возила обавља послове: да по писменом налогу ординирајућег доктора, доктора из Службе хитне медицинске помоћи и референта за саобраћај врши превоз болесника, при чему води бригу о болеснику током транспорта, смештаја у болницу, специјалистичког прегледа и превоза до здравствене установе или стана болесника, врши по потреби превоз здравствених радника за пружање услуга у стану болесника, превози медицинску документацију и осталу документацију у Службу заједничких послова из здравствених станица и обрнуто, односи материјал на лабораторијске анализе у надлежну здравствену установу, свакодневно одржавање чистоће и исправности возила, обавезно остављање возила у исправном стању и напуњеног горивом, у сарадњи са референтом за саобраћај у случају већих кварова на возилу предузима мере за што бржу оправку у надлежном сервису, води бригу о редовном сервисирању санитетског возила, води посебну књигу у коју уноси датуме прања кола, подмазивања, промене гума, уља, пређене километраже, утрошка горива и бонова за гориво, по пријему путног налога и извршене вожње уписује податке, непосредно сарађује са референтом за саобраћај и придржава се плана и програма (распореда вожњи и радног времена) које сачини референт за саобраћај, сачињава недељни извештај о пређеној километражи.

Сви возачи екипе хитне медицинске помоћи мимо уговореног делокруга брину се и о инсталираном систему за оксигенизацију односно давање кисеоника, управљају светлосно-звучном сигнализацијом у возилу и у поступку медицинског збрињавања пацијената обављају послове које им наложи дежурни лекар екипе. У поступцима реанимације односно

оживљавања пацијената при масажи срца и давању вештачког дисања, возач по налогу дежурног лекара врши вентилирање амбу-балоном, износи сет за интубацију, дефибрилатор и носила.

Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 44/01... 91/2010) донела је Влада РС на основу Закона о платама запослених у јавним службама. Одредбом члана 2. тачка 13. Уредбе утврђени су коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама.

Одредбом уговора о раду, односно његовог анекса утврђен је припадајући коефицијент за обрачун и исплату плате за рад на пословима возача санитетског возила, у складу са Уредбом.

Послодавац је служба која обавља делатност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана, која обухвата спровођење мера и активности здравствене заштите које се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу здравствених технологија, користе за очување и унапређење здравља људи, дакле обавља здравствену делатност. Мере и активности здравствене заштите морају бити засноване на научним доказима, односно морају бити безбедне, сигурне и ефикасне и у складу са начелима професионалне етике. Ради се о здравственој служби коју чине здравствени радници, односно здравствени сарадници који обављају здравствену делатност у складу са Законом о здравственој заштити.

Здравствени радници према Закону о здравственој заштити су лица која имају завршен медицински, стоматолошки, односно фармацеутски факултет, као и лица са завршеном школом здравствене струке, која непосредно као професију обављају здравствену делатност у здравственим установама или приватној пракси под условима прописаним овим законом. Здравствени сарадници према закону су лица са средњом, вишом, односно високом стручном спремом која обављају одређене послове здравствене заштите у здравственој установи, односно приватној пракси. Дакле, завршени медицински, стоматолошки, фармацеутски факултет, завршена школа здравствене струке и непосредно као професија обављање здравствене делатности одређују здравственог радника и тиме се он разликује од здравственог сарадника.

Закон о здравственој заштити поред тога што даје дефиницију здравственог радника, набраја здравствене раднике у зависности од степе-

на стручне спреме. Тако су здравствени радници доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут медицински биохемичар – са завршеним одговарајућим факултетом здравствене струке, други здравствени радник – са завршеном одговарајућом високом, вишом, односно средњом школом здравствене струке.

Закон прописује обавезу здравствених радника да здравствену делатност обављају у складу са важећом здравственом доктрином и у складу са кодексом професионалне етике. Одредбом члана 173 Закона о здравственој заштити забрањено је обављање здравствене делатности од стране лица која се у смислу овог закона не сматрају здравственим радницима и здравственим сарадницима.

Услов за обављање послова возача санитетског возила није завршена школа здравствене струке, нити возач обавља непосредно као професију здравствену делатност, а у опису његових послова није, нити може бити пружање медицинске помоћи с обзиром на стручну спрему коју има. Зато возач није здравствени радник у смислу Закона о здравственој заштити па се при обрачуну плате не може применити коефицијент утврђен за здравствене раднике.

Извршиоци на пословима возача по слову закона не могу обављати здравствену делатност ради чега и у случају да стварно врше послове из њеног садржаја они то чине противправно и из тога не могу извући корист.

(Правно схватање усвојено једногласно на заједничкој седници Апелационих судова и то: Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Нишу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 11.04.2014. године у просторијама Апелационог суда у Новом Саду).

ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА ОСНОВНИХ СУДОВА



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
Су. II-17-16/14
05.12.2014. године
Н и ш

I

**Закључци усвојени на седници Кривичног одељења
Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 16. и
17.04.2014. године, усаглашени са закључцима
Кривичног одељења Врховног касационог суда
на састанку Кривичног одељења Апелационог суда
у Нишу дана 01.12.2014. године**

**1. НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
НА ОДЛУКЕ КРИВИЧНОГ ВЕЋА**

(чл. 21. ст. 4. ЗКП у вези чл. 23. Закона о уређењу судова)

О жалбама на решење КВ већа основног суда одлучује непосредно виши суд. Конкретно, ако је одбијена молба осуђеног за условни отпуст са издржавања казне затвора на коју је осуђен пресудом основног суда, за кривично дело за које је прописана казна затвора до 5 година, о жалби одлучује виши суд, а у осталим случајевима одлучује апелациони суд. Наведени критеријум тиче се и решења о "брисању осуде" или "спајања казни" али се не односи на одлуку о "приговору" тј. одговору на оптужницу, обзиром да у скраћеном поступку (кривична дела за која је као главна казна прописана новчана казна или казна затвора до 8 година) оптужни акт је оптужни предлог, а не оптужница.

2. ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА

(чл. 422. ст. 3. ЗКП)

Када је током трајања главног претреса дошло до застарелости кривичног гоњења или друге трајне процесне сметње за вођење кривичног поступка, претресно веће или судија појединац, донеће пресуду којом се оптужба одбија, на основу чл. 422. тач. 3. ЗКП.

3. КОНОПЉА КАО ОПОЈНА ДРОГА

(чл. 246. КЗ)

Врста и варијетет конопље (рода *cannabis*), која може да садржи више од 0,3% ТХЦ, подлеже кривичној инкриминацији код кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. Кривичног законика.

4. САДРЖИНА ИЗРЕКЕ ПРЕСУДЕ

(чл. 428. ЗКП)

Изрека пресуде садржи радњу извршења кривичног дела које је стављено на терет оптужним актом овлашћеног тужиоца, док друге алтернативне радње из диспозитива кривичног дела које нису обухваћене радњом извршења, не могу бити део изреке пресуде.

5. ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРИТВОРА

(чл. 215. ст. 1. ЗКП)

Одредбом чл. 215. ст. 1. ЗКП, прописано је да се окривљени може задржати у притвору на основу решења судије за претходни поступак највише до три месеца, рачунајући од дана лишења слободе, али се не прописује на колики период се притвор одређује по донетом конкретном решењу. Обзиром на другу реченицу чл. 215. ст. 1. ЗКП, која прописује обавезу судије за претходни поступак да по истеку сваких 30 дана испита да ли још постоје разлози за притвор и да донесе решење о укидању или продужењу притвора, јасно је да се у конкретном решењу притвор одређује на период до 30 дана.

6. ИЗУЗЕЋЕ ИСТРАЖНОГ СУДИЈЕ ОД СУДИЈСКЕ ДУЖНОСТИ

(чл. 37. ст. 1. тач. 4. ЗКП)

Судија који је као истражни судија издао наредбу на основу чл. 504е. Законика о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 70/01 и 60/02 и "Службени гласник" РС бр. 58/04, 85/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09 и 76/10), не може да поступа у истом предмету као председник кривичног већа и по новом ЗКП ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, бр. 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013), јер је одредбом чл. 37. ст. 1. тач. 4. ЗКП, који одговара одредби чл. 40. тач. 4. ранијег ЗКП, у погледу предузетих радњи од стране истражног судије односно судије за претходни поступак, прописано да у тој ситуацији судија мора бити изузет од судијске дужности.

7. ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ

(чл. 51. у вези чл. 603. ЗКП)

У случају када је оштећени као тужилац поднео захтев за спровођење истраге о коме није одлучено, до ступања на снагу новог ЗКП (01.10.2013. године), у том случају поднети захтев за спровођење истраге се има сматрати приговором у смислу одредбе чл. 51. ЗКП, а у случају када је оштећени као тужилац поднео оптужни акт пре наведеног датума, он својство тужиоца задржава, без обзира на ступање оптужног акта на правну снагу.

8. ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

(чл. 32. ст. 1. ЗКП у вези чл. 23. ст. 3. Закона о уређењу судова)

Одредба члана 24. ст. 2. Закона о уређењу судова је у колизији са одредбом члана 32. ст. 1. новог ЗКП-а, као последица ранијег решења да су се апелациони судови у односу на основне и више судове јављали као непосредно виши, а променом надлежности у новом Закону о уређењу судова то више није случај. Наиме, одредбом члана 24. ст. 2. Закона о уређењу судова, прописано је да апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова када су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари. Одредба члана 32. ст. 1. ЗКП, прописује да када је надлежан суд из правних или стварних разлога спречен да поступа, дужан је да о томе извести непосредно виши суд,

који ће решењем одредити други стварно надлежан суд на свом подручју. Проблем се јавља јер се виши суд у односу на основни суд јавља као непосредно виши суд за кривична дела за која је законом предвиђена новчана казна или казна затвора до 5 година, а за остала кривична дела непосредно виши суд је апелациони суд. С обзиром да је одредбом члана 23. ст. 3. Закона о уређењу судова, одређено да виши суд врши и друге послове одређене законом, то значи да у смислу чл. 32. ЗКП, као непосредно виши суд, за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, виши суд одлучује о преношењу месне надлежности основних судова на свом подручју.

9. СТРУЧНИ САВЕТНИК

(чл. 125. ЗКП)

Фаза поступка до које може бити ангажован стручни саветник ограничена је правилима о трајању доказног поступка на главном претресу и о могућности предлагања доказа на главном претресу. То значи да стручни саветник може бити ангажован уз услове прописане одредбама чл.350, 356. и 395. ЗКП, до завршетка вештачења и окончања доказног поступка на главном претресу. Саветник може бити ангажован и касније у смислу чл. 410, 411. и 414. ЗКП, у случају измена и проширења оптужнице, и накнадне допуне доказног поступка.

10. НОВО ВЕШТАЧЕЊЕ

(чл. 124. ЗКП)

На основу чл.124 ЗКП, јасно су прописани услови за понављање вештачења и то ако је налаз вештака нејасан, непотпун, погрешан, и противречности сам са собом или са околностима у којима је вештачено или се појави сумња у његову неистинитост и ако је мишљење нејасно и противречно. У том случају колико се наведени недостаци не могу да отклоне поновним испитивањем вештака или допунским вештачењем тада може да се одреди други вештак који ће обавити ново вештачење. То значи као у одговору првостепеног суда да без покушаја отклањања недостатака обављеног вештачења не може бити одређено ново вештачење.

11. ОЦЕНА ПОСРЕДНИХ ДОКАЗА

(чл. 16. у вези чл. 419. ЗКП)

Индиције су чињенице на основу којих се посредно изводи закључак о одлучним чињеницама и утврђује постојање или непостојање чињенице која је предмет доказивања. Да би пресуда била заснована на посредним доказима неопходно је да ти докази - индиције са чињеницама које се утврђују у току поступка, стоје у логичкој вези тако да закључак који се из њих изводи указује да оне представљају целину у поступку закључивања на основу које се искључује могућност другачијег начина утврђивања чињеница које су предмет доказивања. У кривично правном смислу посредни докази указују на постојање кривичног дела и на ближу или даљу везу између кривичног дела и неког лица као могућег извршиоца. Уколико постоји више индиција – посредних доказа наведеног квалитета, које чине затворени круг логично повезаних чињеница на основу њих се може са већом или мањом вероватноћом закључити да ли је кривично дело извршено или није и да ли се одређено лице појављује као извршилац и на основу резултата оцене доказа донети пресуда.

12. NE BIS IN IDEM

(чл 4. ЗКП)

а) Када је правноснажним решењем прекршајног суда обустављен поступак због наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка, а ради се о идентичном чињеничном опису дела пред кривичним судом и поред тога што је претходно донето решење о прекиду прекршајног поступка до правноснажног окончања кривичног поступка, ради се о правноснажно пресуђеној ствари.

б) Нема места примени института "ne bis in idem" због кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из чл. 344А Кривичног законика, у ситуацији када је окривљеном због истог чињеничног описа у дисциплинском поступку, пред комесаром за такмичења при Фудбалском савезу општине донета коначна одлука којом се окривљени кажњава забраном играња у трајању од једне године, јер се ради о дисциплинском поступку у коме се изричу дисциплинске мере које немају кривичну конотацију, а за "пресуђену ствар" природа дела заједно

са тежином казне треба да доведу осуду лица у сферу кривичног поступка, што овде није случај.

13. ПРИМЕНА ОДРЕДБЕ ЧЛ. 34. У ВЕЗИ ЧЛ. 385. ЗКП

Уколико је након укидања првостепене пресуде дошло до измене Кривичног законика у погледу запрећене казне по којој је надлежан за суђење суд нижег ранга, а поступак није отпочео, надлежан за поступање је нижи суд, а уколико је виши суд започео поступак након укидања пресуде, исти се неће огласити ненадлежним за поступање, већ ће наставити поступак и донети одлуку, имајући у виду да у смислу чл. 385. ст.1. ЗКП главни претрес почиње доношењем решења да се главни претрес одржи.

14. ПРИТВОР У СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

(чл. 498. ЗКП)

У скраћеном поступку пре подношења оптужног предлога, о одређивању притвора одлучује судија појединац, а по жалби на решење о одређивању притвора одлучује веће из чл.21. ст.4. ЗКП (чл.498. ст.2. и 3. ЗКП). Од подношења оптужбе до изрицања првостепене пресуде у скраћеном поступку, веће из чл.21. ст.4. ЗКП испитује на сваких 30 дана да ли постоје разлози за притвор, а о жалби на ово решење одлучује веће непосредно вишег суда.

15. ИСКАЗ СВЕДОКА ПРЕД ОВЛАШЋЕНИМ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА

(чл. 229. ст. 4. у вези чл. 499. ст. 2. ЗКП)

Искази сведока дати на записнику пред овлашћеним службеним лицима Полицијске управе, по овлашћењу јавног тужиоца (чл.499. ст.2. у вези чл.299. ст.4. ЗКП) могу се користити у доказном поступку ако су дати у складу са одредбама ЗКП, с тим што сагласност судије за претходни поступак није потребна.

16. ОДЛУКА О МЕРИ БЕЗБЕДНОСТИ

(чл. 424. тач. 5. ЗКП)

Навођење броја пресуде у пресуди у којој се изриче мера безбедности забране управљања моторним возилом није потребно.

17. ПРИЗНАЊЕ САОКРИВЉЕНОГ

(чл. 88. ЗКП)

Признање једног од саокривљених обавезује суд да изведе и друге доказе и провери његово признање у односу на друге саокривљене, што значи да се начелно осуђујућа пресуда може засновати на признању једног саокривљеног.

18. ПРАВО ОШТЕЋЕНОГ НА ЖАЛБУ

(чл. 433. ст. 4. ЗКП)

Када се окривљени и јавни тужилац одрекну права на жалбу, а оштећени се тог права није одрекао, у делимично образложеној пресуди, суд ће оштећеног упутити да може изјавити жалбу на одлуку о трошкови-ма кривичног поступка и имовинско правном захтеву (чл.429. ст.3. тач.3. у вези чл.433. ст.4. ЗКП).

19. ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА НА ЖАЛБУ

(чл. 429. и 434. ЗКП)

Окривљени коме је изречена казна затвора у трајању до три године након потпуног признања извршења кривичног дела и када пресуда не садржи образложење, може се одрећи права на жалбу, али тек када му пресуда буде достављена.

20. ДОКАЗНА СНАГА ИСКАЗА ЛЕКАРА

(чл. 93. у вези чл. 91. ЗКП)

Пресуда се може заснивати на исказу лекара као сведока уколико се не ради о лекарској тајни у смислу чл. 93. ЗКП и уколико не доводи у питање право сведока из чл. 94. ЗКП, али не може да се заснује само на том исказу, већ је потребно да постоје и други докази, што зависи од конкретног предмета.

21. ПРИЗНАЊЕ ОПТУЖЕНОГ

(чл. 88. ЗКП)

Пресуда се може заснивати на признању оптуженог, уколико је признање дато у смислу одредбе чл.88. ЗКП.

22. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ПРИТВОРА

(чл. 213. ст. 2. ЗКП)

Одредбом чл. 213. ст. 2. ЗКП, прописано је шта све треба да садржи решење о одређивању притвора, која се аналогно примењује и код доношења решења о продужењу притвора. Изрека решења већа из чл. 21. ст. 4. ЗКП о продужењу притвора мора да садржи име и презиме оптуженог, којим решењем је притвор одређен, од када се исти рачуна, када је последњи пут продужен, законски основ продужења притвора и до када по решењу има најдуже трајати. Није неопходно да изрека решења садржи одредбу да је веће дужно да и без предлога странака по истеку сваких 60 дана испита да ли још постоје разлози за притвор и да донесе решење о продужењу или укидању притвора, јер исти непотребно изреку оптерећује. Веће је у обавези да пре истека одређеног рока притвора, изврши контролу по службеној дужности, с тим што се у случају продужења притвора по новом решењу, притвор продужава од дана доношења новог решења, а не од дана истека притвора по претходном решењу.

23. САДРЖИНА РЕШЕЊА О ПРИТВОРУ

(чл. 213. ст. 2. ЗКП)

Одредбом чл. 213. ст. 2. ЗКП, прописано је шта све треба да садржи решење о одређивању притвора. Изрека решења судије за претходни поступак о одређивању притвора мора да садржи све личне податке окривљеног, законски основ одређивања притвора, од када се исти рачуна и до када по решењу има најдуже трајати. Није неопходно да изрека решења треба да садржи и образложење законског основа за одређивање притвора. Одредбом чл. 215.ст. 1. ЗКП прописано је да се на основу решења судије за претходни поступак окривљени може задржати у притвору највише 3 месеца од дана лишења слободе и како изрека решења треба да гласи, али при том треба имати у виду одредбу чл. 210.ст. 1. и 2. ЗКП, којом је прописано да се притвор може одредити само под условима предвиђеним ЗКП и само ако се иста сврха не може остварити другом мером, те да је дужност свих органа који учествују у поступку да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени налази у притвору, што упућује да притвор треба одређивати у краћим роковима.

24. ДУПЛО ОПТУЖЕЊЕ

(чл. 502. и 503. ЗКП)

Процесна ситуација вођења два истоветна скраћена поступка против истог лица, није околност која трајно искључује кривично гоњење прописана чл. 338. ст. 1. тач. 2. ЗКП, тако да није могуће одбијање оптужбе применом чл. 503. ЗКП. У датој ситуацији потребно је сачекати правноснажно решење по једном предмету, а затим одлучити о пресуђеној ствари, а не применити одредбу чл. 502. ЗКП; јер се не ради о околности која привремено спречава гоњење.

25. ОДБАЧАЈ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

(чл. 502. ЗКП)

Приватну кривичну тужбу због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, треба одбацити по основу чл. 502 ЗКП, јер нема захтева овлашћеног тужиоца.

26. ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА НАРЕДБЕ ЗА ПРЕТРЕСАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА

(чл. 155. ст. 3. ЗКП)

Рок од осам дана од дана издавања наредбе о претресању, који је одређен чланом 155. ст. 3. ЗКП, у коме најкасније може да започне радња претресања, важи и за претресање уређаја за аутоматску обраду података и опреме на коју се чувају или се могу чувати електронски записи, које се врши на основу наредбе суда из чл. 152. ст. 3. ЗКП, а уколико радња претресања не започне у наведеном року, претресање се не може предузети, а наредба ће се вратити суду.

27. ДОСТАВА ПИСМЕНА

(чл. 246. ЗКП)

Одредбом чл. 246. ст. 1. ЗКП прописано је да ако се достављање писмена окривљеном не може извршити на адресу о којој је окривљени обавестио орган поступка, достављач ће оставити обавештење да ће се писмено истаћи на огласној табли и по могућству на интернет страници ор-

гана поступка. По протеку рока од 8 дана од дана истицања писмена сматра се да је достављање извршено. Дакле, није прописано да је достављач дужан да више пута одлази на адресу окривљеног нити да врши било какве провере, а такође није прописано да се провера адресе врши преко полиције. То значи да достављач оставља обавештење како је прописано наведеном одредбом и да се даље поступа по чл.246. ст.1. ЗКП.

28. ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Трошкови предвиђени одредбом чл. 261. ст. 2. тач. 1. до 6. ЗКП, као и нужни издаци постављеног браниоца по службеној дужности, исплаћују се увек унапред из средстава органа поступка, без обзира што је законодавац то пропустио да наведе, међу трошкове који се унапред исплаћују спада и награда вештаку. Коначна наплата ових трошкова на основу пописа унапред исплаћених трошкова, врши се на основу правила предвиђених чл. 262. до 265. ЗКП, у пресуди или решењу које одговара пресуди, када ће бити одређено лице обавезано на њихову исплату или ће бити одређено да ови трошкови падају на терет буџетских средстава.

29. САСТАВ ВЕЋА У СМИСЛУ ЧЛ. 150. СТ. 1. ЗМ

Одредбом чл. 150. ст. 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, прописано је да веће којим председава судија који је стекао посебна знања из области права детета и кривичноправне заштите малолетних лица суди пунолетним учиниоцима кривичних дела прописаних кривичним закоником, ако је оштећени малолетно лице, при чему су тачно наведена кривична дела на која се односи наведена законска одредба. Закон не прави разлику у погледу прописане казне затвора, па стога произилази да се за наведена кривична дела мора судити у већу којим председава судија са лиценцом, док у односу на друга кривична дела која овде нису наведена, ова лиценца није неопходна.

30. ДОСТАВА ЖАЛБЕ НА ОДГОВОР

(чл. 444. ст. 1. ЗКП)

Одредбом чл. 444. ст. 1. ЗКП, прописано је да се примерак жалбе доставља противној странци, која може у року од 8 дана од дана пријема жалбе поднети одговор на жалбу. Одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 9. ЗКП, који се односи на тумачење израза у овом закоником, прописано је да су странке

тужилац и окривљени. Из овога произилази да се жалба окривљеног доставља на одговор јавном тужиоцу, уколико оштећени није супсидијарни тужилац или приватни тужилац, јер обавеза достављања оштећеном није прописана у ЗКП.

31. ОБАВЕЗНА ОДБРАНА

(чл. 74. ЗКП)

Одредбом чл. 74. ст. 1. тач. 2. ЗКП, прописано је да окривљени мора имати браниоца ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна, и то од првог саслушања па до правноснажног окончања кривичног поступка. Дакле, из овога произилази да уколико је обавезна одбрана предвиђена почев од првог саслушања окривљеног, утолико пре је потребно да он има браниоца и приликом уручења и испитивања оптужнице, с обзиром на право да поднесе одговор на оптужницу, што даље значи да ако окривљени није ангажовао браниоца нити се о томе изјаснио, треба му поставити браниоца по службеној дужности.

32. ОБАВЕЗНА ОДБРАНА

(чл. 75. ЗКП)

Одредбама чл. 75. ст. 1. Законика о кривичном поступку прописано је да браниоца може изабрати и пуномоћјем овластити окривљени (или његов законски заступник, брачни друг, сродник по крви у правој линији, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра, хранитељ и лице са којим окривљени живи у ванбрачној или каквој другој трајној заједници живота осим ако се окривљени томе изричито противи). Ставом 2. истог члана прописано је да окривљени може дати браниоцу и усмено пуномоћје изјавом на записник код органа поступка. Из напред наведеног, произилази да писмена изјава окривљеног о томе да ће сам ангажовати браниоца, не представља пуномоћје дато браниоцу, а економичност и ефикасност поступка не утиче на законитост предузетих радњи, па уколико се на позив суда окривљени не изјасни да ће ангажовати браниоца, суд ће поступити сходно чл. 76. ЗКП и у случају обавезне одбране (чл. 74. ЗКП), окривљеном поставити браниоца по службеној дужности.

33. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИТВОРА ПРЕ ПОДНОШЕЊА ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА

(чл. 498. ст. 2. и 3. ЗКП)

Одредбом чл. 498. ст. 3. ЗКП, изричито је одређено да се ради о судији појединцу, а не судији за претходни поступак. За разлику од ранијег ЗКП (Службени лист СРЈ бр. 70/01 и 68/02 и Службени гласник РС бр. 58/04, 85/05 - др. Закон, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 - др. Закон, 72/09 и 76/10), судија појединац је надлежан да одлучује о предлогу за одређивање притвора, јер доношењем решења о одређивању притвора, на основу чл. 7 тач. 3. ЗКП, сматра се да је кривични поступак покренут, па је логично да о притвору одлучује судија пред којим се поступак има водити.

34. ПРИТВОР У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

(чл. 313. ЗКП)

Одлучивање о притвору у поступку закључивања споразума о признању кривичног дела, у смислу чл. 313. ЗКП, када је одлука о притвору део споразума је у надлежности судије за претходни поступак уколико је споразум поднет до потврђивања оптужнице, односно председника већа, уколико је споразум поднет након потврђивања оптужнице, а уколико притвор није део споразума, о њему одлучује веће из чл. 21. ст. 4. у смислу чл. 216. ст. 1. ЗКП.

II

Закључци усвојени на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 23, 24. и 25.09.2014. године, усаглашени са закључцима Кривичног одељења Врховног касационог суда на састанку Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу дана 01.12.2014. године

1. НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА РЕДОВНИХ СУДОВА ПО ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА

а) Законом о извршењу кривичних санкција и Законом о извршењу ванзаводских санкција и мера ("Службени гласник Републике Србије" бр.55/2014 од 23.05.2014. године), који су ступили на снагу 01.06.2014. године, а примењују од 01.09.2014. године, задржана је надлежност председника судова опште надлежности у поступку извршења кривичних санкција, тако што председник основног суда има дужности у смислу чл. 63. (одлучивање о молби за одлагање извршења казне) и чл. 67. (опозив одлагања) Закона о извршењу кривичних санкција, а председник вишег суда има дужности у смислу чл. 33. (одређивање судије за извршење), чл. 64. (одлучивање о жалби на решење по молби за одлагање извршења казне затвора) и чл. 245. (одређивање судије за надзор притвора клада одлучи да тај надзор не врши судија за извршење) Закона о извршењу кривичних санкција.

б) Надлежности у односу на извршење казне затвора у просторијама у којима учинилац станује (кућног затвора) из ранијег Закона о извршењу кривичних санкција ("Сл. Гласник РС" бр.85/2005) са изменама из чл. 174е (Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција "Сл. Гласник РС" бр. 31/2011) и надлежности председника првостепених судова и председника апелационог суда, престају даном почетка примене новог Закона о извршењу кривичних санкција, осим код нерешених предлога за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује, који су поднети до 01.09.2014. године.

в) Одлучивање о издржавању казне затвора у просторијама у којима учинилац станује је у искључивој надлежности првостепеног суда, а изјашњавање о начину контроле ове казне у ситуацији када правноснажном пресудом начин није одређен (чл. 20 Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера), извршење кућног затвора са или без примене електронског надзора, је у надлежности првостепеног суда.

2. ИЗДРЖАВАЊЕ КУЋНОГ ЗАТВОРА СА ИЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАДЗОРА

(чл.20. Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
у вези чл. 424. ст. 4 ЗКП)

Суд је дужан да у правноснажној пресуди одреди да ли ће се казна кућног затвора извршити са или без примене електронског надзора. Када првостепени суд не означи у правноснажној пресуди да ли ће се казна кућног затвора извршавати са или без примене електронског надзора, надлежан првостепени суд је дужан да се без одлагања изјасни о начину извршења казне.

3. ОДБИЈАЊЕ ОПТУЖНОГ АКТА

(чл. 503. ст. 1. ЗКП)

Након укидања првостепене пресуде и враћања списка предмета првостепеном суду на поновно суђење, првостепени суд ће на основу чл. 503 ст. 1 ЗКП, донети решење којим се оптужни предлог односно приватна тужба одбија у ситуацији када је у међувремену наступила застарелост кривичног гоњења.

4. ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА

(чл. 61. и 65. ЗИКС)

Молба за одлагање извршења казне поднета из разлога прописаних у чл. 61. ст. 1. Закона о извршењу кривичних санкција, може да се поднесе у року од три дана од дана пријема налога за извршење казне. Законска одредба из чл. 61. ст. 1. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласник РС бр.55/2014), који се примењује од 01.09.2014. године, је јасна и указује да се молба за одлагање извршења казне затвора може поднети после истека рока од три дана од пријема налога за издржавање ка-

зне, па до дана када осуђени треба да се јави на издржавање казне, из разлога таксативно наведених у ст. 2. овог члана. Из одредбе чл. 65. ст. 2. Закона о извршењу кривичних санкција, произилази да осуђени може више пута да поднесе молбу за одлагање извршења казне.

5. ИЗРИЦАЊЕ КАЗНЕ КУЋНОГ ЗАТВОРА ПРЕМА СТРАНЦУ

(чл. 45. ст. 5. и 6. КЗ)

Страни држављанин који има пријављено боравиште на територији Републике Србије, може издржати казну затвора у кућним условима.

6. ПРИГОВОР НА ОДЛУКУ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА О ДОКАЗНОМ ПРЕДЛОГУ

(чл. 395 ст. 4. ЗКП)

У редовном кривичном поступку, о приговору на одлуку председника већа којим одбија неки доказни предлог одлучује претресно веће, у складу са овлашћењима из чл. 395. и чл. 368. ЗКП или ванпретресно веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП, уколико се одлука доноси ван главног претреса, а у скраћеном поступку поступајући судија.

7. ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

(чл. 32. ЗКП)

Статус судова у Косовској Митровици је стварни разлог из чл. 32. ЗКП, да се надлежан суд обрати непосредно вишем суду, који ће решењем одредити други стварно надлежни суд на свом подручју, да би одлучио о захтеву за понављање кривичног поступка.

8. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИТВОРА ПРЕ ПОДНОШЕЊА ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА

(чл. 498. ЗКП)

Притвор окривљеном пре подношења оптужног предлога може се одредити по чл. 211. ст. 1. тач.1, 2. и 3. ЗКП, а не и по чл. 211. ст. 1. тач. 4. ЗКП.

9. ОДЛУКА О ПРИТВОРУ НАКОН ИЗРИЦАЊА ПРЕСУДЕ

(чл. 425а ЗКП)

Уколико је веће које је изрекло пресуду, из било ког разлога пропустило да донесе одлуку о притвору, а пресуду је објавило, одлуку о притвору доноси веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП, јер судеће веће више није у заседању.

10. РЕШЕЊЕ О ВРАЋАЊУ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИХ ПРЕДМЕТА

(чл. 151. ЗКП)

Решење о враћању привремено одузетих предмета, сходно одлуци о главној ствари, доноси суд који је судио у првом степену, а уколико је он то пропустио, веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП.

**11. ОРГАН ПОСТУПКА НАДЛЕЖАН ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ЈЕМСТВУ**

(чл. 205. ст. 1. ЗКП)

Функционално надлежно за одлучивање о јемству на основу чл. 205 ст. 1 ЗКП, у фази подизања оптужнице до њеног потврђивања, је ван-расправно веће из чл. 21 ст. 4 ЗКП, уколико је у заседању, а уколико није, председник кривичног већа из чл. 21. ст. 4. ЗКП, коме је достављена оптужница.

12. ИСПРАВКА ПРЕСУДЕ

(чл. 234. и чл. 431. ЗКП)

а) Изворник пресуде не може бити исправљан применом одредбе чл. 431. ЗКП. На основу одредбе чл. 431. ЗКП могу бити исправљене само очигледне грешке у писању овереног преписа пресуде било да се исте односе на грешке у писању у самом препису пресуде или се односе на неслагласности између преписа и изворника.

б) Када је у питању исправка изворника пресуде у погледу очигледних грешака у писању, таква исправка би могла бити извршена само сходно одредби чл. 234. ЗКП. Таква исправка се може извршити и након објављивања пресуде па и након израде преписа пресуде и да ЗКП не ограничава и не везује такву исправку за неку посебну фазу поступка, тач-

није не забрањује да се исправка записника о главном претресу изврши и након објављивања пресуде.

в) Уколико дође до очигледне грешке у писању и рачунању и у изворнику и у писаном отпракку, која је очигледна, неспорна и ноторна, могла би се прво извршити исправка изворника пресуде на записнику о главном претресу, применом одредбе чл. 234. ЗКП, а након тога и исправка преписа пресуде тако што би се иста ускладила са изворником применом одредбе чл. 431. ЗКП.

13. ПОСЕБНО РЕШЕЊЕ О ДОЗВОЉЕНОСТИ ИЗВРШЕЊА СУДСКЕ ОДЛУКЕ

(чл. 278. ЗКП)

Веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП је надлежно за одлучивање у смислу чл. 278. ст. 1. ЗКП.

14. NE BIS IN IDEM

(чл. 4. ЗКП)

Чланом 4. Законика о кривичном поступку је јасно дефинисано начело "Ne bis in idem" тиме што је прописано да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен, што подразумева и обуставу после прекида прекршајног поступка.

15. ПРОИЗВОДЊА ОПОЈНИХ ДРОГА

(чл. 246. ст. 1. КЗ)

У законској одредби кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.1. КЗ, инкриминисано је више радњи извршења, које се појављују у два основна облика: неовлашћена производња и неовлашћено стављање у промет опојних дрога или психотропних супстанци. Под производњом опојних дрога у смислу чл.246. ст.1. КЗ подразумева се свака активност којом се из одређеног материјала може добити супстанца или препарат који имају својство опојне дроге. За постојање овог основног облика кривичног дела из чл.246. ст.1. КЗ није од значаја да ли се неовлашћена производња опојних дрога врши ради промета или не, јер из садржине описа законског обележја овог дела

произилази да исти не садржи и услов да се неовлашћена производња врши ради промета.

16. ОБИМ ИСПИТИВАЊА ЖАЛБЕ

(чл. 451. ЗКП)

Уколико је жалба изјављена само по основу битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. ЗКП, без образложења овог основа, пресуда по том основу не може се испитати, сходно чл. 435. ст. 1. тач. 3. ЗКП, па би првостепени суд требало да поступи сходно чл. 436. ст. 2. ЗКП. (одбацити уколико исту не уреди). Ако је ова жалба изјављена у корист оптуженог, тада ће првостепени суд жалбу доставити вишем суду, који ће у смислу чл. 451. ст. 2. ЗКП, испитати пресуду у погледу одлуке о кривичној санкцији (чл. 451. ст. 2. тач. 2. ЗКП). У другој ситуацији, уколико је жалба изјављена и по другим основима, који су на одговарајући начин образложени, жалба ће се испитати по тим основима.

17. ОБИМ ИСПИТИВАЊА ЖАЛБЕ

(чл. 451. ЗКП)

Ако се жалбом не побија чињенично стање у погледу чињеница које су предмет доказивања односно чињеница које чине обележје кривичног дела, односно чињеница од којих зависи примена одредаба кривичног поступка или примена неке друге одредбе кривичног закона, (чл. 83. ЗКП), другостепени суд неће испитивати чињенице на које указује жалба, а које нису предмет доказивања, јер не утичу на правилност и потпуност чињеничног стања, од чега зависи примена кривичног закона

18. ПРИМЕНА ЧЛ. 15. СТ. 4. ЗКП

Другостепени суд не може дати налог да се саслуша сведок чије саслушање није предложено, јер не зна у ком правцу ће сведок сведочити и да ли ће одређивање овог доказа ићи на штету оптуженог. Суд може дати налог странци да предложи допунске доказе или изузетно сам одреди да се такви докази изведу само ако оцени да су изведени докази противуречни или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио у смислу чл. 15 ЗКП. При томе треба имати у виду да су странке везане роковима за предлагање доказа и да одредба чл.350. ЗКП

обавезује странку да доказ предложи најкасније на припремном рочишту. Докази се могу предложити накнадно у току поступка и у жалби, али само уколико се докаже да из оправданог разлога исти нису предложени.

19. ЖАЛБА ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ

(чл. 463. ЗКП)

Сходном применом одредбе чл. 463. ЗКП којим је прописано да је жалба против другостепене пресуде дозвољена само када је другостепени суд преиначио првостепену пресуду којом је оптужени ослобођен од оптужбе и изрекао пресуду којом се оптужени оглашава кривим, жалба је дозвољена и када другостепени суд преиначи пресуду којом се оптужба одбија и изрекне пресуду којом се оптужени оглашава кривим.

20. УСЛОВНИ ОТПУСТ

(чл. 46. КЗ и чл. 567. ст. 1. ЗКП)

Признање оптуженог и изражено кајање треба ценити у склопу свих осталих прописаних услова за пуштање осуђеног на условни отпуст, који се тичу тога да ли је у конкретном случају постигнута сврха кажњавања, односно да ли се осуђени у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна неће учинити ново кривично дело.

21. УСЛОВНИ ОТПУСТ

(чл. 46. КЗ и чл. 567. ст. 1. ЗКП)

Извештај установе у којој осуђени издржава казну дат у поступку одлучивања по молби за условни отпуст, треба да обухвати и мишљење о постигнутим резултатима рада са осуђеним, процену ризика осуђеног и процену о сналажењу осуђеног у постпеналним условима, од којих околности зависи одлука суда о молби.

22. ИЗУЗЕЋЕ ИСТРАЖНОГ СУДИЈЕ

(чл. 37. ЗКП)

Поступање истражног судије у истрази пре 01.10.2013. године је разлог за његово изузеће у првом степену и након ступања на снагу новог ЗКП.

23. СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ОШТЕЋЕНОГ КАО ТУЖИОЦА

(чл. 51. ЗКП)

Оштећени нема својство овлашћеног тужиоца (оштећеног као тужиоца), када је по поуци за преузимање гоњења по одредбама старог ЗКП, гоњење преузео након ступања на снагу новог ЗКП, већ ће се његов оптужни предлог, непосредна оптужница или захтев за спровођење истраге сматрати приговором непосредно вишем тужиоцу у смислу одредбе члана 51. ст. 1. ЗКП.

24. ОДРИЦАЊЕ ОПТУЖЕНОГ ОД ПРАВА НА ЖАЛБУ

(чл. 434. ст. 1, ст. 2. и ст. 3. ЗКП)

а) Уколико оптужени након давања изјаве, одмах по објављивању пресуде којом је осуђен на казну затвора, да се одриче од права на жалбу, изјави жалбу на пресуду која не садржи образложење, жалба се не може одбацили као недозвољена, већ ће другостепени суд одлучити по жалби.

б) Уколико се оптужени након пријема пресуде (која садржи или не садржи образложење), којом је осуђен на казну затвора, одрекао од права на жалбу, онда ће у случају изјављивања жалба бити одбачена као недозвољена, осим уколико није осуђен на казну затвора у трајању од 30 до 40 година.

25. ИЗМЕНА И ПРОШИРЕЊЕ ОПТУЖНИЦЕ

(чл. 409. и чл. 410. ЗКП)

Оштећени као тужилац који је тај статус стекао одбацивањем кривичне пријаве, пре ступања на снагу новог ЗКП, може вршити измену, али не може проширити своју оптужбу за ново кривично дело за које се гони по службеној дужности, јер јавни тужилац није одустао од гоњења, али може проширити оптужбу за кривично дело које се гони по приватној тужби.

26. СВОЈСТВО ОШТЕЋЕНОГ КАО ТУЖИОЦА

(чл. 52. и чл. 58. ЗКП)

Удружење малих акционара не може имати својство оштећеног као тужиоца у кривичном поступку.

Оштећени као тужилац (лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено), који је то право стекао пре 01.10.2013. године, задржава то право односно својство.

27. АДВОКАТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(чл. 63. и чл. 64. ст. 1. тач. 2. Закона о адвокатури и чл.12.Статута
Адвокатске коморе Републике Србије)

Адвокат са легитимацијом Адвокатске коморе Републике Косово не може поступати као бранилац у кривичним поступцима пред судовима у Републици Србији.

28. ОДЛУКА УСЛЕД ЗАСТАРЕЛОСТИ

(чл. 422. тач. 3. ЗКП)

Главни претрес је јединствен, са дозвољеним одступањима прописаним у чл. 388. ЗКП, те је потребно, након отварања главног претреса, донети одбијајућу пресуду у заседању судског већа или поступајућег судије уколико се ради о скраћеном поступку, у смислу чл. 422 тач. 3 ЗКП, када се гоњење не може предузети због застарелости, а не решење о обустави поступка.

29. САСЛУШАЊЕ ОСУМЊИЧЕНОГ

(чл.294 ЗКП)

Потребно је саслушање осумњиченог који је задржан по решењу тужиоца 48 сати, уколико тужилац по саслушању предложи одређивање неке мере за обезбеђивање присуства осумњиченог из чл. 188. ЗКП, без обзира што одредбе чл. 293. и 294. ЗКП то изричито не предвиђају, јер је то у складу са основним људским правима и слободама које су зајемчене Уставом Републике Србије и европском Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

30. ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

(чл. 479. ЗКП)

Када су испуњени услови за понављање поступка по правно-снажној пресуди донетој у одсуству осуђеног, ради се о обавезном по-

нављању поступка у смислу чл. 479. ЗКП, тада је потребно да првостепени суд који је одлучивао у правноснажно окончаном првостепеном поступку одлучи о захтеву за понављање поступка, а затим да у зависности од исхода тог поступка, виши суд који је делегиран за одлучивање по предлогу за одузимање имовине, одлучи у поступку одузимања имовине проистекле извршењем кривичног дела.

31. ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА

(чл. 262. ст. 3. ЗКП)

У смислу чл. 262. ст. 3. ЗКП, о жалби на решење о трошковима поступка истраге у истражном предмету јавног тужиоца, одлучује трочлано веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП, а не судија за претходни поступак. У поступку истраге јавни тужилац је овлашћен да врши исплату трошкова на основу налога за исплату и евиденције у трошковнику, а коначну одлуку о трошковима кривичног поступка доноси надлежан суд.

32. ДОСТАВА ПРЕСУДЕ

(чл. 243. ст. 2. ЗКП)

Пресуда којом је изречена условна осуда може се доставити предајом пунолетном члану домаћинства оптуженог, у складу са чл. 243 ст. 2 ЗКП.

33. ДОСТАВА ПРЕСУДЕ

(чл. 246. ЗКП)

Пресуда којом је оптуженом изречена ефективна казна затвора и коме пресуда није могла бити достављена на адреси о којој је обавестио суд, доставља се на основу чл. 246 ст. 1 ЗКП којим је прописано да ако се достављање писмена окривљеном не може извршити на адреси о којој је окривљени обавестио суд, достављач ће оставити обавештење да ће се писмено истаћи на огласној табли суда и по могућству на интернет страници суда и по протеку рока од 8 дана од дана истицања пресуде, сматра се да је достављање извршено.

34. ВРАЋАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ЈЕМСТВА

(чл. 207. ст. 2. ЗКП)

Положени новчани износ се враћа по укидању решења о јемству или по правноснажном окончању кривичног поступка, у смислу чл. 207. ст. 2. ЗКП, што значи у важећој валути у којој је тај износ готовог новца положен, а то даље значи да је у неким случајевима потребно извршити конверзију датих новчаних средстава у важећу валуту.

35. ТУЖБА И ПРОТИВТУЖБА

(чл. 66. ЗКП)

У складу са одредбом чл. 66. новог ЗКП, дозвољено је да окривљени поднесе противтужбу за било које кривично дело за које се гоњење предузима по приватној тужби у оквиру истог догађаја и по протеку рока из чл. 65. ст. 2. ЗКП, без обзира што је приватна тужба поднета у време важења ранијег ЗКП.

36. СТРАНКА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНОГ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА

(чл. 522. ЗКП)

На основу чл. 522. ЗКП, предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења према неурачунљивом учиниоцу може поднети само јавни тужилац, а оштећени као тужилац и приватни тужилац нису овлашћена лица за подношење предлога.

37. УВИД У ЗАПИСНИКЕ О ИСКАЗУ СВЕДОКА И ВЕШТАКА

(чл. 388. ЗКП)

На главном претресу који се држи без присуства једне или обеју странака у скраћеном поступку, суд не може одлучити да се по чл. 388. ст. 4. Законика о кривичном поступку, изврши увид у записнике о исказима сведока и вештака који нису дошли на главни претрес. Та одлука је условљена претходним саслушањем, односно сагласношћу странака и зато је није могуће донети у одсуству странака.

38. ОДНОС ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ

(чл. 420. ЗКП)

Одредбом чл. 420. ст. 2. Законика о кривичном поступку, прописано је да суд није везан за предлоге тужиоца у погледу правне квалификације кривичног дела, па постоји могућност суда да оптуженог за кривично дело квалификовано тежом последицом, огласи кривим за исто кривично дело у основном облику, у складу са изведеним доказима на главном претресу, а да ли у конкретном случају треба донети ослобађајућу пресуду за кривично дело које је окривљеном стављено на терет или извршити преквалификацију на основни облик кривичног дела и донети ослобађајућу или осуђујућу пресуду, зависи од утврђеног чињеничног стања на главном претресу.

**Председник Кривичног одељења
Апелационог суда у Нишу
Судија,
Братислав Крстић**

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО

КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОПТУЖБЕ

(Чл. 438. ст. 1. тач. 9. ЗКП)

Оптужба је прекорачена када је суд у изреци пресуде додао оне радње оптуженог, које му се не стављају на терет оптужним актом.

Из образложења:

Првостепени суд је извршио измену оптужног предлога, што је образложио тиме да је у изреци навео оне чињенице, радње извршења дела и последице које је узео за доказане, као и у погледу времена извршења дела, сматрајући да тиме не прекорачује границе оптужног предлога. Међутим, из оптужног предлога се утврђује да се окривљеном ставља на терет да је критичном приликом, дрским и безобзирним понашањем и применом насиља, угрозио спокојство чланова своје породице, оца и мајке, на описани начин, те да је у дворишту сустигао свог оца, ударио га три, четири пута у пределу лица, од чега је он задобио лаке телесне повреде. Првостепени суд је изменио оптужни предлог, тако што је у изреци пресуде навео да је окривљени дрским и безобзирним понашањем, претњом да ће напасти на живот или тело и применом насиља угрозио спокојство чланова своје породице и телесни интегритет свог оца, те да је у дворишту применио насиље према њему. Дакле, произилази да је првостепени суд додао у изреци оне радње које се окривљеном не стављају на терет оптужним предлогом, речима: "претњом да ће напасти на живот или тело", као и да је угрозио не само спокојство чланова своје породице, већ и телесни интегритет свог оца, која радња му се не ставља на терет. На овај начин првостепени суд је прекорачио оптужбу и то на штету окривљеног, пошто му је ставио на терет оне радње које му се оптужним предлогом не стављају на терет. Првостепени суд може да донесе пресуду на основу чињеничног стања, које је утврђено на главном претресу и које се разликује од чињеничног стања из оптужног акта, али да је исто повољније за окривљеног

уколико се ради о истом догађају, те само у том случају нема повреде објективног идентитета између оптужбе и пресуде.

(Пресуда Основног суда у Нишу 12К. бр. 1922/13 од 12.09.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 3283/13 од 01.11.2013. године)

Приредила: судија Горана Митић

ИМОВИНСКОПРАВНИ ЗАХТЕВ

(Чл. 258. ст. 4. ЗКП)

Када су кривичним делом од оштећеног одузети еври и имовинскоправни захтев је истакнут у еврима, оптужени, који је оглашен кривим, обавезује се да оштећеном исплати исти у динарској противвредности, по важећем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Из образложења:

Испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о имовинскоправном захтеву, Апелациони суд налази да је жалба пуномоћника оштећеног у овом делу основана. Наиме, првостепени суд је изреком побијане пресуде обавезао оптуженог да оштећеном на име имовинскоправног захтева исплати износ од 130.699,20 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, сходно чл. 258. ст. 4. ЗКП. При томе је током поступка утврђена тачна вредност одузетог новца, која је наведена и у изреци побијане пресуде, а такође је и оштећени свој захтев истакао у еврима. У том случају, требало је оптуженог обавезати да оштећеном исплати наведени износ у динарској противвредности, а не да исплати исти у динарима, како је то учинио првостепени суд.

Како се стога основано жалбом пуномоћника оштећеног указује да првостепени суд није правилно досудио имовинскоправни захтев, то је побијана пресуда преиначена у наведеном делу, тако што је оптужени, сходно чл. 258. ст. 4 ЗКП, обавезан да оштећеном исплати износ од 1. 170 евра, у динарској противвредности, по важећем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 6К. бр. 947/13 од 17.04.2014. године, и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 775/14 од 26.09.2014. године)

Приредила: судија Горана Митић

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА ИЗ ЧЛ. 246. СТ. 1. КЗ

Код неовлашћеног преношења опојне дроге опис радње извршења кривичног дела мора да садржи битно обележје овог дела, односно да је оптужени неовлашћено преносио опојну дрогу ради продаје.

Из образложења:

Основни облик кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. КЗ садржи више алтернативно одређених радњи, односно кривично дело врши лице које неовлашћено производи, прерађује, продаје или нуди на продају или ко ради продаје купује, држи или преноси или ко посредује у продаји и куповини или на други начин неовлашћено ставља у промет супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге. Дакле, као једна од радњи којима се омогућава стављање у промет опојних дрога прописано је преношење опојне дроге у циљу продаје, док субјективно биће дела садржи умишљај који обухвата радње извршења и објект радње. То значи да је за постојање овог кривичног дела потребно да се неовлашћена куповина, држање и преношење опојне дроге врши ради продаје, те да код учиниоца мора да постоји свест и воља да се опојна дрога преноси ради продаје.

У конкретном случају, оптуженом се ставља на терет да је "неовлашћено преносио опојну дрогу – хероин", на тај начин што је критичном приликом код себе "држао скривену опојну дрогу – хероин", што значи да опис радње извршења кривичног дела не садржи битно обележје овог дела, односно да је оптужени неовлашћено преносио опојну дрогу ради продаје. Осим тога, ни у образложењу пресуде нема разлога о томе да је оптужени пронађену дрогу преносио ради продаје, па стога произилази да дело које се оптуженом ставља на терет није кривично дело, јер недостаје битно законско обележје овог кривичног дела.

(Пресуда Вишег суда у Лесковцу К. бр. 12/13 од 04.06.2013. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 2852/13 од 15.01.2014. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ - ЧЛАН 25. ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Када се захтев за привремено одузимање имовине односи на имовину предузећа, а не на имовину окривљеног, при чему није тражено одузимање имовине од трећег лица, правилно је одбијен захтев за привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела.

Из образложења:

Из списка предмета се утврђује да је теретно возило, чије се одузимање тражи, такође у власништву предузећа "А", односно да је исто набављено на основу уговора о финансијском лизингу од 14.10.2005. године, као и да је исто продато другом предузећу дана 24.07.2012. године, дакле пре подношења захтева за привремено одузимање имовине.

Одредбом чл. 23. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела прописано је да захтев за привремено одузимање имовине садржи податке о власнику, законски назив кривичног дела, означање имовине коју треба одузети, доказе о имовини, околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела и разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине. Такође, одредбом чл. 25. истог закона, прописано је да ће суд решењем одредити привремено одузимање имовине, ако су испуњени услови: 1. постоји основана сумња да је физичко или правно лице извршило кривично дело из чл. 2. овог закона, 2. постоји основана сумња да је имовина власника проистекла из кривичног дела, 3. вредност имовине прелази износ од милион и петсто хиљада динара и 4. постоје разлози који оправдавају потребу за привременим одузимањем. Поред тога, одредбом чл. 3. тач. 2. истог закона имовином проистеклом из кривичног дела сматра се имовина власника, која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима, а чл. 3. тач. 4. да се власником сматра окривљени, окривљени сарадник, оставилац, правни следбеник или треће лице.

У конкретном случају, произилази да се захтев за привремено одузимање имовине односи на имовину чији је власник предузеће "А", а не на имовину окривљеног, а овим захтевом није тражено одузимање имовине од трећег лица, односно од наведеног предузећа.

(Решење Основног суда у Пироту 4Кв. бр. 157/13 од 23.07.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 2. бр. 1238/13 од 17.12.2013. године)

Приредила: судија Горана Митић

**КРИВИЧНО ДЕЛО УГРОЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА
ОПАСНОМ РАДЊОМ И ОПАСНИМ СРЕДСТВОМ****ЧЛ. 290. СТ. 1. КЗ**

За постојање овог кривичног дела неопходно је утврдити да ли је наступила конкретна опасност по живот или тело људи или имовину већег обима.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљене за ово кривично дело ослободио од оптужбе, сматрајући да није наступила последица овог кривичног дела, која се састоји у конкретној опасности за живот или тело људи, односно за имовину већег обима, при чему се цитира садржина одредбе чл. 290. ст. 1. КЗ. За постојање овог кривичног дела потребно је да је опасност по живот или тело људи или имовину већег обима заиста и наступила. Међутим, у конкретном случају, ова одлучна чињеница није поуздано утврђена. Ово из разлога што је саслушан представник оштећеног, који је изјавио да је оваквим радњама окривљених дошло до угрожавања железничког јавног саобраћаја и довођења у опасност живота или тела људи, као и да је причињена материјална штета, без изјашњавања у чему се састоји то угрожавање. Сведок, који је чувар пруге, сведочио је да је он утврдио колико шрафова недостаје, али да има и трулих прагова, па је могуће да неки шраф сам отпадне. У оваквој ситуацији, било је неопходно да се на одговарајући начин утврди да ли је поступањем окривљених, односно уклањањем ових шрафова, дошло до угрожавања железничког саобраћаја, а што првостепени суд није утврдио. Стога се за сада не може прихватити закључак да није наступила конкретна опасност на овај начин, јер је ову одлучну чињеницу требало на несумњив начин утврдити.

(Пресуда Основног суда у Врању ЗК. бр. 883/11 од 17.05.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 2266/13 од 19.11.2013. године)

Приредила: судија Горана Митић

**ИЗРУЧЕЊЕ ДРЖАВЉАНИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЧЛАН 18.-26. ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА**

У поступку за изручење примењују се одредбе члана 18-26. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Из образложења:

Законом међународној правној помоћи у кривичним стварима прописано је поступање суда у поступку за изручење, и то одредбама чл. 18-26. Из првостепеног решења се не види да ли је и на који начин спроведен поступак за изручење пред истражним судијом, на начин како је то прописано одредбама чл. 18-26. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима. Између осталог, лице чије се изручење захтева, поучава се о праву да узме браниоца, а ако се тог права одрекне или истог не обезбеди у одређеном року, поставља му се бранилац по службеној дужности. Дакле, из наведеног произилази да ово лице мора имати браниоца.

С тим у вези, за сада се не може спровести поступак пред Апелационим судом, с обзиром да је одредбом чл. 28. ст. 2. истог закона, прописано да непосредно виши суд доноси одлуку о решењу којим се одбија изручење, али тек након саслушања јавног тужиоца и браниоца лица чије изручење се захтева. Како у конкретном случају ово лице није имало браниоца, то се не може поступити по наведеној законској одредби.

Имајући у виду да је решење донето од стране ванпретресног већа које је извршило увид у списе предмета, без претходно спроведених радњи од стране истражног судије, повређена је одредба чл. 23. ст. 3. цитираног Закона, којом је прописано да ће тек након спроведених радњи из ст. 1. овог члана, истражни судија доставити списе већу од тројице судија.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Кре. бр. 3/12 од 17.05.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кр. бр. 17/13 од 05.11.2013. године)

Приредила: судија Горана Митић

ОВЛАШЋЕЊЕ СУДА ДА САМ ОДРЕДИ ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА

(Чл. 15. ст. 4. Законика о кривичном поступку)

У ситуацији када је одбрана оптуженог противречна у погледу чињенице да ли користи опојну дрогу, а странке нису предложили доказе на ту околност, првостепени суд је овлашћен да по основу чл. 15. ст. 4. ЗКП, одреди неуропсихијатријско вештачење оптуженог, ради утврђивања да ли је у време извршења кривичних дела био конзумент опојних дрога и ако јесте, да ли је и на који начин то утицало на његову урачунљивост.

Из образложења:

"Оптужени А.И. је у својој одбрани у полицији дана 02.12.2012. године, коју је дао у присуству браниоца, изјавио да марихуана, коју је полиција пронашла у кући његове бабе у Алексинцу, није његова, нити да му је познато како се она ту нашла. Међутим, у истражном поступку, приликом саслушања у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, оптужени је своју одбрану изменио, објашњавајући да је вишегодишњи конзумент хероина, да је хероин набављао од оштећеног ВА, да су га често заједно конзумирали и да је од средине новембра 2012. године, почео са лечењем од зависности од опојне дроге.

Након овакве противречне одбране оптуженог, у ситуацији када странке нису предложили доказе на основу којих би се утврдило да ли је оптужени заиста употребљавао хероин, првостепени суд није по основу овлашћења из чл. 15. ст. 4. Законика о кривичном поступку, којим је прописано да суд може дати налог странци да предложи допунске доказе или изузетно сам одредити да се такви докази изведу ако оцени да су изведени докази противречни или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио, одредио неуропсихијатријско вештачење оптуженог, ради утврђивања да ли је у време извршења кривичних дела био конзумент опојних дрога и ако јесте, да ли је и на који начин то утицало на његову способност да управља својим поступцима и схвати значај свог дела, већ је по изјашњењу јавног тужиоца и одбране да немају предлоге за извођење нових доказа, објавио завршетак главног претреса и донео пресуду.

Из тих разлога, нису јасни разлози побијане пресуде у погледу урачунљивости оптуженог, да се у току поступка није јавила сумња у то

да је она била искључена или смањена и да је оптужени кривична дела учинио са умишљајем, а на то се жалбом браниоца основано указује.

С тим у вези, нејасни су и разлози пресуде у вези намене марихуане која је пронађена и одузета од оптуженог. Закључак првостепеног суда да је она била намењена даљој продаји, образложен је свешћу оптуженог да супстанца коју је неовлашћено држао представља опојну дрогу и да је она била упакована у 34 пакетића приближно исте масе. Међутим, овакав закључак је нејасан, зато што претходно није извршено неуропсихијатријско вештачење оптуженог, на основу кога би се могло утврдити да ли је реч о зависнику од опојних дрога и ако јесте, да ли је користио марихуану и у којој количини, а то су чињенице које је затим требало довести у везу са осталим околностима случаја и утврђеним чињеничним стањем, након чега би се могло са сигурношћу утврдити за шта је марихуана била намењена, да ли за потребе оптуженог или је оптужени држао како би је подметнуо оштећеном.

Непоступање првостепеног суда по одредби чл. 15. ст. 4. Законика о кривичном поступку, довело је до тога да чињенично стање у погледу наведених околности није у потпуности утврђено, па је жалба браниоца и у том делу основана. "

(Пресуда Вишег суда у Нишу 4К. бр. 215/13 од 24.03.2014. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 784/14 од 04.09.2014. године).

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

КОНОПЉА ЧИЈА ВРСТА И ВАРИЈЕТЕТ НИСУ УТВРЂЕНИ

(чл. 246. Кривичног законика)

Уколико конопља може да садржи ТХЦ у масеном уделу у проценту већем од 0,3%, реч о врсти и варијетету чије је гајење, промет и поседовање забрањено, у смислу чл. 58. ст. 2. тач. 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и самим тим је предмет извршења кривичног дела из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика.

Из образложења:

"За закључак да одређена биљна материја (рода *cannabis*) представља опојну дрогу прописану законом, потребно да се ради о врсти и варијетету конопље која може садржавати више од 0,3% ТХЦ-а, будући да по-

стоје врсте и варијетети конопље рода *cannabis* које ни у ком случају не могу садржати ниво психоактивне супстанце ТХЦ већи од 0,3%, као што је индустријска конопља.

У конкретном случају, чињеница да је у време извршења кривичног дела, марихуана која је од оптуженог одузета, имала ТХЦ у масеном уделу у проценту већем од 0,3%, што је утврђено на основу записника о вештачењу НКТЦ, непобитно указује да је реч о врсти и варијетету конопље (рода *cannabis*) која има, односно може имати ТХЦ у проценту већем од наведеног. Стога она, у смислу чл. 58. ст. 2. тач. 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама ("Службени гласник РС" број 99/10 од 27.12.2010. године), представља биљку из које се могу добити психоактивне контролисане супстанце, чије је гајење, промет и поседовање забрањено, осим под условима прописаним тим законом и прописима донетим за његово спровођење, а на ту забрану се примењују прописи којима се уређују кривична дела, што је прописано трећим ставом наведене одредбе.

Такође, конопља (канабис) и психоактивна супстанца ТХЦ се налазе на Списку психоактивних контролисаних супстанци Правилника о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци ("Службени Гласник РС" број 28/13 од 26.03.2013. године). Имајући у виду да је одредбом чл. 112. ст. 15. Кривичног законика, прописано да се опојним дрогама сматрају супстанце и препарати који су законом и другим прописом заснованим на закону проглашени за опојне дроге и остале психоактивне контролисане супстанце, то марихуана која је пронађена у стану оптуженог, представља опојну дрогу у смислу Кривичног законика и самим тим је предмет извршења кривичног дела из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика, без обзира што конкретна врста којој припада није утврђена. "

(Пресуда Вишег суда у Прокупљу К. бр. 25/14 од 30.06.2014. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 953/14 од 21.10.2014. године).

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

**ПОСТУПАЊЕ СУДА У СЛУЧАЈУ НЕИСТИНИТОГ
И ПРОТИВРЕЧНОГ ПРИЗНАЊА**

(Чл. 88. Законика о кривичном поступку)

Ако постоји основана сумња у истинитост признања или је признање непотпуно, противречно или нејасно и ако је у супротности са другим доказима, обавеза суда је да и даље прикупља доказе у учиниоцу и кривичном делу.

Из образложења:

"Истинитост признања оптуженог Ж.Ј. које је дао у полицији у присуству браниоца и при коме је остао у претходном поступку и по налажењу Апелационог суда, доведена је у питање самом чињеницом да је оптужени то признање оповргао на главном претресу, када је најпре изјавио да се продавнице, чије је обијање признао, не налазе у насељу Д., које је наведено у оптужници јавног тужиоца, већ у селу Ц. Р., а затим и у поновљеном поступку, када је потпуно негирао да је било какве продавнице обио и да је у томе учествовао и оптужени Д.Ц.

Такође, чињеница да су признањем обухваћени артикли, односно предмети који нису били на пописним листама одузете робе СТКР "Ж. ", власништва оштећеног ИЖ и СТР "С. ", чији је власник оштећена З.М. и да је оптужени Ж.Ј. изјавио да су се оптужени ДЦ и он довели возилом тог оптуженог марке "Голф 2", зелене боје, а из одбране оптуженог ДЦ и исказа сведока М.Ц. и М.Н, произилази да је возило оптуженог Д.Ц. "Голф 1", отвореноплаве боје, такође доводи у сумњу истинитост тог признања. У том смислу су наводи жалбе тужиоца, да није од утицаја то што је оптужени признао одузимање предмета који му се не стављају на терет, неосновани.

И по налажењу Апелационог суда, признање оптуженог Ж.Ј. је нејасно, само себи противречно и у супротности је са изведеним доказима у погледу возила које је коришћено за извршење кривичног дела и одузете робе. У ситуацији када не постоји ни један други доказ који би то признање поткрепио, јер оштећени нису имали сазнања о извршиоцу или извршиоцима кривичног дела, такође ни саслушани сведоци, нити те податке садрже писани докази који су изведени на главном претресу, а ту спадају и криминалистичко-техничка документација и записници о увиђају лица места, на таквом признању оптуженог Ж.Ј. се не може засновати одлука.

Наведени недостаци признања оптуженог, довели су до тога да је у првостепеном поступку дошло до даљег прикупљања доказа о учиниоцу и кривичном делу, саслушањем сведока које је предложила одбрана, имајући у виду да јавни тужилац у том смислу није предложио доказе ни у оптужном предлогу, нити на главном претресу, а на основу чл. 88. Законика о кривичном поступку, којим је прописано да је орган поступка дужан, када оптужени призна да је учинио кривично дело, да и даље прикупља доказе о учиниоцу и кривичном делу ако постоји основана сумња у истинитост признања или је признање непотпуно, противречно или нејасно и ако је у супротности са другим доказима. "

(Пресуда Основног суда у Пироту 2К. бр. 73/12 од 24.06.2014. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 1203/14 од 24.10.2014. године).

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

**ПРИТВОР ПО ОСНОВУ ЧЛ. 211. СТ. 1. ТАЧ. 1. ЗКП
– ЗАМЕНА МЕРОМ ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА МЕСТА
БОРАВИШТА БЕЗ ОДОБРЕЊА СУДА
(чл. 199. Законика о кривичном поступку)**

Приликом одлучивања о продужењу притвора по основу чл. 211. ст. 1. тач. 1. ЗКП, обавеза суда је да у смислу чл. 189. ст. 1. ЗКП, води рачуна о томе може ли се иста сврха постићи неком другом, блажом мером из чл. 188. ЗКП. Та друга мера мора бити таква да обезбеди присуство оптуженог и несметано вођење кривичног поступка, а да му се истовремено не ограничи слобода кретања више од потребног.

Из образложења:

"Чињеница да је оптужени РЈ и поред сазнања да се против њега води кривични поступак, био недоступан суду у периоду дужем од једне године и шест месеци, уз околност да је за кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359. ст. 3. Кривичног законика, запређена казна затвора од две до дванаест година и да она може бити изречена и помагачу, у ком својству је РЈ оптужен, а по основу чл. 35. Кривичног законика, указује на могућност бекства оптуженог уколико би се нашао на слободи и потребу да му се у том смислу ограничи слобода кретања.

Међутим, супротно наводима жалбе јавног тужиоца, у конкретном случају није нужно ограничити слободу кретања оптуженом Р.Ј. продужењем притвора, по основу чл. 211. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку, које се жалбом јавног тужиоца предлаже, већ неком другом, блажом мером из чл. 188. Законика о кривичном поступку, имајући у виду да је оптужени указао првостепеном суду на намеру да се врати у Републику Србију и да је у том смислу предложио укидање потернице да не би био задржан у иностранству и да се одмах по доласку на аеродром "Никола Тесла" у Београду, пријавио полицији, која га је након тога привела, као и одредбу чл. 189. ст. 1. Законика о кривичном поступку, којим је прописано да ће приликом одређивања мера из члана 188. овог законика, орган поступка водити рачуна да се не примењује тежа мера ако се иста сврха може постићи блажом мером.

Наведене околности оправдавају закључак првостепеног суда да је потребно укинути притвор против оптуженог, који му је одређен по основу чл. 211. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку и да је истовремено нужно да му се одреди блажа мера забране напуштања места боравишта без одобрења суда - територије града Лесковца, која је прописана чл. 199. Законика о кривичном поступку, јер је таква мера и по налажењу Апелационог суда, довољна да се у датим околностима, обезбеди присуство оптуженог и несметано вођење кривичног поступка, а да му се истовремено не ограничи слобода кретања више од потребног, с обзиром на чл. 20. ст. 3. Устава Републике Србије, који прописује обавезу свих државних органа, нарочито судова, да при ограничавању људских и мањинских права, воде рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права, као и чл. 39. ст. 2. Устава, да се слобода кретања и настањивања и право да се напусти Република Србија могу ограничити законом, ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка, заштите јавног реда и мира, спречавања ширења заразних болести или одбране Републике Србије. "

(Решење Вишег суда у Лесковцу Кв. бр. 168/14 од 06.10.2014. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 2. бр. 926/14 од 04.11.2014. године).

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ ИЗ ЧЛ. 337 СТ. 1 ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Када веће донесе одлуку по истеку рока од 15 дана од истека рока за подношење одговора на оптужницу, наведено не представља битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438 ст. 2 тач. 3 Законика о кривичном поступку јер се ради о инструктивном року.

Из образложења:

Жалбом браниоца окривљеног М. С. се првостепено решење побија због битне повреде одредаба кривичног поступка и наводи да је решење донето након протекла рока за доношење одлуке о испитивању оптужнице. Иако је последњи дан рока за доношење побијаног решења био петак, 07.02.2014. године, побијано решење није захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 438 ст. 2 тач. 3 Законика о кривичном поступку јер се ради о инструктивном року, у оквиру ког је одређено да би процесну радњу требало предузети али законом нису прописане никакве процесне последице уколико се таква процесна радња предузме након истека рока већ непоштовање таквих рокова повлачи једино обавезу изјашњавања о разлозима за пропуштање, за разлику од преклузивних рокова, који су законом прописани за изјављивање жалбе, преузимање кривичног гоњења и слично, где се пропуштањем рока губи право на њено предузимање. Околност да одлука није експедована истог дана када је и донета такође не утиче на законитост побијаног решења и нема карактер битне повреде одредаба кривичног поступка, како то наводи жалба браниоца окривљеног М. С.

(Решење Апелационог суда у Нишу 18Кж. 2 бр. 310/14 од 27.03.2014. године, решење Основног суда у Прокупљу Кв. бр. 627/13 од 10.02.2014. године)

Приредили: Иван Булатовић, судија Апелационог суда у Нишу
и Марија Димитријевић, судијски помоћник

ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ ИЗ ЧЛ. 54. КЗ

Околности које је првостепени суд ценио приликом избора врсте и висине кривичне санкције и то држање оптуженог након извршеног кривичног дела с обзиром да након саобраћајне незгоде није посетио оштећене нити се интересовао за њихово здравствено стање, да није на било који начин контактирао породицу сада покојне оштећене М.Р. која је изгубила живот у предметној саобраћајној незгоди нити је у току кривичног поступка испољио жаљење што је до наведеног догађаја дошло, погрешно су одређене као отежавајуће околности.

Из образложења:

Испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о казни по жалби браниоца оптуженог, Апелациони суд налази да је изречена казна затвора у висини законског максимума престога јер наведене околности и то његово држање након извршеног кривичног дела с обзиром да након саобраћајне незгоде није посетио оштећене нити се интересовао за њихово здравствено стање, да није на било који начин контактирао породицу сада покојне оштећене М. Р. која је изгубила живот у предметној саобраћајној незгоди нити је у току кривичног поступка испољио жаљење што је до наведеног догађаја дошло, погрешно одређене као отежавајуће околности, нису такве да оправдавају изрицање максимално предвиђене казне за ово кривично дело. Ово из разлога јер се наведене околности могу примењивати приликом одређивања олакшавајућих околности док нису од посебног утицаја приликом одмеравања отежавајућих околности. Осим тога, да је искључива кривица у настанку предметне саобраћајне незгоде на страни оптуженог јер је искључиво оптужени управљајући такси возилом брзином која није била прилагођена особинама и стању пута узроковао предметну саобраћајну незгоду, како је то наведено у образложењу побијане пресуде, не може представљати отежавајућу околност јер се у конкретном случају ради о обележју предметног кривичног дела због којег је оптужени и оглашен кривим и која као таква не представља ни по чему нарочито отежавајућу околност нити прелази меру која је потребна за постојање кривичног дела за које је побијаном пресудом оглашен кривим.

Имајући у виду законски оквир прописане казне за извршено кривично дело, као и утврђене олакшавајуће и отежавајуће околности, Апелациони суд је нашао да је жалба у делу побијања одлуке о казни основана и да приликом одмеравања казне првостепени суд није уважио предлог који је Виши јавни тужилац у Неготину дао на главном претресу да се оптуже-

ни осуди на казну затвора од три године, као и да није дао адекватан значај утврђеним олакшавајућим околностима, посебно чињеници да се ради о до сада неосуђиваном лицу које је у време извршења предметног кривичног дела имало 23 године, а да је пропустио да цени као олакшавајућу околност да је од критичног догађаја прошло четири године и да оптужени у међувремену није извршио друго кривично дело.

На основу свега изнетог, дајући довољан значај и наведеној олакшавајућој околности, Апелациони суд је оптуженог Д.Н. осудио на казну затвора у трајању од три године, налазећи да је таква казна сразмерна тежини извршеног кривичног дела и степену кривице оптуженог и нужна и довољна за остваривање законом прописане сврхе кажњавања из чл. 42. Кривичног законика, спречавањем учиниоца да врши кривична дела, утицајем на њега и на друге да не врше кривична дела, изражавањем друштвене осуде и учвршћивању обавезе поштовања закона. Такође, овако одмерена казна затвора је у складу и са предлогом Вишег јавног тужиоца у Неготину датом у смислу одредбе чл. 413. ст. 1. Законика о кривичном поступку.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 18Кж. 1 бр. 244/14 од 02.09.2014. године, пресуда Основног суда у Неготину 1К. бр. 71/11 од 18.10.2013. године)

Приредили: Иван Булатовић, судија Апелационог суда у Нишу
и Марија Димитријевић, судијски помоћник

НЕПОДОБАН ПОКУШАЈ (члан 31. Кривичног законика)

Уколико је предмет извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика опојна дрога "cannabis sativa", чији је проценат ТХЦ мањи од 0,3%, а која представља конопљу, која припада влакнастом типу и која искључиво има примену у индустрији, реч је о неподобном покушају, у смислу чл. 31. Кривичног законика.

Из образложења:

"Оптужени И.М. је критичног дана, у урачуњливом стању свестан својих радњи, према неподобном предмету покушао да изврши кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, та-

ко што је у својој кући, неовлашћено ради продаје држао супстанцу, за коју је био уверен да представља опојну дрогу "марихуана", а коју је дана 16.03.2012. године неовлашћено нудио на продају потенцијалном купцу Д.Б., кога је телефоном позвао и саопштио да има добру траву, за коју би на име цене требало да понесе 2. 000,00 динара, након чега је поменуто лице упознало овлашћена службена лица Полицијске станице са којима се договорио да позове оптуженог, договоре место наводне испоруке, да би се затим на аутобуској станици, састао са оптуженим, који је у целофану донео 1,67 грама нето масе материје познате под називом марихуана, састављене од осушених делова биљке канабис, али до предаје није дошло, из разлога што су овлашћена службена лица спречила оптуженог да наведену биљну материју прогута, при чему је вештачењем утврђено да таква материја садржи психоактивну супстанцу ТХЦ у проценту мањем од 0,3% и да припада влакнастом типу, који искључиво има примену у индустрији влакана. "

(Пресуда Вишег суда у Неготину 3К бр. 2/2014 од 25.04.2014. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 9Кж. 1. бр. 782/14 од 28.08.2014. године)

Приредила: Јелена Додић,
судијски помоћник, Апелационог суда у Нишу

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 438. ст. 2. тач. 2. Законика о кривичном поступку)

Првостепена пресуда је захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. Законика о кривичном поступку када суд приликом оцене доказа, није дао јасне и потпуне разлоге у чему се огледа "значајније" угрожавање спокојства грађана и "теже" ремећење јавног реда, што је битан елемент предметног кривичног дела.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Прокупљу 6К. бр. 852/12 од 19.02.2013. године окривљени М.Ђ. из Прокупља оглашен је кривим за кривично дело насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 7 месеци у коју му се има урачунати време проведено у притвору од 21.11.2012. године до 14.12.2012. године.

По налажењу Апелационог суда у Нишу, основано се жалбом браниоца указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. ЗКП јер пресуда не садржи разлоге о чињеницама које су предмет доказивања. Наведена повреда кривичне процедуре огледа се у томе што је првостепени суд окривљеног огласио кривим за кривично дело насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ јер је "вршењем насиља према оштећеном Н.К., дрским и безобзирним понашањем значајније угрозио спокојство грађана и теже реметио јавни ред и нанео му лаке телесне повреде" ближе описане у изреци, док у образложењу пресуде, приликом оцене доказа, није дао јасне и потпуне разлоге у чему се огледа "значајније" угрожавање спокојства грађана и "теже" ремећење јавног реда, а што је битан елемент предметног кривичног дела. Следствено наведеном, у првостепеној пресуди изостали су разлози који несумњиво указују да је, конкретном приликом, већи број људи био изложен осећању личне или имовинске несигурности које су изазване радњама окривљеног и разлози који се тичу интензитета евентуалног непокојства, на ком месту, под којим околностима и у које доба дана се догађај десио.

У контексту наведеног, а код околности да је кривично дело свршено када је неком од алтернативно предвиђених радњи извршења овог кривичног дела значајно угрожено спокојство грађана или је у већој мери поремећен јавни ред и мир, само паушално описивање радњи окривљеног М.Ђ., а без навођења делатности која се појављује као радња извршења овог дела, остаје нејасно по датом опису дела, да ли је лака телесна повреда проистекла из насилничког понашања и да ли је нанета нехатно, или се ради о "обичној" лакој телесној повреди. С овим у вези, Апелациони суд указује да се наведено кривично део састоји у угрожавању спокојства грађана или ремећењу јавног реда и мира, али не у угрожавању спокојства лица према коме се насиље врши, већ присутних грађана.

Због наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, за сада се не могу као правилна прихватити чињенично правна закључивања првостепеног суда, па је побијана пресуда укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 6К. бр. 852/12 од 19.02.2013. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 6Кж. 1. бр. 1890/13 од 09.10.2014. године)

Сентенцу приредила: Милица Алексић
виши судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

(Чл. 32. ст. 1. Законика о кривичном поступку)

Правни разлог за преношење месне надлежности суда постоји када су све судије које поступају у кривичној материји у различитим својствима учествовале у различитим фазама предметног поступка или су изузете од поступања.

Из образложења:

У захтеву за преношење месне надлежности Вишег суда у Пироту Су VII 32/14 од 17.10.2014. године наведено је да су све судије Вишег суда у Пироту из правних разлога спречене да поступају у кривичном предмету окривљеног Д. Н. из Пирота и др., због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл. 234. ст. 3. у вези ст. 1. Кривичног законика у вези чл. 33. КЗ и чл. 61. КЗ из којих разлога је затражено преношење месне надлежности.

Имајући у виду да из списка предмета произилази да су све судије које поступају у кривичној материји у различитим својствима учествовале у различитим фазама предметног поступка (претходни поступак, потврђивање оптужнице) или су изузете од поступања, а код околности да пред Вишим судом у Пироту тренутно поступа седморо судија, Апелациони суд је нашао да је основан захтев за преношење месне надлежности јер за то постоје правни разлози па је решењем, применом одредбе чл. 32. ст. 1. ЗКП, одредио други стварно надлежан суд на свом подручју, конкретно Виши суд у Нишу.

(Захтев за преношење месне надлежности Вишег суда у Пироту Су VII 32/14 од 17.10.2014. године, решење Апелационог суда у Нишу 17Кр. бр. 43/14 од 23.10.2014. године)

Сентенцу приредила: Милица Алексић,
виши судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ПРОТИВРЧЕНО И НЕЈАСНО ПРИЗНАЊЕ

(Чл. 88. ЗКП)

Изјава окривљене у завршној речи да прихвата предложену кривичну санкцију од стране тужиоца, а у склопу целокупне њене одбране дате током трајања кривичног поступка да негира извршење кривичног дела, представља противречно и нејасно признање.

Из образложења:

"Првостепени суд је окривљену Ј.Р. огласио кривом због кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 1. КЗ и на основу одредбе чл. 429. ст. 3. тач. 1. ЗКП пресуду делимично образложио, тако што је нашао да је окривљена признала да је учинила кривично дело јер се у завршној речи сагласила са предлогом јавног тужиоца да буде оглашена кривом и да јој се изрекне условна осуда, а које признање је првостепени суд у потпуности прихватио и оценио као реално, усмерено на правилно утврђење чињеничног стања и сагласно са другим доказима, те суд у даљем образложењу пресуде није износио садржину и анализу изведених доказа које је оценио као веродостојне и на основу којих је утврдио чињенично стање описано у изреци пресуде.

Основано се жалбом окривљене указује да су потпуно нејасни разлози првостепеног суда у побијаној пресуди, у погледу закључка да је окривљена признала извршење кривичног дела, те се правилно истиче, да изјава окривљене у завршној речи да прихвата предложену кривичну санкцију од стране тужиоца, а у склопу целокупне одбране окривљене дате током трајања кривичног поступка, представља противречно и нејасно признање, јер је одбрана окривљене дата на главном претресу којом приликом негира извршење кривичног дела у супротности са изјавом окривљене у завршној речи да прихвата да јој се изрекне условна осуда, при чему окривљена ни у завршној речи није изричито признала да је извршила радње описане у изреци пресуде за које је побијаном пресудом оглашена кривом.

Како противречност признања постоји када је један његов део у супротности са другим делом, а о нејасном признању се говори када оно није изричито или је неодређено или двосмислено, а одредбом чл. 88. ЗКП је прописано да је, када окривљени призна кривично дело, орган поступка дужан да и даље прикупља доказе о учиниоцу и кривичном делу ако је признање противречно или нејасно и у супротности са другим доказима, то и по налажењу овог суда, првостепени није дао довољене и јасне разлоге из којих је, у конкретном случају, прихватио признање окривљене и нашао да исто не садржи недостатке на које се

указује жалбом, те су нејасни и разлози првостепеног суда о испуњености услова за доношење пресуде са делимичним образложењем из чл. 429. ст. 3. тач. 1. ЗКП. "

(Решење Апелационог суда у Нишу 19Кж. 1. бр. 3831/13 од 29.01.2014. године)

Аутор сенценце: Дијана Јанковић,
судија Апелационог суда у Нишу

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА

(Чл. 337. ЗКП и 338. ЗКП)

Испитујући оптужницу, веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП, се не може упуштати у утврђивање чињеница које произилазе из оцене противречних доказа, нити утврђивати постојање субјективних елемената кривичног дела, јер је за такву оцену надлежно само веће на главном претресу у контрадикторном поступку.

Из образложења:

"Из списка предмета и побијаног решења произилази да се првостепени суд, приликом испитивања оптужнице, упустио у оцену доказа прикупљених у истрази – одбране окривљеног, налаза и мишљења вештака хемијске струке, писаних и материјалних доказа, те је након тога закључио, да нема довољно доказа који би поткрепили оправдану сумњу да је окривљени учинио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет и применом чл. 337. ст. 1. ЗКП у вези чл. 338. ст. 1. тач. 3. ЗКП нашао да нема места оптужби и обуставио кривични поступак против окривљеног.

Како је при испитивању оптужнице, веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП, овлашћено да само да цени да ли постоји довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет, то су дати разлози првостепеног суда, потпуно нејасни и као такви за сада неприхватљиви. "

Расправљајући ово питање веће испитује да ли је тужилац суду доставио довољно доказа који оправдавају извођење окривљеног на главни претрес. Веће које одлучује о оптужници није овлашћено да цени да ли чињенице и околности на којима се оптужница заснива пружају поуздан

доказ да је окривљени извршио кривично дело које му се оптужним актом ставља на терет, нити да ли су испуњени услови да буде оглашен кривим. Такође, у овој фази поступка веће није овлашћено да утврђује постојање или непостојање субјективних елемената кривичног дела, односно да утврђује, да ли је окривљени у конкретном случају, поступао са намером да стави у промет опојну дрогу, на начин како му се оптужницом јавног тужиоца ставља на терет, јер је за такву оцену надлежно судеће веће, на главном претресу у контрадикторном поступку.

(Решење Апелационог суда у Нишу 19 Кж. 2. бр. 765/14 од 05.09.2014. године)

Аутор сенценце: Дијана Јанковић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕПОТПУНО ПРИЗНАЊЕ

(Чл. 429. ЗКП)

Констатација на записнику о главном претресу, да оптужени потпуно признаје кривично дело, није довољна, да би се признање сматрало потпуним, већ је потребно да се оптужени конкретно изјасни о свим наводима оптужбе који га терете, као и о свом субјективном односу према предузетим радњама, те да након тога првостепени суд изведе закључак о томе да ли се ради о признању које испуњава све претпоставке из чл. 88. ЗКП.

Из образложења:

"Основано се жалбом оптуженог указује да се у конкретном случају ради о непотпуном признању, које не испуњава услове прописане одредбом чл. 88. ЗКП, јер је оптужени у својој одбрани признао чињеницу да је својим возилом прешао на леву страну коловоза, али није признао и да се кретао неприлагођеном брзином, а што му се такође ставља на терет оптужбом.

Како непотпуно признање постоји у случају када оптужени признаје само неке чињенице које му се стављају на терет, то се правилно жалбом оптуженог истиче да се у конкретном случају ради о непотпуном признању, јер оптужени у својој одбрани није признао све радње на којима

се заснива оптужба и за које је оглашен кривим, те је и по налажењу овог суда, првостепени суд неправилно у току главног претреса применио одредбу чл. 88. ЗКП и донео пресуду без образложења у смислу одредбе чл. 429. ст. 1. тач. 2. ЗКП, а да за то нису били испуњени законски услови. "

(Решење Апелационог суда у Нишу 19Кж. 1. бр. 688/14 од 25.07.2014. године)

Аутор сентенце: Дијана Јанковић,
судија Апелационог суда у Нишу

НУЖНА ОДБРАНА И ЊЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ

(Чл. 19. КЗ)

Непостојање јаке раздражености или препасти изазване нападом није од утицаја на постојање нужне одбране или њеног прекорачења већ само на могућност ослобођења од казне ако се утврди прекорачење граница нужне одбране.

Из образложења

Основано се жалбом браниоца оптуженог К.С. из Лесковца указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. ЗКП јер су у потпуности изостали разлози о чињеницама које су предмет доказивања а тичу се примене института нужне одбране или њеног прекорачења због чега није било могуће испитати законитост и правилност побијане пресуде. Наиме, теза одбране оптуженог С.К. је била да је кривично дело учинио у нужној одбрани. Позивање на институт нужне одбране у конкретном случају при свим утврђеним околностима конкретног случаја од стране првостепеног суда, (долазак покојног у кућу оптуженог у ноћним часовима, насилан улазак у кућу са оруђем којим може да се нанесе тешка телесна повреда и остале околности) је заслуживало детаљнију пажњу првостепеног суда и анализу истог института. Уколико је првостепени суд сматрао да се у конкретном случају не ради о нужној одбрани био је у обавези да изврши анализу тог института и изнесе разлоге због чега сматра да у конкретном случају нема места примени овог института. Навод првостепеног суда на страни тринаестој у другом пасусу којим се образлаже одсуство јаке раздражености и у

вези са тим непостојања кривичног дела убиства на мах из чл. 115. КЗ не може представљати образложење и за непостојање нужне одбране или њено прекорачење како се то наводи у наведеном пасусу, обзиром да се ради о два сасвим различита института материјалног права. Законодавац у чл. 19. ст. 3. КЗ једино код прекорачења границе нужне одбране услед јаке раздражености или препасти изазване нападом предвиђа могућност ослобођења од казне па се само у том смислу може говорити о повезаности института прекорачења нужне одбране и убиства на мах обзиром да је заједничка компонента код оба ова института постојање јаке раздражености изазване нападом. Међутим, у свим другим случајевима постојање јаке раздражености изазване нападом нема утицаја на постојање института нужне одбране и њеног прекорачења. Нужна одбрана садржи више елемената као и прекорачење нужне одбране па је првостепени суд био у обавези да анализира те елементе и оцени да ли у конкретном случају има места примени ових института и за сваку своју одлуку изнесе јасне разлоге. Овим налогом се наравно не прејудицира одлука првостепеног суда у вези постојања ових института већ се само налаже да се изврши анализа и затим дају разлози за било какву судску одлуку у том правцу.

(Пресуда Вишег суда у Лесковцу К. 35/14 од 02. 9. 2014. године и решење Апелационог суда у Нишу 12Кж. 1. 1166/14 од 27.10.2014. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА - НЕРАЗУМЉИВОСТ ИЗРЕКЕ ПРЕСУДЕ -

(Чл. 438 ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Чињенични опис пресуде мора садржати време и место извршења кривичног дела, па уколико изрека пресуде то не садржи већ се само наводи да је окривљени " на месту и у време означено у оптужном предлогу" учинио кривично дело, при чему следи опис радњи које је окривљени предузео, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 1. тач. 11 ЗКП јер је изрека пресуде неразумљива.

Из образложења

Основано се жалбом заједничког браниоца окривљених указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка тиме што је у опису дела за окривљеног М. В. пропустио да наведе време и место извршења кривичног дела, што изреку пресуде чини неразумљивом. Позивање првостепеног суда на диспозитив оптужног предлога, који није саставни део пресуде, није довољан за опредељење места и времена извршења кривичног дела, што се основано указује у изјављеној жалби заједничког браниоца окривљених. Управо због постојања наведене битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. ст. 1. тач. 11. ЗКП било је нужно укидање ожалбене пресуде.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 4К. 203/11 од 07.11.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж. 1. бр. 1346/13 од 21.10.2013. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

**КРИВИЧНО ДЕЛО СКИДАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА ИЛИ ЗНАКА
(Чл. 327. ст. 1. КЗ)**

Кривично дело скидање службеног печата и знака је власторучно кривично дело па због тога извршилац овог дела не може бити лице које је ангажовањем трећег стручног лица оштетило пломбу електродистрибуције и извршило прикључење свог струјомера на електродистрибутивну мрежу.

Из образложења

Основано се жалбом окривљеног И.С. указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 2. тач. 2. ЗКП навођењем да је првостепени суд неосновано закључио да је можда треће лице учинило за окривљеног услугу прикључења струјомера, што представља противречност датих разлога са изреком првостепене пресуде, а због чега се није могла испитати законитост и правилност исте.

Наиме, првостепени суд је у изреци пресуде окривљеног огласио кривим за предметно кривично дело које је по чињеничном опису учинио тако што је скинуо службени печат који је овлашћено службено лице ста-

вило ради осигурања предмета, а на страни четвртој у претпоследњем пасусу првостепени суд наводи да је окривљени уклонио постављену пломбу и објекат прикључио на дистрибутивну мрежу **сам или ангажовањем трећег стручног лица**. Према томе, у образложењу своје пресуде првостепени суд дозвољава могућност да је окривљени то можда учинио и ангажовањем трећег лица. Апелациони суд указује да предметно кривично дело представља власторучно дело и може га извршити само лице које непосредно скине или повреди службени печат или знак. Када би неко лице ангажовањем трећег стручног лица извршило повреду службеног печата, његова одговорност би се могла расправљати у смислу института подстрекавања на извршење кривичног дела, док би непосредни извршилац било управо лице које би повредило службени печат и које би непосредно извршило оштећење или повреду печата или знака. Због противречности изреке пресуде са датим разлозима није се могла испитати законитост и правилност првостепене пресуде.

(Пресуда Основног суда у Нишу К. 2025/12 од 07.02.2013 и решење Апелационог суда у Нишу 12Кж. 1. 3595/13 од 03.02.2014. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ

(чл. 344а ст. КЗ)

Првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. ЗКП када је дајући разлоге за ослобађајућу пресуду због кривичног дела из чл. 344А ст. 1. КЗ навео да је окривљени описану радњу извршења кривичног дела предузео ван стадиона.

Из образложења

Потпуно је неприхватљив навод првостепеног суда, и у вези с тим дати нејасни разлози о одлучним чињеницама које су предмет доказивања, да је кривица И.С. искључена из разлога што је бацање каменице у правцу полицијског службеника предузео ван стадиона због чега нема доказа да је учинио кривично дело из чл. 344а ст. 1. КЗ. Из законског описа

кривичног дела из чл. 344а ст. 1. КЗ произилази да кривично дело чини и лице које између осталог врши насиље или оштећује имовину веће вредности **приликом доласка и одласка** са спортске приредбе или јавног скупа, из чега произилази да за постојање предметног кривичног дела уопште није од утицаја да ли је радња предузета на стадиону или ван њега. У конкретном случају се ради о јединственом догађају и оптужним актом овлашћеног тужиоца се оптуженима ставља на терет да су управо приликом одласка са спортске приредбе учинили предметно кривично дело што подразумева да су радње кривичног дела могли предузети како на стадиону тако и у његовој близини односно приликом изласка са стадиона где се одржава спортска приредба.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 2К. 203/11 од 07.11.2014. г. И решење Апелационог суда у Нишу 12Кж. 1. 54/14 од 02. 7. 2014. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

ТЕШКА КРАЂА

(Чл. 204. КЗ)

Околност да је учинилац противправно одузету ствар продао отпаду по знатно нижој цени од њене реалне вредности, сама по себи, није довољна за закључивање да је његов умишљај био усмерен на прибављање мале имовинске користи и да у његовим радњама недостаје битан елемент кривичног дела тешка крађа из чл. 204. КЗ

Из образложења:

Жалбом се наводи да је погрешно утврђено да је окривљени прибавио имовинску корист у износу од 117.965,00 динара јер је мењач, који је предмет извршења кривичног дела, отпаду продао за 8.000,00 динара, те се по ставу жалбе ради о кривичном делу ситне крађе из чл. 210. КЗ.

Без обзира по којој цени је окривљени предметни мењач продао, умишљај учиниоца да одузимањем туђих покретних ствари прибави себи противправну имовинску корист утврђује се према вредности ствари која је противправно одузета. Окривљени је одузимајући предметни мењач прибавио противправну имовинску корист у износу вредности истог и његова вредност је поуздано утврђена налазом вештака економске и машин-

ске струке, па је без утицаја на другачије одлучивање по којој цени је окривљени одузету ствар даље продао и да ли ју је уопште продао, јер је окривљени продајући мењач отпаду по веома ниској цени свакако знао да се не ради о реалној вредности одузете ствари.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 3783/12 од 14.05.2013. године, пресуда Основног суда у Прокупљу 1К. бр. 931/11 од 13.07.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНА ВАСПИТНЕ МЕРЕ

(Чл. 24. ЗМ)

Васпитна мера упућивање у васпитну установу замениће се васпитном мером упућивање у васпитно поправни дом када све околности указују да је то у најбољем интересу малолетника

Из образложења:

Из побијаног решења произилази да је првостепени суд одлучујући о предлогу Вишег јавног тужиоца за замену изречене васпитне мере, правилно утврдио и оценио све чињенице које су од утицаја за доношење овакве одлуке. Из ванредног извештаја Завода за васпитање деце и омладине у Књажевцу утврдио је да малолетна Ј.В. од момента смештаја у том заводу пружа отпор у свим покушајима да се са том спроведе васпитно-корективан рад, да је укључена у праћење од стране неуропсихијатра у Заводу, да је напала куварицу Завода, била у два наврата хоспитализована на лечење, током распуста покушала суицид тровањем лековима, да је од почетка нове школске године поново показивала одбојност према школи и настави, самовољно напуштала установу, враћала се под дејством алкохола и психоактивних супстанци, одбијала узимање терапије, при чему је у извештају посебно потенцирано да и даље одбија да иде у школу, не поштује кућни ред, самовољно напушта Завод, ступа у односе са старијим мушкарцима, испољава изузетну вербалну и физичку агресивност према вршњацима и запосленима, да је деструктивна, уништава имовину Завода, склона употреби марихуане и алкохола, да је 13.04.2014. године напа-

ла другу корисницу Завода ударајући је песницама у пределу главе и лица због чега је и мишљење стручног тима Завода да проблеми у понашању ове малолетнице превазилазе њихове третманске могућности и да изречена мера не даје очекиване резултате, те да би даљи боравак у Заводу био контрапродуктиван, а да исти доводи у питање безбедност запослених и остале деце.

Имајући у виду наведене чињенице утврђене из извештаја стручног тима Завода, а посебно да је малолетница често под дејством алкохола и психоактивних супстанци, да ступа у односе са старијим мушкарцима и испољава изузетно вербалну и физичку активност према вршњацима и запосленима и уништава имовину Завода, по налажењу овог суда, првостепени суд је правилно поступио када је усвојио предлог Вишег јавног тужиоца за замену изречене васпитне мере другом, адекватном васпитном мером и то васпитном мером упућивање у васпитно поправни дом.

Притом, одлучујући о жалби браниоца малолетнице којом се суштински побија правилност утврђеног чињеничног стања изношењем сопственог става о основаности предлога Вишег јавног тужиоца, овај суд је посебно имао у виду да је овакав предлог јавног тужилаштва уследио након достављања ванредног извештаја Завода са наведеним подацима који осликавају понашање и структуру личности малолетнице, при чему се је и на седници већа, на којој је одлучивано о наведеном предлогу бранилац сагласио са предлогом Вишег јавног тужиоца да се према малолетници изрекне строжија васпитна мера, упућивање у васпитно поправни дом уз образложење да сматра да је у то у њеном интересу, имајући у виду проблеме у извршењу изречене васпитне мере.

По налажењу овог суда, првостепени суд је правилно утврдио да су испуњени услови за замену васпитне мере упућивање у васпитну установу васпитном меру упућивање у васпитно поправни дом јер из списка предмета и из извештаја Васпитне установе произилази да се код малолетнице не постижу очекивани резултати, јер малолетница крши правила кућног реда, агресивно се понаша према осталим васпитаницима и запосленима угрожавајући им физичку безбедност, а према мишљењу тог завода према малолетници се не могу постићи резултати на плану измене њеног понашања, због чега је и предложена измена васпитне мере.

Имајући у виду наведено, као и мишљење представника завода и представника надлежног Центра за социјални рад, уз изјашњење пред-

ставника овог центра на седници већа и непосредно саслушање малолетнице, посебно чињеницу да малолетница није спремна да поштује правила кућног реда, те да укупно понашање малолетнице ремети реализацију васпитне мере не само код ње већ и код осталих штићеника Завода, првостепени суд је правилно закључио да су се у конкретном случају стекли услови за замену изречене васпитне мере у циљу примене појачаних мера надзора и посебних стручних програма васпитања према малолетници, у смислу чл. 24. ЗМ, о чему побијано решење садржи јасне, довољне, опредељене и на закону засноване разлоге које у свему као такве прихвата и овај суд, те је жалба браниоца малолетнице, којом се сматра супротно, оцењена неоснованом.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм. 2. бр. 8/14 од 29.05.2014. године, решење Вишег суда у Зајечару Ивм. бр. 103/13 од 24.04.2014. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕОВЛАШЋЕНО СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНЕ ДРОГЕ

(Чл. 246. ст. 1. КЗ)

Размена једне за другу врсту опојне дроге представља радњу извршења кривичног дела неовлашћено стављање у промет опојне дроге из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика

Из образложења:

Жалбом се не оспорава правилност утврђења суда да је намера оптуженог била да другом лицу преда хероин и узме метадон, већ се потврђује да је оптужени понео опојну дрогу хероин да исти размени за метадон, али се износи закључак да је оптужени наркоман који је више пута лечен и да му је намера била да прибављени метадон употреби за сопствене потребе, па се жалбом сматра да се не ради о промету разменом ради продаје, већ за сопствену употребу, што није кривично дело из чл. 246. ст. 1. КЗ.

Изнети наводи жалбе нису основани. Из самог назива кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога произилази да је радња овог кривичног дела алтернативно одређена и да се на-

ведено кривично дело може извршити неовлашћеном производњом или неовлашћеним стављањем у промет. У смислу одредбе чл. 242. КЗ, недозвољена производња је неовлашћена производња или прерада робе за чију је производњу или прерађивање потребно одобрење надлежног органа, а одредба чл. 243. КЗ прописује недозвољену трговину као набављање робе или других предмета у већој вредности у сврху даље продаје без овлашћења за трговину, бављење таквом трговином или посредовањем у истој.

Предмет кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога није било која роба већ само опојна дрога те је кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога специјално кривично дело у односу на наведена кривична дела и суштински произилази из тих одредаба закона, при чему је одредбом чл. 243. ст. 3. КЗ прописана неовлашћена продаја, куповина или размена робе чији је промет забрањен или ограничен, из чега опет произилази да је размена начин стављања у промет и да се ради о трговини и без намере продаје.

Под појмом стављања у промет опојне дроге, у смислу наведеног члана Кривичног законика, не подразумева се само њена продаја или нудење на продају, већ и сваки други начин стављања у промет као што су поклањање, позајмљивање, размена за неку другу дрогу и слично, па се логичким и језичким тумачењем наведене законске одредбе закључује да размена не мора бити учињена у циљу продаје. Иначе, кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. КЗ је и пребачено у главу број 23 Кривичног законика, као кривично дело против здравља људи, један од најважнијих групних заштитних објеката, те је очигледно да је инкриминација осталих начина промета без намере продаје, чиме је законодавац желео да пружи већу заштиту кажњавањем и овог промета.

У конкретном случају размена је делатност која сама за себе чини неовлашћени други начин стављања у промет опојне дроге, јер размена јесте врста промета обзиром да подразумева да се на саговорача пренесе својина ствари и да му се у ту сврху ствар, односно у конкретном случају опојна дрога и преда, а под стављањем у промет опојне дроге подразумева се и размена исте за било коју другу ствар, осим за новац, при чему је овде оптужени у одбрани датој у полицијској управи, на записнику Ку. бр. 2994/10 од 13.12.2010. године у присуству браниоца, признао да су га полицајци зауставили и код њега пронашли око 2 грама хероина који је понео да трампи за метадон са својим другом и то

да је хтео другу да учини да се трампе, а да је хероин оптужени купио претходног дана од Ј.Р. у количини од 5 грама, те измерио два грама и понео са собом да да другу. Првостепени суд је правилно прихватио одбрану оптуженог дату у полицијској управи, о чему побијана пресуда садржи јасне и у свему прихватљиве разлоге и за овај суд.

Суштина предметне размене опојних дрога је стављање у промет опојне дроге хероин, предајом исте другом лицу, што произилази пре свега из прве одбране оптуженог, коју је првостепени суд прихватио, па околност да се заузврат не би добио новац, што значи да се не ради о продаји, већ друга роба, у конкретном случају друга врста опојне дроге коју би оптужени евентуално користио, што представља размену односно трампу за другу опојну дрогу, даје правног основа за закључак да се ради о размени дроге за другу робу, што у кривичноправном смислу спада у друге начине неовлашћеног стављања у промет опојних дрога.

Дакле, размена није условљена продајом дроге. Имајући у виду наведено, жалбени навод да осим радње продаје дроге, сваки други вид промета дроге мора бити учињен ради продаје да би били остварени елементи бића кривичног дела из чл. 246. ст. 1. КЗ не доводи у питање правилност чињенично правног утврђења првостепеног суда јер је изведеним доказима поуздано утврђено да је оптужени понео опојну дрогу хероин у намери да исту неовлашћено стави у промет, тако што би је заменио за метадон, а давање једне врсте дроге у замену за другу врсту дроге представља неовлашћено стављање у промет опојних дрога у смислу чл. 246. ст. 1. Кривичног законика јер је размена опојне дроге за било коју ствар осим за новац радња извршења наведеног кривичног дела, а у конкретном случају оценом и околности да је хтео да учини другу дајући му хероин у предметној размени.

Стога, неоснован је жалбени навод да је неопходан услов да трампа, односно размена, буде вршена ради продаје и да сама за себе не може бити радња извршења кривичног дела, јер је, по налажењу овог суда, продаја само један од начина стављања у промет опојне дроге, баш као што је и размена исте.

Ово посебно из разлога што размена опојне дроге за друге ствари спада у друге начине неовлашћеног стављања у промет опојних дрога, за коју није као за продају, држање, преношење или посредовање одређено да се врши ради продаје, тако да размена која би се састојала у обавези оптуженог да опојну дрогу хероин преда у својину и државину другом лицу и да као противвред-

ност за ту опојну дрогу прими у својину и државину другу покретну ствар, метадон, јесте радња промета за који оптужени није био овлашћен.

Такође, не стоје наводи жалбе да је оптужени опојну дрогу хероин размењивао за сопствене потребе јер би се то могло односити на метадон а оптужени за ту опојну дрогу није ни оптужен ни оглашен кривим, а оног тренутка када је понео опојну дрогу хероин да је размени, јасно је испољио вољу да је стави у промет а не да је држи за себе, тим пре што је исти имао законског основа да легално, као терапију прописану од стране здравствене установе дође у посед метадона у циљу лечења.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1 бр. 715/14 од 29.07.2014. године, пресуда Вишег суда у Нишу 1К. бр. 55/14 од 08.05.2014. године)

Приредила Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

БЛАЖИ КРИВИЧНИ ЗАКОН

(чл. 5. КЗ)

Примена блажег закона код кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из чл. 219а ст. 2. КЗ

Из образложења:

Окривљена В.Н. је оптужена да је кривично дело са описом радње извршења као у изреци ове пресуде извршила неутврђеног дана током 2007. године, а пре 18.06.2007. године. Оптужним актом јавног тужиоца од 19.02.2009. године окривљеној је стављено на терет кривично дело из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, према закону који је важио у време извршења кривичног дела за које кривично дело је била прописана казна затвора до три године.

Чланом 5. Кривичног законика је прописано да се на учиниоца кривичног дела примењује закон које је важио у време извршења кривичног дела, а ако је после извршења кривичног дела измењен закон једном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца.

У конкретном случају није било места примени Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 72/09 који је ступио на снагу 11.09.2009. године) јер су тим законом кривично правне радње које су окривљеној стављене на терет прописане у чл. 219а ст. 2. за које је прописан затвор од шест месеци до пет година и новчана казна, те се не ради о закону који је блажи по учиниоца.

Стога, правилном применом закона, Апелациони суд је кривично правне радње које су окривљеној стављене на терет правно квалификовао као кривично дело из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, онако како је оптужним предлогом окривљеној стављено на терет, без обзира на каснију измену јавног тужиоца у погледу правне оцене дела, а према закону који је важио у време извршења кривичног дела у смислу чл. 5. ст. 1. КЗ.

Имајући у виду време извршења кривичног дела и то "неутврђеног дана током 2007. године, пре 18.06.2007. године" закључује се да време извршења није прецизно означено већ да је време извршења неутврђени дан у периоду од почетка 2007. године до 18.06.2007. године, што значи од 01.01.2007. године до 18.06.2007. године.

Дакле, у конкретном случају није опредељено ког је дана у том периоду према наводима оптужбе окривљена извршила кривично дело, те је првостепени суд био у обавези да утврди је време извршења 01.01.2007. године, што је најповољније за учиниоца.

Полазећи од законског оквира прописане казне за кривично дело из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, за које је прописан затвор до три године, а имајући у виду рокове застарелости кривичног гоњења и то да је одредбом чл. 103. ст. 1. тач. 3. Кривичног законика прописано да се кривично гоњење не може предузети кад протекну три године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко једне године, а одредбом чл. 104. ст. 1. тач. 6. да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења, Апелациони суд налази да је застарелост кривичног гоњења за наведено кривично дело наступила протеклом рока од шест година, што значи 01.01.2013. године.

Из наведених разлога, применом чл. 354. ст. 3. Законика о кривичном поступку, Апелациони суд је преиначио првостепену пресуду тако што је оптужбу одбио према окривљеној ВН за кривично дело из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, а у смислу чл. 391. ЗКП.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 1544/13 од 14.05.2013. године, пресуда Основног суда у Нишу 4К. бр. 1704/2011 од 22.02.2013. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ИЗРИЦАЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ ЗА ДЕЛА У СТИЦАЈУ

(Чл. 60. ст. 1. и чл. 65. ст. 1. КЗ)

При изрицању условне осуде оптуженом, за кривична дела у стицају, суд је обавезан да најпре за свако дело утврди појединачне казне, а затим јединствену казну и да истовремено одреди да се она неће извршити, ако осуђени у време проверавања не учини ново кривично дело.

Из образложења:

Изрека првостепене пресуде је неразумљива и из разлога што је првостепени суд окривљеном, за кривична дела за која га је огласио кривим, најпре утврдио појединачне условне осуде, а затим му изрекао јединствену условну осуду.

Имајући у виду да је на наведени начин поступљено супротно одредби чл. 60. ст. 1. КЗ јер нису најпре утврђене казне за свако појединачно дело већ су утврђене условне осуде то је овим изрека учињена неразумљивом. У овом делу наведена битна повреда је отклоњена у другостепеном поступку самом чињеницом да окривљени није оглашен кривим за два кривична дела и да није било места примени одредбе чл. 60. КЗ.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 2137/11 од 16.09.2011. године, пресуда Основног суда у Врању К. бр. 3162/10 од 02.12.2010. године)

Приредила Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ВАСПИТНА МЕРА ПОЈАЧАН НАДЗОР ОД СТРАНЕ ОРГАНА
СТАРATEЉСТВА**

(Чл. 17. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично
правној заштити малолетних лица)

Није целисходно изрицање васпитне мере појачан надзор од стране органа старатељства према малолетном лицу према коме је започето извршење исте васпитне мере изречене другим решењем

Из образложења:

Решење не садржи јасне разлоге о одлучној чињеници која се тиче изрицања васпитне мере према малолетном сада пунолетном И.А. Из изреке побијаног решења произилази да је овом малолетнику већ изречена васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства решењем Вишег суда у Пироту Км. бр. 11/10 од 01.07.2011. године, а из образложења истог решења се утврђује да је започето извршење те васпитне мере и да исто траје 7- 8 месеци.

Нејасни су разлози првостепеног суда о целисходности изрицања васпитне мере појачан надзор од стране органа старатељства према малолетном сада пунолетном И.А. у овом кривичном поступку, имајући у виду да се према њему већ спроводи иста васпитна мера, чије је спровођење недавно почело од стране стручних лица органа старатељства и под њиховим стручним и континуираним надзором, нити о овој одлучној чињеници решење садржи разлоге који су на закону засновани.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм1. бр. 35/12. од 25.12.2012. године, решење Вишег суда у Пироту Км. бр. 26/11 од 03.04.2011. године)

Приредила Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**РАДЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ДАВАЊЕ МИТА
ИЗ ЧЛ. 368. СТ. 1. КЗ**

Радња нуђења поклона мора да буде јасна и да на несумњив начин показује вољу окривљеног то јест његово хтење да нуди поклон службеном лицу да то лице на име поклона изврши одређену радњу, закониту или незакониту.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Нишу 6К. бр. 651/10 од 11.07.2011. г. Оптужени ДД је оглашен кривим због кривичног дела давање мита из чл. 368. ст. 1. КЗ.

Одредба чл. 368. ст. 1. КЗ прописује да кривично дело давање мита чини ко службеном лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би

смео извршити или да не изврши службену радњу коју би морао извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица. Тумачењем ове одредбе произилази да се радња овог кривичног дела састоји у нуђењу поклона, стављање на располагање службеном лицу поклон, које се налази код учиниоца дела, и да је нужно да прималац поклона-службено лице у вези са тим нешто учини или пропусти да учини, односно да учини нешто што не сме да учини, односно нуђење поклона службеном лицу у вези са вршењем законите радње или незаконите радње тог службеног лица.

Из чињеничног описа кривичног дела изреке побијане пресуде произилази да је окривљеном стављена на терет радња да је приликом предаје теста понудио новчаницу службеном лицу коју је држао савијену у малу коцкицу у десној руци, док је у левој држао тест обраћајући му се речима "може ли ово да се призна" а потом се наводи шта је окривљени мислио а није изговорио "мислећи да му члан комисије НН попуни преостала питања Б.Б., с обзиром да је окривљени у истом попунио само првих 6 питања и код 5 питања већ направио грешку јер је заокружио и одговор под А и одговор под Б, што се сматра неправилним одговором, те би у случају евентуално још једне грешке у зависности од бодова пао на тесту, што је било врло вероватно, јер због приватних обавеза није стигао да се спреми на тест". Овакав чињенични опис радње је нејасан.

Радња нуђења поклона мора да буде јасна и да на несумњив начин показује вољу окривљеног то јест његово хтење да нуди поклон службеном лицу да то лице на име поклона изврши радњу, закониту или незакониту и за коју то радњу службеног лица окривљени нуди поклон. То што је наведено шта је окривљени мислио, а није рекао, нити је из претходних радњи јасно шта је хтео, изреку пресуде када је у питању радња окривљеног чини неразумљивом, а с обзиром да се ради о битним елементима кривичног дела исто је од битног значаја и за правну квалификацију овог кривичног дела.

У вези са тим су и нејасни разлози првостепеног суда у односу на радњу кривичног дела, при чему су и изостали разлози о незаконитој радњи службеног лица у вези које је окривљени нудио поклон, то јест која је овлашћења службено лице имало и у вези са тим шта није смео да уради.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1 1137/12 од 25.10.2012. г. и пресуда Основног суда у Нишу 6К. бр. 651/10 од 11.07.2011. г.)

Приредила: судија Љиљана Миљковић

**ИЗДВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА О САСЛУШАЊУ СВЕДОКА
ИЗ ЧЛ. 98. ПРИМЕНОМ ЧЛ. 337. СТ. 3. ЗКП**

("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и 68/02 и "Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09 и 76/10).

У току трајања доказног поступка, дакле када доказни поступак није завршен, у ситуацији када сведоци који су ослобођени од дужности сведочења из чл. 98. ЗКП нису примили позиве за претрес нема места издвајању записника о саслушању ових сведока јер још постоји могућност да исти приме позив.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Врању 2К. бр. 118/12 од 29.07.2013. г., из списка предмета Вишег суда у Врању 2К. бр. 118/12, издвојени су записници о саслушању сведока М.А. са записника К. бр. 193/10 од 16.03.2011. г. и записник о саслушању сведока Д.А. К. бр. 193/10 од 13.04.2011. године.

Првостепени суд изреком побијаног решења издваја наведене записнике о саслушању сведока М.А. и Д.А, и који су саслушани током претходног првостепеног поступка и у образложењу истог за доношење наведене одлуке позива се на одредбу чл. 337. ст. 3. ЗКП, наводећи да су исти саслушани на предлог опт. П.П. и његовог браниоца, који су одустали од предлога за саслушање, налазећи да исти живе и раде у Немачкој и да се незна када ће доћи у Србију, а да је оптужени своју одбрану изменио у поновљеном поступку и повукао изјаву да је код ујака и брата од ујака видео кесу са пиштољем и периком и да је исту додиривао. Даље суд налази да није потребно саслушање наведених сведока у циљу провере одбране оптуженог јер би позивањем истих а који се не налазе у Србији и који су привилеговани сведоци, поступак непотребно одуговлачио.

Одредбом чл. 337. ст. 3. ЗКП прописано је да се записници о ранијем испитивању лица који су ослобођени од дужности сведочења (чл. 98) не смеју прочитати ако та лица нису позвана на главни претрес или су на главном претресу пре првог испитивања изјавила да неће да сведоче, по завршеном доказном поступку веће ће одлучити да се записници одвоје из списка и одвојено чувати.

Из списка предмета произилази да доказни поступак још није завршен, те постоји могућност да наведени сведоци приме позив. Имајући у виду наведено и цитиране законске одредбе, нису јасни разлози првостепеног суда

за своју одлуку да сходно чл. 337. ст. 3. ЗКП издвоји записнике о саслушању сведока МА и ДА, на шта основано указује у жалби бранилац оптуженог.

На изнети начин начињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, што је условило да решење морало је бити укинато.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 2бр. 1244/13 од 05.09.2013. г. и решење Основног суда у Врању 2К. бр. 118/12 од 29.07.2013. г.)

Приредила:судија Љиљана Миљковић

ЖАЛБА БРАНИОЦА ЧЛ. 364. И 446. СТ. 6. ЗКП

("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и 68/02 и "Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 85/05, 115/05, 49/07,122/08, 20/09, 72/09 и 76/10).

Нема места одбачају жалбе браниоца ако је иста изјављена у року за изјављивање жалбе окривљеног а пре него што је бранилац примио пресуду и пре него што је за њега отпочео рок за изјављивање жалбе.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Нишу 12К. бр. 1874/12 од 22.04.2013. г. одбачена је жалба браниоца окривљеног Ј.С. из Ниша адвоката НЈ из Ниша од 03.04.2013. године изјављена на пресуду Основног суда у Нишу 12К. бр. 1874/12 од 29.01.2013. године као неблаговремена.

Одредбом чл. 372. ст. 2. ЗКП прописано је да ће неблаговремену и недозвољену жалбу одбацити председник већа првостепеног суда а одредбом чл. 376. прописано је да ће се жалба одбацити као неблаговремена ако се утврди да је поднета после законског рока.

Надаље, одредбом чл. 446. ст. 6. ЗКП прописано је да против пресуде донете у скраћеном поступку може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана достављања пресуде.

Из списка предмета произилази да је по одржаном главном претресу дана 29.01.2013. г. првостепени суд објавио пресуду 12К. бр. 1884/12 од 29.01.2013. године. Надаље формалан отправак пресуде достављен је окривљеном на дан 04.02.2013. г. а браниоцу окривљеном адв. Н.Ј. на дан 13.04.2013. г., а жалбу на пресуду бранилац окривљеног је изјавио на дан

03.04.2013. године, произилази пре него што је добио формално отправак пресуде а након што је пресуда објављена и пре него што је отпочео његов рок за изјављивање жалбе дана 14.04.2013. године а који је истицао дана 21.04.2013. године.

Имајући у виду да је кривичним закоником, одредбом чл. 446. ст. 6. ЗКП, прописан само преклузивни рок за изјављивање жалбе, а не и дилаторни рок у коме се та радња не би смела вршити, то нема ни стварног разлога да се преурањена жалба одбаци. Околност да бранилац још није прочитао пресуду не може изазвати штету, јер своју жалбу увек може допунити по пријему пресуде до истека рока.

С обзиром на наведено и цитиране законске одредбе, нису јасни разлози првостепеног суда да тиме што је бранилац окривљеног изјавио жалбу на пресуду пре него што је добио отправак исте да је његова жалба неблагоприятна јер је окривљени примио пресуду дана 04.02.2013. године и рок окривљеног за изјављивање жалбе истицао 13.02.2013. године, и за закључак да је жалба браниоца окривљеног неблагоприятна.

Због наведеног, нејасно је у каквој су корелацији услови за одбацивање жалбе браниоца окривљеног у односу на рок за изјављивање жалбе окривљеног, јер и бранилац има право на изјављивање жалбе сходно чл. 364. ЗКП и за њега тече засебан рок.

(Решење Апелационог суда у Нишу 2Кж. 2 1155/13 од 20.08.2013. г. и решење Основног суда у Нишу 12К. бр. 1874/12 од 22.04.2013. г.)

Приредила: судија Љиљана Миљковић

ОЦЕНА ДОКАЗА И УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА

Одредбом чл. 16. ЗКП предвиђено је да суд пресуду може засновати само на чињеницама у чију извесност је уверен а да уколико постоји сумња у погледу чињеница од којих зависи постојање обележја кривичног дела суд ће у пресуди решити у корист окривљеног.

Из образложења:

На страни 17. и 18. образложења побијане пресуде првостепени суд је извршио анализу изведених доказа на главном претресу и након

оцене истих изнео јасне разлоге којима се руководио приликом решавања правних питања. Првостепени суд је навео да је на основу изведених доказа утврдио одлучне чињенице у овој кривично правној ствари, а то је да је количина бензина коју је оптужена просула по оштећеном била мала, да се налазила у флашици запремине 0,5 литара, да је оптужена полила само ивицу двоседа на коме је оштећени у том тренутку лежао и то у пределу његове леве ноге, а које чињенице су потврђене свим изведеним доказима током главног претреса а које чињенице не оспорава ни сам оштећени. На основу овако утврђених одлучних чињеница првостепени суд је изнео закључак да намера оптужене није била да оштећеног лиши живота већ да истог повреди обзиром да поливањем само једног дела његове ноге и ивице двоседа свакако не би могло довести до тога да буде лишен живота будући да је оштећени био поливен бензином на делу тела где се не налази витални орган нити сама површина по којој је оштећени поливен била велика тако да би чак и у случају да је до запаљења ипак дошло пламен био локалног карактера и не би се тако брзо раширио на остале виталне делове тела оштећеног.

И по налажењу Апелационог суда на основу изведених доказа на главном претресу а који су предложени од странака закључак првостепеног суда у датој правној ситуацији је исправан. Наиме, одредбом чл. 16. ЗКП предвиђено је да суд пресуду може засновати само на чињеницама у чију извесност је уверен а да уколико постоји сумња у погледу чињеница од којих зависи постојање обележја кривичног дела суд ће у пресуди решити у корист окривљеног.

Одлучне чињенице које су биле предмет оцене првостепеног суда а које се односе на радњу извршења кривичног дела, средство и објекат кривичног дела а посебно евентуално наступеле последице кривичног дела су могле бити предмет провере на главном претресу ангажовањем стручних лица или установа који би изнели мишљење а које би на посредан начин у многостручно допринело расветљавању ове кривично правне ствари. Међутим, чланом 15. ЗКП предвиђено је да је терет доказивања оптужбе на тужиоцу и да суд изводи доказе на предлог странака а да само изузетно може изводити доказе сам ако оцени да су изведени докази противречни или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио, с тим да се ово право суда односи искључиво на допуњавање или употпуњавање постојећег доказног фондуса, те

да није овлашћен да преузме доказивање одлучних или материјално правних чињеница које се тичу конститутивних елемената општег појма кривичног дела. У вези са тим, имајући у виду да првостепени суд није био овлашћен да утврђује одлучне чињенице које чине обележја кривичног дела већ да исте утврђује само на основу предложених доказа, правилно је донео одлуку која је повољнија по оптужену. Обзиром да је првостепена пресуда у смислу чл. 451. ст. 1. ЗКП испитана у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби а да у жалби нису изнете чињенице и предложени нови докази ради допуне утврђивања чињеничног стања у смислу чл. 436. ст. 4. ЗКП, Апелациони суд наведени пропуст у утврђивању чињеничног стања у доказном поступку може само констатовати.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 18Кж1. бр. 140/14 од 29.01.2014. године, пресуда Вишег суда у Неготину 1К. бр. 16/13 од 29.10.2013. године)

Приредио: Иван Булатовић,
судија Апелационог суда у Нишу

УКИДАЊЕ ПРИТВОРА ЈЕР ВИШЕ НЕ СТОЈЕ РАЗЛОЗИ ИЗ ЧЛ. 211. СТ. 1. ТАЧ. 3. И ТАЧ. 4. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Првостепено решење о продужењу притвора мора садржати разлоге о релевантним околностима које би оправдавале даље трајање мере притвора и које би указивале на ажурно вођење поступка и хитно поступање првостепеног суда, с обзиром да се ради о најтежој мери за обезбеђење присуства оптужених, као и да дати разлози за његово одређивање и продужавање у међувремену не изгубе на свом интензитету.

Из образложења:

Основано се истиче у жалбама бранилаца оптужених да притвор према оптуженима предуго траје, скоро годину дана и да нема сврхе да оптужени и даље остану у притвору с обзиром да су у међувремену били пуштени на слободу и да за тих месец дана нису извршили никакно кри-

вично дело, уз околност да из извода казнене евиденције за оптуженог Н.М., која се налази у списима предмета, произилази да оптужени Н.М. до сада није осуђиван а да је оптужени Г.Ж. осуђиван за друга кривична дела.

Наиме, чл. 210. ст. 1. Законика о кривичном поступку предвиђено је да се притвор може одредити само под условима предвиђеним у овом закону и само ако се иста сврха не може остварити другом мером, а ст. 2. истог члана да је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа који им пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени налази у притвору, док је одредбом чл. 31. Устава Републике Србије предвиђено да трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време, имајући у виду разлоге притвора, да притвор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази најдуже три месеца, а виши суд га може, у складу са законом, продужити на још три месеца, а ако до истека овог времена не буде подигнута оптужница, окривљени се пушта на слободу, да после подизања оптужнице трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време, у складу са законом, а притвореник се пушта да се брани са слободе чим престану разлози због којих је притвор одређен.

Имајући у виду стање ствари у списима предмета, оптужени су били у притвору и то оптужени Г.Ж. почев од 12.09.2012. године до 03.10.2013. године и који је поново притворен почев од 08.11.2013. године а оптужени Н. М. у периоду од 30.11.2012. године до 03.10.2013. године, да је притвор више пута продужаван из разлога предвиђених чл. 142. ст. 1. тач. 5. тада важећег Законика о кривичном поступку, као и да је Виши јавни тужилац у Пироту подигао оптужницу против оптужених дана 08.02.2013. године. Како је у међувремену дошло до примене новог Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, бр. 101/2011, бр. 121/2012, бр. 32/2013 и бр. 45/2013), то су разлози који су наведени као основ за продужење притвора према оптуженима предвиђени у чл. 211. ст. 1. тач. 4. Законика о кривичном поступку и то да је узнемирење јавности, до којег је дошло због начина извршења кривичног дела и сазнања да су оптужени основано сумњиви да су у дужем временском периоду већем броју лица са територије Општине Пирот продавали опојну дрогу, временом опадао и губио на свом интензитету а

нарочито након што су оптужени били лишени слободе, да је ипак поново добио на значају када су оптужени пуштени из притвора тако да у тренутку доношења побијаног решења узнемирење и даље постоји и има такав интензитет да би могао угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка против оптужених јер би њихов даљи боравак на слободи могло да доведе до неспремности поменутих лица да се одазову позиву суда и сведоче у поступку против оптужених, уз околност да је оптужени Н.М. након што му је поново одређен притвор више пута потраживан али није пронађен.

Да би задржавање оптужених у притвору по овом законском основу било оправдано и неопходно за несметано вођење кривичног поступка, потребно је да буду испуњени одређени кумулативни услови предвиђени законом и то: да је за кривично дело које се оптуженима ставља на терет прописана казна затвора преко десет година (односно казна затвора преко пет година са кривично дело са елементима насиља или да је пресудом првостепеног суда изречена казна затвора преко пет година или тежа казна), да су начин извршења кривичног дела или тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности и да је то узнемирење јавности таквог квалитета да може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Из наведене законске одредбе јасно произилази да је услов који се тиче прописане казне затвора испуњен, што је и првостепени суд правилно утврдио, јер су оптужени Г.Ж. и Н.М. оправдано сумњиви да су учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 3. у вези ст. 1. Кривичног законика, за које је прописана казна затвора од 5 до 15 година.

Међутим, у побијаном решењу се наводи да је због начина извршења кривичног дела дошло до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, али се не дају разлози за такав закључак. По налажењу Апелационог суда, првостепени суд није дао довољне и јасне разлоге у чему се састоји узнемирење јавности, односно како је начин извршења кривичног дела довео до узнемирења јавности. Првостепени суд је образлажући своју одлуку само описао начин на који је извршено предметно дело, али се из тога не може закључити како је начин извршења дела у конкретном случају довео до узнемирења јавности нити о којој јавности је реч, да ли се ради о ме-

штанима Општине Пирот, те да ли је то утицало на њихове свакодневне навике.

Такође, ни чињеница да су оптужени Г.Ж. и Н.М. оправдано сумњиви да су у периоду од новембра 2011. године па све до тренутка када је оптужени Г.Ж. лишен слободе, што је период од скоро годину дана, великом броју различитих лица са територије Општине Пирот продавали опојну дрогу хероин, да је код оптужених пронађена и одузета опојна дрога нето тежине 112,66 грама, односно да су радњу кривичног дела које им се ставља на терет извршили као група повезаних лица, те да су је предузимали у континуитету и да су опојну дрогу продавали већем броју лица, сама по себи не представља особиту околност која указује да ће оптужени у смислу чл. 211. ст. 1. тач. 3. Законика о кривичном поступку, у кратком временском периоду поновити кривично дело, тим пре што до сада за истоврсно кривично дело оптужени нису осуђивани а по наводима из чињеничног описа оптужнице Вишег јавног тужиоца у Пироту описана је само једна радња набављања и држања опојне дроге у наведеној количини која има се ставља на терет. На основу свега изнетог, произилази да су разлози првостепеног суда за задржавање оптужених у притвору по наведеном законском основу недовољни и нејасни.

Апелациони суд оцењује да првостепено решење не садржи разлоге о релевантним околностима које би оправдавале даље трајање мере притвора и које би указивале на ажурно вођење поступка и хитно поступање првостепеног суда, с обзиром да се ради о најтежој мери за обезбеђење присуства оптужених, а да су дати разлози за његово одређивање и продужавање у међувремену изгубили на свом интензитету. Како је решење о продужавању притвора до сада више пута укидано са налогом првостепеном суду да се испита да ли се мера обезбеђења присуства оптужених за несметано вођење кривичног поступка може постићи и неком другом, блажом мером предвиђеном чл. 188. ст. 1. Законика о кривичном поступку, као и налоге да првостепени суд да детаљније, јасније и непротивуречне разлоге за даље трајање притвора према оптуженима а да Виши суд у Пироту није поступио по налозима из решења Апелационог суда у Нишу којима су укидана првостепена решења, то овај суд налази да је током трајања поступка дошло до промене одређених чињеница и околности које су раније биле разлог за одређивање и продужавање притвора. Из свих напред наведених разлога, а на основу чл. 216 Законика

ка о кривичном поступку и у смислу чл. 31. Устава Републике Србије, Апелациони суд је укинуо притвор према оптуженима и одредио да се исти одмах пусте на слободу.

(Решење Апелационог суда у Нишу 18Кж. 2бр. 68/14 од 20.01.2014. године, решење Вишег суда у Пироту Кв. бр. 214/13 од 31.12.2013. године)

Приредили: Иван Булатовић, судија Апелационог суда у Нишу
и Марија Димитријевић, судијски помоћник

СУДСКА ПРАКСА

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ПРОЦЕСНО ПРАВО

ОДБАЧАЈ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Када подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року умре у току трајања судског поступка у коме сматра да му је повређено то право, а у списима предмета првостепеног суда нема доказа да су његови наследници или старалац заоставштине преузели поступак, нити има доказа да је иза истог вођен оставински поступак и да су оглашени наследници, то у моменту одлучивања по поднетом захтеву за заштиту права на суђење у разумном року нема странке на страни подносиоца захтева, па се такав захтев одбацује, јер је то недостатак који се у овом поступку (у коме није дозвољен прекид поступка) не може отклонити.

Из образложења:

Предлагачи Н.Б. и К.Б., поднели су Уставном суду дана 12.09.2012. године, уставну жалбу због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Неготину под П. бр. 880/05, сада пред Основним судом у Неготину под П. 844/09, односно под бр. 1П. 43/14. Уставни суд је дана 27.05.2014. године доставио на даљу надлежност Апелационом суду у Нишу захтев предлагача за заштиту права на суђење у разумном року, у складу са одредбом чл. 2. Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 101/13). Апелациони суд у Нишу, је као непосредно виши суд у смислу одредбе чл. 8а Закона о уређењу судова, прихватио стварну и месну надлежност за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року предлагача.

Суд је сходно чл. 77. ст. 1. ЗПП дужан по службеној дужности у току целог поступка да пази да ли лице које се појављује као странка може бити странка у поступку и да ли је странка парнично способна. Одредбом чл. 73. ст. 1. ЗПП прописано је да странка у поступку може бити свако физичко и правно лице.

Увидом у списе предмета првостепеног суда, а на основу смртвонице, утврђено је да је К. Б. преминуо дана 25.09.2013. године, да је првостепени суд донео решење о прекиду поступка дана 31.01.2014. године, а затим и решење о наставку прекинутог поступка дана 19.05.2014. године које није правноснажно, а нема доказа да су наследници сходно чл. 217. ст. 1. ЗПП, преузели поступак и ступили у парницу на место пок. К, нити има доказа да је иза истог вођен оставински поступак и да су оглашени наследници. Због наведеног у моменту одлучивања овог суда по поднетом захтеву за заштиту права на суђење у разумном року нема странке на страни предлагача сада пок. К, а то је недостатак који се у овом поступку (у коме није дозвољен прекид поступка) не може отклонити због чега је овај суд применом одредбе чл. 78. ст. 5 ЗПП у вези са чл. 30. ст. 2. Закона о ванпарничном поступку и чл. 10. ЗПП, захтев за заштиту права на суђење у разумном року предлагача одбацио.

(Решење Апелационог суда у Нишу 21 Р4. г. бр. 158/14 од 18.09.2014. год.)

Приредила: Судија Марина Милановић

ШТЕТА ИЗАЗВАНА УДАРМ ГРОМА

Дистрибутер електричне енергије је у обавези да отклони штету на бројилу и елементима мерног ормана потрошача, насталу услед атмосферског пражњења – удара грома

Према чл. 157. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, на местима на којима атмосферски пренапони могу изазвати опасност, морају се поставити одводници пренапона, а према чл. 158. истог правилника, ако се електрична инсталација напаја из надземне мреже и заштићена је одводницима пренапона, одводници пренапона морају се поставити што ближе кућном прикључку. Тужени "Југоисток" се бави послом дистрибуције електричне енергије и одговоран је за одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система, усклађен са потребама купца сходно чл. 103. Закона о енергетици. Због тога за туженог не може бити непредвидива околност удар грома и појава атмосферских пренапона у електричној мрежи, нити је то за њега неотклоњиви узрок штете, нити узрок који се није могао избећи. Постављање одводника пренапона, сходно чл. 157. и 158. наведеног правилника је начин да се заштите инсталације од атмосфер-

ских пражњења, или уколико постоји неки други начин заштите тужени као дистрибутер електричне енергије може користити, али је у сваком случају дужан да заштити потрошача, купца, од пренапона изазваног атмосферским пражњењем, односно од удара грома.

Са наведених разлога, дистрибутер електричне енергије је у обавези да отклони штету насталу на бројилу и елементима мерног ормана потрошача и да обезбеди несметано напајање електричном енергијом објекат потрошача – купца електричне енергије.

(Решење Апелационог суда у Нишу 14Гж. 2240/13 од 12.12.2013 године)

Приредио: судија Александар Пантић

ПРОМЕНА ВИСИНЕ ИЗДРЖАВАЊА

(Чл. 164. Породичног закона)

За правилну примену чл. 164. Породичног закона потребно је утврдити какве су биле околности у време доношења раније одлуке, и то како на страни повериоца издржавања, мал. детета, тако и на страни родитеља као дужника издржавања, сходно чл. 154. ст. 1. Породичног закона, а какве су околности сада када се тражи измена одлуке, како би суд могао да одлучи јесу ли се околности на основу којих је донета ранија одлука промениле, што би био основ за смањење или повећање висине издржавања.

Доносећи побијану пресуду првостепени суд полази од следећег чињеничног стања: да је пресудом Општинског суда у Лесковцу П. 2187/08 од 02.10.2008. године тужени обавезан да доприноси у издржавању мал. детета исплатом месечног износа од 20% од зараде коју остварује при ВП 2079-2 у Прокупљу. Тужени је сада по наредби команде од 28.12.2011. године удаљен са дужности цивилног лица на служби у војсци на дужност чувара у Прокупљу због одређивања притвора од стране надлежног истражног судије Вишег суда у Прокупљу почев од 22.12.2011. године због сумње да је извршио кривично дело злоупотребе службеног положаја. Просечно исплаћена зарада туженом у нето износу за период децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године износи 13.890,00 динара. Законска заступница тужиоца је у радном односу у Основној школи

"Вук Караџић" где остварује зараду у висини од 46.000,00 динара, живи у кући са родитељима који су пензионери и са сестром која је незапослена. Тужилац је сада на узрасту од 13. година, ученик је седмог разреда основне школе и његове укупне месечне потребе износе 20.000,00 динара. Има деформитет кичме и као вид терапије предложено је пливање.

Код тако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је обавезао туженог да доприноси у издржавању тужиоца са 10.000,00 динара месечно, применом одредбе чл. 154. ст. 1. и чл. 160. - 164. Породичног закона, налазећи да ће тужени, иако остварује накнаду зараде у висини 50% од зараде, с обзиром да се ради о младој и здравој особи, бити у могућности да плаћа досуђену висину алиментације.

Међутим, изнето правно становиште се не може прихватити као правилно и законито јер се основано жалбом указује на битну повреду из чл. 374. ст. 2. тач.12. ЗПП, јер пресуда нема разлога о битним чињеницама, и на непотпуно утврђено чињенично стање, због чега пресуду није могуће испитати са аспекта правилне примене материјалног права, па је иста морала бити укинута.

Одредбом чл. 164. Породичног закона прописано је да се висина издржавања може смањити или повећати ако се промене околности на основу којих је донета претходна одлука.

Одредбом чл. 160. ст. 1. Породичног закона прописано је да се издржавање одређује према потребама повериоца и могућностима дужника издржавања, при чему се води рачуна о минималној суми издржавања. Ставом 3. истог члана прописано је да могућности дужника издржавања зависе од његових прихода, могућности за запослење и стицање зараде, његове имовине, његових личних потреба, обавезе да издржава друга лица те других околности од значаја за одређивање издржавања.

Првостепени суд је из постојеће правноснажне пресуде Општинског суда у Лесковцу П. 2187/08 од 02.10.2008. године утврдио да је тужени био обавезан да доприноси у издржавању мал. детета са 20% од своје зараде. Утврђене су чињенице које се односе на тужиоца, његове основне месечне потребе, утврђено је какве су сада материјалне могућности законске заступнице, узимајући у обзир само њене редовне приходе, и какве су сада материјалне могућности туженог, које суд утврђује само из наредбе команде од 28.12.2011. године и потврде о висини накнаде зараде.

Међутим, за правилну примену чл. 164. Породичног закона потребно је утврдити какве су биле околности у време доношења раније одлуке, и то како на страни повериоца издржавања, мал. детета, тако и на страни родитеља као дужника издржавања, сходно чл. 154. ст. 1. Породичног закона, а какве су околности сада када се тражи измена одлуке, како би суд могао да одлучи јесу ли се околности на основу којих је донета ранија одлука промениле, што би био основ за смањење или повећање висине издржавања.

Из побијане пресуде је нејасно у односу на који приход туженог суд цени његову обавезу за издржавање мал. детета, да ли од накнаде зараде коју тренутно остварује, или од зараде коју би остваривао да није било његовог противправног понашања, па Апелациони суд није у могућности да испита пресуду са аспекта правилне примене материјалног права.

У наставку поступка првостепени суд ће поступити по наведеним примедбама, отклониће учињене битне повреде одредаба парничног поступка и утврдити све битне чињенице од којих зависи одлука о тужбеном захтеву, када ће бити у могућности да уз правилну примену материјалног права одлучи о захтеву за издржавање, дајући за своју одлуку правилне и јасне разлоге.

(Из решења Апелационог суда у Нишу, 15Гж2. 258/14 од 17.07.2014. године.)

Припремиле: Судија Мирослава Миловановић
и виши судијски сарадник Мирјана Милутиновић

СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ И НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Уговор о купопродаји непокретности закључен пре покретања поступка извршења на предметној непокретности и упис у јавне књиге извршен након забележбе јавне продаје не спречавају спровођење извршења.

Према утврђеном чињеничном стању, између тужиоца као купца, и родитеља туженог Д.Ђ., М.Ђ. и З.Ђ. као продаваца, закључен је уговор о купопродаји стана у П., који је оверен пред Основним судом у П. дана 30.11.2010. године. Решењем о извршењу Привредног суда у Н. 06.01.2011. године одређено је извршење на непокретности која је предмет уговора о купопродаји, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца банке

Е. а.д. из Београда према извршним дужницима Д.Ђ., предузетнику, власнику СЗТР "Г.П." Пирот и М.Ђ. Закључком Привредног суда у Н. од 11.06.2012. године одређено је извршење на већем броју непокретности извршних дужника, између осталих и на стану који је предмет уговора о купопродаји од 30.11.2010. године, извршена је забележба закључка у јавну књигу код СКН П., утврђена вредност непокретности и заказана јавна продаја. Тужилац се након сазнања за покренути извршни поступак уписао као власник предметне непокретности у јавну књигу дана 08.07.2013. године.

Код овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је погрешно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца и утврдио да је недопуштено извршење на $\frac{1}{2}$ двособног стана у Нишу, ближе означеног у ставу првом изреке, налазећи да је тужилац у смислу чл. 33. Закона о основама својинско правних односа постао власник спорне непокретности закључењем уговора о купопродаји, те да није од утицаја чињеница што је тужена банка најпре уписала забележбу у јавну књигу 11.06.2012. године, а тужилац се тек након тога 08.07.2013. године уписао као власник спорног стана. Првостепени суд погрешно налази да се правним послом - уговором о купопродаји стиче својина на непокретности а да је упис у јавне књиге последица закључења уговора, односно да упис у јавне књиге има декларативан карактер.

Одредбом чл. 33. Закона о основама својинско правних односа јасно је прописано је да се на основу правног посла право својине на непокретностима стиче уписом у јавну књигу или на други одговарајући начин. Правни посао је правни основ (*iustus titulus*), а упис у јавне књиге или други одговарајући начин је начин стицања својине на непокретностима (*modus acquirendi*), што значи да упис у јавне књиге нема декларативни већ конститутивни карактер, односно да се право својине стиче тек уписом у јавне књиге.

Исто тако, одредбом чл. 60. Закона о државном премеру и катастру прописано је да се својина и друга стварна права на непокретностима стичу, преносе и ограничавају уписом у катастар непокретности (конститутивност уписа), а престају брисањем уписа, а чл. 63. истог закона да су подаци о непокретностима уписани у катастар истинити и поуздани и да нико не може сносити штетне последице због тог поуздања. Како је у конкретном случају тужилац уписан као власник непокретности тек 08.07.2013. године, односно након што је донето решење о извршењу и закључком одређено извршење на предметном стану и извршена забележба

јавне продаје, то је упис тужиоачевог права својине у јавне књиге без утицаја па поступак извршења.

Промена власника у току извршног поступка не чини извршење на тој непокретности недопуштеним. Накнадно стицање права својине од трећег лица, након извршене забележбе јавне продаје, а која је према стању у списима извршена 11.06.2012. године, не утиче на поступак извршења, сходно чл. 107. Закона о извршењу и обезбеђењу. Тужилац је тек након извршене забележбе јавне продаје, уписом власништва накнадно стекао право својине, те нема препрека да се извршни поступак продајом наведене непокретности настави без обзира на промену власника. Стога се не може сматрати да тужилац у смислу чл. 50. поменутог закона у погледу предмета извршења има право које спречава извршење, јер је тужилац у време покретања извршног поступка имао само основ стицања-уговор о купопродаји непокретности, али наведено право није било уписано у јавне књиге, па тужилац није био власник предметне непокретности.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 14Гж. 1991/14 од 23.10.2014 године)

Приредио: судија Александар Пантић

ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА

Верска заједница која није уписана у регистар верских заједница надлежног министарства, нити је регистрована у складу са законом, не може аутономним прописима признати својство правног лица својим организационим јединицама.

Из образложења:

Између тужиоца ПТГП "РТ" као извођача радова и Месне заједнице "П"- Исламске заједнице, као инвеститора закључен је уговор о изградњи џамије. Из извештаја Министарства правде и државне управе Београд утврђено је да наведена верска заједница није уписана у регистар цркава и верских заједница који води ово министарство у смислу чл. 10. ст. 3. Закона о министарствима и чл. 17. Закона о црквама и верским заједницама. Одредбом чл. 9. ст. 1. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом имају својство правног лица, а како је у конкретном из извештаја надле-

жног министарства утврђено да тужена није као таква регистрована и уписана у регистар, то је правилна одлука првостепеног суда када је одбио тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавезе тужена верска заједница - Одбор верске заједнице "П" - Одбор џамије, како је означена у тужби, на исплату дуга по основу уговора о изградњи џамије.

Неосновано је позивање тужиоца у жалби да се према Закону о црквама и верским заједницама, организационим јединицама и установама црква и верских заједница, може признати својство правног лица у складу са аутономним прописима цркве и верске заједнице, јер ни поменута верска заједница није уписана у регистар верских заједница надлежног министарства, да би могла аутономним прописима верске заједнице признавати својство правног лица организационим јединицама, па из тог разлога ни одбор џамије не може имати својство правног лица.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу, 14 Гжс. 1807/14 од 02.10.2014. године)

Приредио: судија Александар Пантић
са судијским помоћником Јеленом Увалин

ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Нису испуњени услови за обуставу испоруке електричне енергије уколико купцу претходно у писменој форми није достављено упозорење и остављен рок за измирење доспелих обавеза.

Радници туженог су тужиоцу истог дана када су сачинили записник-упозорење, које нису уручили тужиоцу већ су га оставили на лицу места, извршили обуставу испоруке електричне енергије без остављања рока у коме тужилац може да измири своју обавезу

Одредбом чл. 27. ст. 2. тач. 10. Уредбе о условима испоруке електричне прописано је да испорука електричне енергије купцу може се обуставити када не извршава обавезе за испоручену електричну енергију у прописаном односно уговореном року, док је ст. 5. истог члана прописано да енергетски субјект за пренос односно дистрибуцију електричне енергије дужан, у случајевима прописаним законом, да пре обуставе испоруке електричне енергије купцу достави писмену опомену о недостацима односно неправилностима због којих му се може обуставити испорука електричне енергије и да му одреди примеран

рок за отклањање тих недостатака односно неправилности који не може бити краћи од 3 дана нити дужи од 30 дана од дана достављања писмене опомене. Закон о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) у члану 147. став 3. прописује да снабдевач, односно јавни снабдевач је дужан да пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке крајњем купцу због неизвршених обавеза крајњег купца из уговора о продаји, купца претходно у писменој форми упозори да, у року који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана достављања упозорења, измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршењу обавезе, као и да упозори крајњег купца на обавезу предузимања свих потребних мера ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине.

Како тужиоцу није остављен законом прописан примерени рок за измирење доспеле обавезе, то је тужилац противправно искључен са електродистрибутивне мреже, па је првостепени суд правилно обавезао туженог да тужиоцу изврши прикључење електричне енергије.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 14Гж. 2106/13 од 05.12.2013 године)

Приредио: судија Александар Пантић

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НА СУЂЕЊУ У РАЗУМНОМ РОКУ

Право на накнаду штете настале повредом права на суђење у разумном року, може се остварити у парничном поступку тужбом за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада органа у вези члана 172. став 1. ЗОО, тек након што је Уставни суд одлучујући по Уставној жалби утврдио да је ово право тужиоца повређено и под условом да захтев за накнаду штете због повреде овог права тужилац није истакао у поступку пред Уставним судом.

Према утврђеном чињеничном стању на коме је првостепени суд засновао своју одлуку тужиле су покренуле извршни поступак у својству извршних поверилаца ради наплате новчаног потраживања пред Првим основним судом у Београду, где је донето решење о извршењу 10.11.2010. године, које међутим није достављено одговарајућим службама ради спровођења. Такође, пред истим судом тужиле су као наследне учеснице

покренуле и оставински поступак, у ком поступку су дале наследничке изјаве, али у коме још увек оставинско решење није донето, услед чега тужиле трпе материјалну штету у виду измакле користи због немогућности издавања објекта – куће у закуп. Тужбеним захтевом тражиле су да првостепени суд обавезе тужену да им на име накнаде штете због противзаконитог и неоснованог одуговлачења извршног поступка, исплати износ од 132.350,00 динара, са законском затезном каматом, као и да им накнади штету на име измакле користи због немогућности издавања објекта у закуп, настале услед нечињења органа тужене у оставинском поступку.

Код овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно одлучио, правилно примењујући материјално право када је одбио као неоснован тужбени захтев тужила, налазећи да у конкретном случају право тужила на накнаду штете припада тек у случају да је вођен поступак пред Уставним судом по Уставној жалби и да је одлуком Уставног суда утврђена повреда права на суђење у разумном року, што овде није случај.

Члан 22. Устава Републике Србије предвиђа "да свако има право на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом као и право на уклањање последица које су повредом настале, уколико су му ускраћена", а према одредби члана 32. Устава Републике Србије гарантује се "да свако има право да независан, непристрасан и законом установљен суд правично и у разумном року одлучи о његовим правима и обавезама". Ове одредбе су правни основ за подношење уставне жалбе због повреде права на суђење у разумном року.

Такође, чланом 89. ст. 3. Закона о Уставном суду прописано је да је одлука Уставног суда којом се усваја уставна жалба, правни основ за подношење захтева за накнаду штете или отклањања других штетних последица пред надлежним органом, у складу са законом.

Сходно наведеним одредбама, одлука Уставног суда којом је утврђена повреда права на суђење у разумном року представља нужан предуслов за остварење права на накнаду штете због повреде овог права у парничном поступку, како то правилно закључује првостепени суд.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 5 Гж. бр. 2091/14 од 27.08.2014. године)

Аутор сентенце судија Слађана Ђуричковић
и виши судијски сарадник Бети Лазаревић

РАДНИ СПОРОВИ

БИТНА ПОВРЕДА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

(Члан 374. ст. 2. тач. 2. ЗПП)

У поступку пред судом запослени може да тражи поништај одлуке или појединачног акта и осуду на исплату зараде, накнаде зараде, других примања или накнаду штете, али не и да суд одлучује о његовим правима. Одлучујући о измени Анекса уговора о раду у погледу висине коефицијента за плату, првостепени суд је починио битну повреду поступка из чл. 372. ст. 2. тач. 2. ЗПП на коју суд пази по службеној дужности.

Из образложења:

У првостепеном поступку је утврђено да је тужилац у радном односу код туженог по основу Уговора о раду, који му је утврђен коефицијент за обрачун плате 13,26. Након измене Правилника о раду у погледу стручне спреме за одређена радна места и коефицијента за обрачун плате, тужиоцу је Анексом уговора о раду промењен коефицијент на 10,70 у складу са коефицијентом за његово радно место. Тужилац у овом поступку, тражи да суд измени Анекс уговора о раду и утврди му коефицијент за обрачун плате 13,26.

Ценећи да су испуњени услови за измену оспореног Анекса уговора о раду, првостепени суд је пресудом, изменио Анекс уговора и утврдио тужиоцу тражени коефицијент за обрачун плате.

Одлучујући на наведени начин, првостепени суд је починио битну повреду поступка из чл. 374. ст. 2. тач. 2. ЗПП, на коју повреду овај суд пази по службеној дужности. Наведеном одредбом је прописано да битна повреда одредаба парничног поступка увек постоји ако је одлучено о захтеву који не спада у судску надлежност (члан 16), односно ако је суд одбио да одлучује о захтеву за који је надлежан.

Наиме, у смислу одредбе чл. 192. Закона о раду, ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61,05 и 54/09) прописано је, да о правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује у правном лицу директор или запосле-

ни кога он овласти. Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права, запослени сходно одредби чл. 195. Закона, може да покрене спор код надлежног суда.

Према карактеру захтева тужба може бити конститутивна - кад се тражи поништај одлуке или појединачног акта и кондемпнаторна - кад се тражи осуда на исплату зараде, накнаду зараде, других примања или накнаду штете.

Кад се тужбом тражи поништавање одлуке послодавца, у том спору суд нема пуну јурисдикцију. Суд је овлашћен да оцењује да ли су донети појединачни акти у складу са законом, али не може да одлучује о самом праву запосленог. О правима запосленог може да одлучује само послодавац, односно надлежни орган послодавца.

Како је првостепени суд поступио супротно наведеној одредби закона и одлучио о праву запосленог, за шта није био надлежан, то је Апелациони суд применом одредбе чл. 391. ст. 2. ЗПП, првостепену пресуду укинуо и одбацио тужбу тужиоца.

(Пресуда Основног суда у Врању, судске јединца у Бујановцу II 33 ПП. бр. 187/13 од 19.09.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу 25 Гж. 1. бр. 544/14 од 27.05.2014. године).

Приредила: судија Ружица Јовановић

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

(Члан 120. и чл. 144. Закона о основама система образовања и васпитања)

Када запослени у установи, након закључења уговора о раду, буде осуђен правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, више не испуњава услове за рад у установи, који су прописани одредбом чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања и радни однос му престаје на основу решења директора у складу са одредбом чл. 140. истог закона, без обзира што је у тренутку отказа уговора о раду био представник запослених.

Из образложења:

У првостепеном поступку је утврђено да је тужилац био у радном односу код тужене и обављао послове наставника разредне наставе, до

08.11.2012. године, када му је отказан Уговор о раду, применом одредбе чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања, а због изречене безусловне казне затвора у трајању од шест месеци, пресудом Основног суда у Пироту 3 К. бр. 133/10 од 30.04.2010. године и пресудом Апелационог суда у Нишу Кж. бр. 3170/10 од 11.04.2012. године.

Наведеном пресудом тужилац је оглашен кривим за извршено кривично дело недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 1. у вези чл. 180. ст. 1. Кривичног законика, те му је отказан Уговор о раду, с обзиром да више не испуњава услове за рад у установи.

Тужилац тврди да је отказ уговора о раду незаконит јер је противан закону, будући да је у моменту заснивања радног односа испуњавао све услове прописане законом и с обзиром да обавља функцију председника синдиката, због чега га штити имунитет до престанка ове функције.

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање правилно је првостепени суд закључио да нису испуњени услови за поништај отказног акта.

Наиме, одредбом чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13) прописано је да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописани законом и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; 4) да има држављанство РС; и 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Ставом 2. исте одредбе је прописано да се услови из напред наведеног става доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву за конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана, или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Из наведене одредбе закона произилази, да су за рад са децом и ученицима у установи потребни одређени услови и то не само у тренутку

заснивања радног односа, већ и у току трајања радног односа, до престанка обављања ових послова. У том смислу је и прописана обавеза установе, да прибавља доказе о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, и то за време трајања радног односа запосленог па до престанка истог.

У конкретном случају тужилац је у кривичном поступку оглашен кривим за кривично дело недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 1. у вези чл. 180. ст. 1. Кривичног законика. Тужена је прибавила доказ о овој чињеници те је правилно поступила када је применом одредбе чл. 120. ст. 4. Закона о основама система образовања и васпитања тужиоцу отказала уговор о раду.

Одредбом чл. 144. истог закона прописано је да радни однос запосленог у установи престаје у складу са Законом на основу решења директора.

Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09) у чл. 188. штити представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, од отказивања уговора о раду, ако тај запослени поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Уговор о раду у смислу чл. 59. Колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, се може отказати и у овом случају ако представник запослених не поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Управо из наведених разлога, жалбени наводи тужиоца да се обавеза за испуњење услова из чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о основама система образовања и васпитања односни само на пријем у радни однос и закључење уговора о раду а не и за престанак радног односа по сили закона, уколико запослени у току трајања радног односа буде осуђен правноснажном пресудом на казну затвора већу од шест месеци, не утичу на правилност и законитост нападнуте пресуде.

Такође, жалбени наводи да овај отказни разлог тужени може да примени само уколико у дисциплинском поступку утврди све релевантне чињенице за отказ уговора о раду, нису од утицаја на одлуку у овој правној ствари. Ово с тога што је, примењени услов за отказ уговора о раду, изричито законом одређен, а то је, да лице које је у радни однос у установи није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора, а не да је утврђена дисциплинска одговорност за одређени прекршај или повреду радне обавезе.

Неосновани су и наводи тужиоца да је отказ уговора о раду незаконит јер му у кривичном поступку није изречена заштитна мера - забрана обављања наставничког посла, будући да му је управо због извршене радње, која је квалификована као кривично дело и за коју је правноснажно осуђен на ефективну казну затвора, решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја бр. 152-00-01102/2012-13 од 27.05.2013. године, одузета лиценца од 04.12.2012. године и сходно одредби чл. 128. ст. 4. Закона нема право на њено поновно издавање нити на рад у установи.

(Пресуда Основног суда у Пироту I ПП. бр. 408/12 од 16.01.2014. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 25 ГжI бр. 1138/14 од 12.08.2014. године)

Приредила: судија Ружица Јовановић

ДЕЈСТВО ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ КРИВИЧНОГ СУДА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Парнични суд је везан за оне правно релевантне чињенице које је утврдио кривични суд правоснажном осуђујућом пресудом, а тичу се бића кривичног дела и кривичне одговорности.

Из образложења:

Према чл. 163. Закона о раду, запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом проузроковао послодавцу. Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао, како се надокнађује, утврђује послодавац у складу са општим актом, односно уговором о раду. Ако се накнада штете не оствари у складу са напред наведеном одредбом о накнади штете одлучује надлежни суд. У конкретном случају одштетна одговорност запосленог заснована је на његовој кривици, јер је правоснажном пресудом кривичног суда оглашен кривим због кривичног дела несавестан рад у привредном пословању из чл. 234. ст. 1 КЗ, а штета је битно обележје тог кривичног дела.

Нису основни наводи жалбе којима се на изнет и утврђен чињенични основ сходно чл. 8. у вези чл. 220. и 223. ЗПП, оспорава правилност и законитост првостепене пресуде. Наиме, правоснажна пресуда кривичног суда у парничном поступку дејствује као правна чињеница, односно представља елемент чињеничног стања материјално правне норме коју парнични суд треба да примени приликом одлучивања као у конкретном случају. С тим у вези, правоснажна пресуда кривичног суда директно утиче на формирање чињеничног основа одлуке парничног суда и исход парнице, јер представља несумњив доказ о постојању одређене правно релевантне чињенице за чије постојање правила меродавног материјалног грађанског права везују одређене правне последице. Чињенице које је утврдио кривични суд у кривичном поступку и које је саопштио у својој пресуди, у погледу битних обележја кривичног дела, за парнични суд, у склопу оцене и других приложених и предложених доказа, представљају чињенични основ закључивања о основаности тужбеног захтева.

Дејство правоснажне пресуде кривичног суда неоспорно је у овој парници, јер се тужбени захтев засива на једном истом животном догађају који је био предмет оптужнице и поводом које је кривични суд донео одлуку. Ово дејство последица је и принципа везаности парничног суда за правоснажну пресуду кривичног суда који је изричито предвиђен у одредби чл. 13. ЗПП.

Наиме, постоји идентитет чињеничног основа у оба поступка правне заштите, јер је животни догађај исти, али са различитим консеквенцама, обзиром да је кривични суд утврђивао да ли одређена радња или пропуштање представља кривично дело, ко је учинилац и да ли му се то може приписати у кривицу, а парнични суд расправља о последицама понашања учиниоца као парничне странке. У конкретном случају парнични суд је везан за оне правно релевантне чињенице које је утврдио кривични суд правоснажном осуђујућом пресудом, а тичу се бића кривичног дела и кривичне одговорности.

С тим у вези, учинилац противправне радње, оглашен је кривим правоснажном пресудом кривичног суда која има посебно дејство, јер се тачност онога што је кривични суд утврдио својом пресудом не може оспоравати, нити довести у питање, па је самим тим везан за утврђење да је настала инкриминисана последица која представља обележје конкретног кривичног дела и да је учинилац одговоран за учињено кривично де-

ло. Последица која представља обележје кривичног дела је штета која је резултат радње, односно пропуштање учиниоца кривичног дела и због које је оптужени оглашен кривим правоснажном пресудом кривичног суда, а тужилац у парници управо захтева накнаду те штете.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 2643/13 од 18.10.2013 године)

Аутор сенценце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВО НА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Право запосленог на исплату јубиларне награде није императивна обавеза послодавца установљена Законом о раду, већ је послодавцима пренето овлашћење да својим актом регулише услове и начин исплате јубиларне награде.

Из образложења:

Према чл. 120. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05... 32/2013), општим актом, односно уговором о раду може се утврдити право на исплату јубиларне награде. Дакле, Закон даје могућност, али не установљава обавезу послодавца да утврди право запосленог на исплату јубиларне награде. Стога, општим актом који је у примени код послодавца, утврђују се услови, начин и обим исплате, као и друга мерила и критеријуми за остваривање тог права.

Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС" бр. 95/08... 95/13), у чл. 1. предвиђа да се тим уговором ближе уређују одређена права, обавезе и одговорности запослених у министарствима, посебним организацијама, Народној Скупштини, Генералном секретаријату председника Републике, Уставном суду, Влади, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, органима за прекршаје и другим републичким органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе који се непосредно примењује, а чл. 1а предвиђено је да се на права и обавезе из радног односа запослених у органима територијалне аутономије и органима локалне самоуправе као и на поједина питања од значаја за учеснике овог уговора примењује одредбе Анекса овог Колективног уговора, који чини саставни део овог колективног уговора.

Према чл. 1. и 2. Посебног колективног уговора за државне органе са Анексом ("Сл. гласник РС" бр. 23/98... 15/12), на права и обавезе из радног односа запослених у органима територијалне аутономије и органима локалне самоуправе, начин остваривања тих права, поступак праћења примене овог Анекса, међусобне односе, као и на сва остала питања од значаја за учеснике овог колективног уговора, примењују се одредбе овог анекса ако законом није другачије одређено, а запослени у смислу овог анекса јесу лица која су у складу са законом засновала радни однос у органима територијалне аутономије односно органима јединица локалне самоуправе, а послодавац у смислу овог анекса је јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне самоуправе, чија права и дужности врши руководиоца надлежног органа.

Стога, како је у конкретној радној средини у примени Посебан колективни уговор за државне органе са Анексом ("Сл. гласник РС" бр. 23/98... 15/12), као општи акт, то се услови, начин и обим права на исплату јубиларне награде цене у складу са одредбама тог акта.

Према чл. 49. Посебног Колективног уговора за државне органе са Анексом, запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права (ст. 1).

Јубиларном наградом рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца, без обзира у ком органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе је запослени остваривао права из радног односа (ст. 2).

Неспорна је чињеница да је тужилац био у радном односу код тужене на пословима саобраћајног инспектора Општинске управе у трајању од седам година пет месеци и четрнаест дана. Како тужилац није био у радном односу у било ком другом органу јединице локалне самоуправе, односно органу територијалне аутономије, то нису били испуњени услови за реализацију права на исплату јубиларне награде у смислу напред наведене одредбе чл. 49. Посебног колективног уговора, којом су на јасан и прецизан начин дефинисане јубиларне године рада.

Стога, како исплата јубиларне награде није императивна обавеза установљена Законом, већ је послодавцима пренето овлашћење да својим актом регулишу услове и начин исплате јубиларне награде, те при чињењу да тужилац није остваривао права из радног односа у периоду од 10 година у органима јединице локалне самоуправе, то Апелациони суд налази да у конкретном случају стаж који је тужилац остварио радом у органима Савезне Републике Југославије не може бити урачунаван у предвиђен број година рада у јединици локалне самоуправе. Из изнетих разлога закључак првостепеног суда се због погрешне примене материјалног права не може прихватити, услед чега је првостепена пресуда преиначена и тужбени захтев тужиоца одбијен као неоснован.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 613/14 од 07.03.2014. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ДЕЈСТВО УСВОЈЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Правноснажно решење о потврђивању усвајања плана реорганизације, је извршна исправа у смислу чл. 167. ст. 1. Закона о стечају, у вези чл. 13. ст. 1. тач. 5 Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 31/2011), и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена, услед чега се право свих поверилаца може остваривати искључиво у складу са усвојеним планом реорганизације.

Из образложења:

Одредбом чл. 167. ст. 1. Закона о стечају ("Сл. гласник РС" бр. 104/2009 и 99/2011) прописано је да је по доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују се искључиво према условима из плана реорганизације. Усвојени план реорганизације је извршна исправа за повериоце чија су потраживања планом обухваћена, јер садржи име повериоца и дужника и обавезу са тачно опредељеним условима измирења и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена. Након усвајања плана

реорганизације, повериоци чија су потраживања у целости призната и који су сврстани у одређене класе поверилаца, немају више правни интерес да даље воде парницу ради исплате новчаног потраживања.

Дакле, Закон предвиђа да послови и радње које предузима стечајни дужник морају бити искључиво у складу и на начин како је усвојеним планом реорганизације одређено, а стечајни управник је дужан да врши надзор над применом одредаба плана реорганизације, има право приговора суду и обавезу обавештења суда и поверилаца о поступању која су супротна плану, јер се реорганизација спроводи онда када се на тај начин обезбеђује повољније намирење поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско оправдани услови за наставак дужниковог пословања. Непоступање по усвојеном плану, представља разлог за покретање стечајног поступка у смислу чл. 173. Закона о стечају и спровођење стечајног поступка банкротством стечајног дужника.

Сви стечајни повериоци чија су потраживања доспела до усвајања плана, могу се намирити само у складу са планом реорганизације, јер усвојени план реорганизације има дејство и према повериоцима који нису за њега гласали као и према повериоцима који нису учествовали у усвајању наведеног плана, тако и према повериоцима чија потраживања наведеним планом нису обухваћена. Наиме, повериоци који своје потраживање нису пријавили у стечајном поступку лишени су могућности принудног намирења својих потраживања спрема стечајном дужнику по основу усвојеног плана реорганизације као извршне исправе. Међутим, имајући у виду правну природу и циљ реорганизације, наставак привредне активности и очување правног субјективитета, повериоци који нису пријавили своје потраживање у стечају, нису лишени могућности намирења свог потраживања на основу пресуде издејствоване у парничном поступку који је вођен против стечајног дужника над којим је вођен и окончан поступак усвајањем плана реорганизације, али само под условима одређеним планом реорганизације, односно само у складу са условима одређеним за испуњење потраживања поверилаца исте класе у коју би се то потраживање могло сврстати.

У конкретном случају, донето је правноснажно решење о потврђивању усвајања плана реорганизације, које у смислу чл. 167. ст. 1. Закона о стечају, у вези чл. 13. ст. 1. тач. 5 Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 31/2011), представља извршну исправу и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена, услед

чега се право свих поверилаца може остваривати искључиво у складу са усвојеним планом реорганизације.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 3652/14 од 23.10.2014. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА

(Чл. 171. Закона о раду)

Запосленом се ради остваривања права, обавеза и одговорности, доставља решење са образложењем и поуком о правном леку у писменом облику, осим у случају измене уговорених услова рада у смислу чл. 171. Закона о раду, која започиње понудом послодавца за закључивање анекса уговора о раду.

Из образложења:

Одредбама чл. 171. и 172. Закона о раду прописани су случајеви када послодавац може тражити измену уговора о раду, као и начин на који се врши измена уговорених услова рада на иницијативу послодавца. У смислу чл. 30. Закона о раду, уговор о раду није само акт заснивања радног односа, већ и акт који има нормативно дејство, јер се њиме уређују права, обавезе и одговорности запосленог и послодавца.

С тим у вези, према чл. 278. Закона о раду, послодавац је био дужан да са запосленим који је засновао радни однос до дана ступања на снагу тог Закона, а нема закључен уговор о раду, да закључи уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности у складу са законом. Наиме, запослени који су засновали радни однос по ранијим прописима, имају акт заснивања радног односа и њима недостаје акт уређења тог односа, као двострано обавезног и теретног уговорног односа, којим би се регулисала садржина узајамних обавеза странака. Стога, пропуст туженог да поступи у складу са одредбом чл. 278. Закона о раду, што је била његова законска обавеза, односно дужност, не може бити оправдавајући разлог доношења једностраног акта којим мења услове рада запосленог и једно-

страно регулише права, обавезе и одговорност тужиле као запослене, како то правилно закључује првостепени суд.

Неоспорно је да послодавац може запосленом да понуди измену услова рада, премештајем на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада, отклањања узрока застоја у раду, лоших односа међу запосленима или увођења мера за боље функционисање делова система рада и у другим ситуацијама, ако запослени за обављање тог посла испуњава не само услов у погледу врсте и степена стручне спреме, него и друге услове у погледу радне способности и потребних знања и вештина. Стога како се премештање врши анексом уговора о раду, те како Закон о раду не прописује распоређивање запослених решењем као једностраним актом, то није постојао правни основ да се тужилца оспореним решењима распореди на послове ВКВ преградника.

Из изнетих разлога, Апелациони суд налази да је на правилно и потпуно утврђено чињенично стање, првостепени суд правилно применио материјално право када је поништио оспорена решења туженог као незаконита, обзиром да послодавац о премештају запосленог на друге послове не одлучује решењем, већ се измена услова рада спроводи по децидираној законској процедури, сходно чл. 171. ст. 1. тач. 1. и чл. 172. Закона о раду, а у вези чл. 193. ст. 1. истог Закона којом је предвиђено да се запосленом у писменом облику доставља решење о остваривању прва, обавеза и одговорности са образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из чл. 172. тог закона, дакле, осим у случају измене уговорених услова рада која започиње понудом послодавца за закључивање анекса уговора о раду. Услед незаконитог распоређивања правилно је првостепени суд обавезао туженика да тужилу врати на послове и радне задатке које је обављале пре доношења оспорених решења, односно на послове који одговарају њеној стручној спреми и радном искуству, те да накнади штету у висини разлике зараде коју би остварила радећи на пословима пре доношења незаконитих одлука и зараде коју је остваривала у спорном периоду. Како су жалбени наводи туженог без основа, то је сходно чл. 390. ЗПП одлучено као у ставу један изреке ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 3453/14 од 03.10.2014. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Чињеница да је војни обвезник који је распоређен у резервни састав Министарства унутрашњих послова био ангажован на извршавању одређених законом предвиђених задатака док су разлози безбедности то захтевали, не представља основ за заснивање радног односа.

Из образложења:

У складу са одредбом чл. 32. Закона о унутрашњим пословима ("Сл. гласник РС" бр. 44/91... 101/05), на раднике Министарства унутрашњих послова примењују се прописи о државној управи, радним односима, здравственом, пензијском и инвалидском осигурању, ако тим законом није другачије одређено. Одредбама чл. 6-10. Закон о радним односима у државним органима, који је у спорном периоду био је у примени, прописно је да се лице прима у радни однос у државном органу на основу коначне одлуке функционера који руководи државним органом о избору између пријављених кандидата или споразума о преузимању из другог државног органа, те да се радни однос заснива даном ступања на рад.

Чињеница да је тужилац био учесник огласа за пријем у радни однос, те да је започет поступак тиме што је обављен лекарски преглед са наговештајем у повољан исход поступка, не може утицати на доношење другачије одлуке у овој правној ствари, обзиром да само коначна одлука о избору између пријављених кандидата, донето решење о пријему у радни однос и ступање на рад, у конкретној радној средини може бити основ заснивања радног односа. У одсуству тих аката, правилан је закључак првостепеног суда да тужбени захтев није основан.

Осим тога, основаност тужбеног захтева не произилази ни из одредаба чл. 27-29. Закона о унутрашњим пословима. Министарство унутрашњих послова, у случају непосредне ратне опасности и рата, попуњава војним обвезницима који су распоређени у резервни састав Министарства, који испуњавају законом утврђене услове за рад у Министарству. Лица из резервног састава министар ангажује на извршавању одређених законом предвиђених задатака док то разлози безбедности захтевају, а за време ангажовања, лица из резервног састава имају права и обавезе службених лица и права из здравственог, пензијског и инвалидског осигура-

ња, као и накнаду утврђену за време проведено на војној вежби и право на разлику до износа плате утврђене за послове на којима су ангажовани.

Дакле, наведеним одредбама регулисан је статус лица која су у резервном саставу Министарства, као и њихова права и обавезе, па стога сама чињеница да је тужилац у 1998. и 1999. године био припадник резервног састава, не чини основ заснивања радног односа, јер закон не предвиђа такав начин и основ заснивања радног односа.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 2608/13 од 11.10.2013. године)

Аутор сенценце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВО НА ИСПЛАТУ КАМАТЕ ЗБОГ ДОЦЊЕ ДУЖНИКА

(Чл. 277., 279. и 295. ЗОО)

Исплата главног новчаног потраживања у доцњи, не гаси право на исплату камате од доспелости и током трајања облигације до њеног престанка, јер се ради о доспелом, а неисплаћеном споредном потраживању, у ком случају поверилац стиче право да износ неисплаћене законске камате остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу, од дана доспелости главног потраживања, до дана исплате, са правом на исплату процесне камате од дана када је суду поднет захтев за њену исплату,

Из образложења:

Правилном применом одредбе чл. 37. ст. 1. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91. . . 79/2005), одредбама Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001), чл. 31. Посебног колективног уговора са Анексом ("Сл. гласник РС", бр. 23/98 и 11/2009) првостепени суд је утврдио доспелост сваког појединачног месечног примања и обавезу туженог да плату исплаћује на начин и у утврђеним роковима предвиђеним законом и општим актом, налазећи да тужени није у законом предвиђеној динамици исплаћивао зараду, услед чега тужилац као поверилац има право на ис-

плату камате у обрачунатом износу и у свему је првостепени суд дао разлоге које прихвата и овај суд.

Право на исплату камате због доцње дужника у исплати главног потраживања регулисана Законом о облигационим односима, у чл. 277. ЗОО, којим је прописано је да дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује поред главнице и затезну камату по стопи утврђеној савезним законом, услед чега право на камату због доцње не зависи од признавања тог права од стране органа тужене, већ од чињеница да ли се ради о доспелој обавези и испуњењу обавезе на начин и у време како је предвиђено.

Одредбом чл. 295. ЗОО предвиђено је да обавеза престаје кад се испуни (ст. 1), а престанком обавезе гасе се јемство, залога и друга споредна потраживања (ст. 2). Исплатом главног потраживања, када обавеза престаје, гаси се и право на исплату камате, као споредног потраживања. Дакле, даном испуњења обавезе, ток камате се прекида, јер у конкретном случају споредно потраживање не може постојати без главног потраживања. Међутим, исплата главног новчаног потраживања у доцњи, не гаси ретроактивно право на исплату камате од доспелости и током трајања облигације до њеног престанка, јер се ради о доспелом, а неисплаћеном споредном потраживању.

С тим у вези одредбом чл. 279. ст. 1. ЗОО прописано је да на доспелу, а не исплаћену уговорену или затезну камату као и на друга доспела повремена доспела давања не тече затезна камата изузев кад је то законом предвиђено. На износ не исплаћене камате може се захтевати затезна камата само од дана када је суду поднет захтев за њену исплату (ст. 2).

Како је главно потраживање исплаћено у доцњи, то је тужилац као поверилац стекао право да износ неисплаћене законске камате остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу, од дана доспелости главног потраживања, до дана исплате у смислу чл. 295. ст. 2. ЗОО, са правом на исплату процесне камате од дана када је суду поднет захтев за њену исплату 06.09.2011. године, сходно чл. 279. ст. 2 ЗОО. Стога, нису основани наводи жалбе којима се указује да је до доцње у исплати зарада дошло без кривице туженог, обзиром да се у прилог својих навода тужени није доставио доказе сходно чл. 220. и 223. ЗПП, нити је доказао да је у смислу чл. 121. Закона о раду обавестио запосленог о разлозима неиспла-

те, о чему је био дужан у смислу ст. 3. истог члана, којим је предвиђено достављање обавештења уз обрачун зараде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 1521/14 од 09.05.2014. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

(Чл. 179. ст. 1. тач. 2. Закона о раду)

Запослени који од клијента прими чек као средство плаћања, који не садржи безусловни упут да се плати одређена свота новца из трасантовог покрића, без означавања дана и места издавања чека (бланко чек), чини повреду радне обавезе предвиђене општим актом, због које запосленом може престати радни однос.

Из образложења:

У конкретном случају, несумњиво је утврђено да је тужилца као шалтерски радник дана 04.10.2011. године од клијента примила бланко чек, супротно законским прописима, без датума, уписаног износа и осталих података и истом вратила износ од 100 динара, за куповину месечне карте у износу од 4. 900,00 динара, иако јој је било познато да је забрањено уновчавање чекова, као и последице које из тога могу да настану, чиме је учинила повреду радне обавезе предвиђене напред наведеним нормама, како је то правилно закључио првостепени суд.

Без утицаја су на правилност првостепене пресуде, жалбени наводи тужилце да поступање са примљеним чеком није уновчавање чека и да враћање износа од 100 динара не може представљати уновчавање чека.

Према чл. 1. Закона о чеку ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 105/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 12/65, 50/71 и 52/73. "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003-Уставна пovelја) између осталог, чек садржи безусловни упут да се плати одређена свота новца из трасантовог покрића и означавање дана и места издавања чека.

Како према чл. 3. наведеног закона исправа у којој не би било ма ко-јег од састојка побројаних у чл. 1, међу којима су и подаци који недостају у конкретном случају, не вреди као чек, а који је тужила примила као средство плаћања за куповину месечне карте у износу од 4.900,00 динара и при том клијенту вратила износ од 100 динара, то је правилан закључак првостепеног суда да је тужила на тај начин, учинила повреду радне обавезе која јој је стављена на терет, при том је без значаја висина износа који је враћен, јер је релевантна радња и поступање које није дозвољено.

Неосновани су жалбени наводи да тужили није било познато да је постојала забрана уновчавања сопствених и туђих чекова у пазарима рачуно-полагача, јер је првостепени суд правилном оценом изведених доказа утврдио да је та чињеница била позната тужили, која је у дисциплинском поступку навела да јој је била позната наведена забрана, тако да је по оцени Апелационог суда постојање само ове повреде довољан основ да се тужили због наведене немарности и несавесности у раду откаже уговор о раду, услед чега нису основани наводи жалбе којима се указује и на то да тужила није учинила друге повреде радних обавеза које су јој стављене на терет.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 2558/13 од 11.10.2013. године)

Аутор сенценце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ КАО УСЛОВ ЗА РАД У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Положен државни стручни испит је обавезни услов за рад у органима државне управе и код носиоца јавног овлашћења који је овлашћен да води управни поступак и одлучује у управном поступку, услед чега надлежни орган послодавца нема дискреционо право да одређена лица ослобађа полагања стручног испита.

Из образложења:

На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд применом одредбе чл. 20. ст. 1. Закона о државној управи ("Сл гласник РС", бр. 20/92) налази да је тужбени захтев основан, оцењујући да је о обавези полагања

стручног испита већ одлучивано решењима туженика од 21.11.2005. године, да иста нису стављена ван снаге, услед чега решења о ослобађању од полагања стручног испита фигурирају у правном саобраћају као коначни и правоснажни акти који производе своје дејство и да поновно обавезивање тужилаца на полагање стручног испита нарушава принцип правне сигурности, те да обавеза садржана у чл. 21. Уговора о регулисању међусобних права и обавеза, не може производити правно дејство.

Међутим, због погрешне примене материјалног права, закључак првостепеног суда се не може прихватити, обзиром да је оцена законитости оспорених решења заснива на Закону о државној управи, одредби члана 20 ст. 1., ("Сл гласник РС", бр. 20/92... 79/05... 87/11), који је престао да важи доношењем Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр79/05, 101/07 и 95/10), који је био у примени у време доношења предметних решења.

Према чл. 19. ст. 1. и чл. 20. ст. 1. и 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 20/92, 48/3 ... 79/2005), запослени могу обављати послове државне управе ако имају прописану школску спрему, положен испит за рад у органима државне управе и када је то одређено законом или другим актом, радно искуство у одговарајућој струци. Лица која су у другим органима и организацијама радила дуже од времена приправничког стажа, а немају положен стручни испит за вршење одређених послова, могу се примати на рад, ако се обавезу да положи стручни испит у року од годину дана ступања на рад. Лица која су у другом органу и организацији радила дуже од три године на истим или сличним пословима, а немају положен стручни испит за вршење послова за које се примају могу се примити на рад без полагања стручног испита ако функционер који руководи државним органом оцени да имају потребно искуство за вршење тих послова, као и лица која су прописима важећим до ступања на снагу овог закона ослобођена од полагања стручног испита, те уколико наведена лица не положи испит у прописаном року предвиђено је да ће им престати радни однос.

Наведене законске одредбе, као императивне, регулишу услове које запослени треба да испуњавају уколико обављају послове државне управе и с тим у вези омогућавање заснивање радног односа лица без положеног стручног испита, али уз орочену обавезу да се тај испит положи, при том без могућности да запослени буде ослобођен полагања стручног испита. У погледу пријема у радни однос и испуњености услова за рад на

управним пословима, наведеним законским нормама изузета су лица која су ослобођена полагања стручног испита по ранијим прописима, односно прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о државној управи који је објављен у "Службеном гласнику РС" бр 20/92.

У конкретном случају није спорно да тужиоци код туженог као послодавца, обављају управне послове, да немају положен стручни испит, нити су ослобођени полагања стручног испита до дана доношења Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 20/92, 48/3 ... 79/2005).

Стога, донета решења директора филијале од 21.11.2005. године, којим су сви тужиоци ослобођени од обавезе полагања стручног испита, могла су бити од значаја на евентуално употребљен разлог за престанак радног односа, као последице рада на управним пословима запослених који немају положен стручни испит и то за протекли период, до доношења оспорених решења од 29.06.2012. године, али не и за убудуће, јер се ради о примени императивних прописа, услед чега надлежни орган послодавца нема дискреционо право да одређена лица ослобађа полагања стручног испита.

Осим тога, побијана решења чији се поништај тражи, донета су применом одредбе чл. 4. и 84. ст. 2. и 4. у вези чл. 86. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005. . . 95/2010), којим је прописано да услове из става 2. и 3. чл. 84. у погледу степена стручне спреме, односно степена образовања и положеног државног стручног испита, мора да испуњава и запослени код носиоца јавног овлашћења који је овлашћен да води управни поступак и одлучује у управном поступку.

Имајући у виду напред наведене законске одредбе, Апелациони суд налази да је првостепени суд на правилно утврђено чињенично стање, погрешно применио материјално право поништавајући оспорена решења од 29.06.2012. године којим су тужиоци обавезани да до 29.06.2013. године положе државни стручни испит пред комисијом коју организују министар надлежан за послове државне управе и локалне самоуправе, јер стручни испит представља обавезни услов за обављање рада у органима државне управе, као и на све носиоце јавног овлашћења када воде управни поступак и одлучују у управном поступку. Стога, околност да су тужиоци решењем туженог од 21.11.2005. године ослобођени полагања стручног испита, није од утицаја, јер нема стеченог права на ослобађање полагања стручног испита по прет-

ходној одлуци туженог у ситуацији када нису за то били испуњени законски услови предвиђени императивним прописима.

У оваквој правној и чињеничној ситуацији, Апелациони суд налази да су оспорена решења заснована на правилној примени одредбе чл. 84. и 86 Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005... 95/2010) и уговорној обавези из тачке 21. уговора о регулисању међусобних права и обавеза који су странке закључиле дана 01.11.2011. године, из којих разлога налази да се основано жалбом туженог побија првостепена пресуда због погрешне примене материјалног права, услед чега је преиначена и тужбени захтев тужилаца одбијен као неоснован, па је сходно чл. 394. ст. 1. тач. 4. ЗПП, одлучено је као у изреци ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 1134/14 од 04.04.2014. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ДОСПЕЛОСТ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА КАДА РОК ЗА ИСПУЊЕЊЕ НИЈЕ ОДРЕЂЕН

Одређивање рока испуњења обавезе може бити остављено једном од субјекта облигације, међутим то право не значи да је он потпуно слободан приликом одређивања овог рока и да искључиво зависи од његове воље, јер доспелост обавезе мора бити одређена у складу са циљем и сврхом који треба да се остваре заснивањем облигационог односа, као и природом обавезе, у смислу чл. 74. ст. 4. и 324. ст. 2 Закона облигационим односима.

Из образложења:

Одредбом чл. 83. Закона о раду из 2001. и чл. 110. Закона о раду који је ступио на снагу 24.3.2005. године, прописано је да се зарада исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. Према чл. 186. Закона о раду из 2005. године, послодавац је дужан да запосленом у случају престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, накнаде зара-

де и др. примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду и то најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Ако послодавац због поремећаја у пословању или из других разлога није извршио исплату зараде и других примања, запослени може да оствари заштиту својих права пред надлежним судом у смислу чл. 195. Закона о раду и да оствари исплату заосталих новчаних потраживања са законском затезном каматом од дана доспелости сваког појединачног потраживања, па до исплате.

Међутим радни однос је уговорни однос и уговорне стране се могу у складу са начелом аутономије воље споразумети да се исплата заосталих зарада и других примања исплати у роковима и под условима утврђеним самим споразумом. Према томе није супротно закону да се у наведеном случају запослени и послодавац споразумевају о другачијем начину и динамици исплате неисплаћених потраживања.

Одредбом чл. 74. ст. 4. Закона о облигационим односима прописано је да је уговор закључен под условом, ако његов настанак или престанак зависи од неизвесне чињенице. Сматра се да је услов остварен ако његово остварење противно начелу савесности и поштења спречи страна на чији је терет одређен, а сматра се да није остварен ако његово остварење противно начелу савесности и поштења проузрокује страна у чију је корист одређена.

Одредбом чл. 324. ст. 2. ЗОО прописано је да ако рок за испуњење није одређен, дужник долази у доцњу кад га поверилац позове да испуни своју обавезу, усмено или писмено, вансудском опоменом или започињањем неког поступка чија је сврха да се постигне испуњење обавезе.

Закљученим споразумом странке нису прецизно и јасно календарским датумом или за тачно одређени период од настанка обавезе, уговорили испуњење обавезе, већ на одредив начин као у чл. 1. Споразума.

Одређивање рока испуњења обавезе може бити остављено једном од субјекта облигације, међутим то право не значи да је он потпуно слободан приликом одређивања овог рока и да искључиво зависи од његове воље, јер доспелост обавезе мора бити одређена у складу са циљем и сврхом који треба да се остваре заснивањем облигационог односа, као и природом обавезе.

С друге стране у конкретном случају, основ и висину новчаног потраживања, које је предмет парнице, тужени у току поступка пред првостепеним судом није оспорио, нити је истицао материјално правни приговор застарелости потраживања.

Како тужени чињенице на којима тужилац заснива основ и висину новчаног потраживања, није оспорио, а при том се не ради о недопуштеним правним последицама и решавању спора који потичу из односа регулисаних императивним нормама у смислу чл. 3. ст. 3. ЗПП, то је правилном применом материјалног права, обавезао туженог на исплату траженог новчаног потраживања. Такође, при чињеници да у вишегодишњем периоду тужени није исказао намеру и вољу да исплати тражено новчано потраживање из 2005. године, дакле не само до дана подношења тужбе, већ ни до окончања главне расправе што представља неизвесност у погледу времена исплате, то Апелациони суд налази да је у смислу чл. 387., 392. ст. 2. и 324. ЗОО, правилно првостепени суд ценио основаност и доспелост траженог новчаног потраживања, дакле започињањем поступка чија је сврха да се постигне испуњење обавезе, односно даном подношења тужбе надлежном суду, а све у границама постављеног тужбеног захтева.

Из изнетих разлога, Апелациони суд налази да је на утврђено чињенично стање првостепени суд правилно применио материјално право, при том имајући у виду да се жалбом не истичу нове чињенице, нити предлаже извођење нових доказа у смислу чл. 372. ст. 1. ЗПП. У жалби тужени истиче приговор застарелости потраживања, међутим у смислу чл. 372. ст. 2. ЗПП, изнети наводи не могу бити основани, нити утицати на доношење другачије одлуке у овој правној ствари, обзиром да тужени у току поступка пред првостепеним судом није истакао материјалноправни приговор. Стога, из изнетих разлога сходно чл. 390. ЗПП, одлучено ако у изреци ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 1825/13 од 18.07.2013. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАДУ

Суд опште надлежности апсолутно је ненадлежан за оцену законитости решења о разрешењу катихете односно одузимања архијејског благослова за вршење дужности наставника верске наставе - православног катихизиса (веронауке) код школских установа која доноси старешина епархије Српске православне цркве, јер су за то надлежни органи цркве.

Надлежан је за оцену законитости одлука школских установа о престанку радног односа – отказ уговора о раду наставнику верске наставе који је разрешен катихете са аспекта постојања разлога за отказ уговора прописаних Законом о раду.

Из образложења:

Тужена СПЦ је у току поступка указивала на ненадлежност судова опште надлежности за решавање о захтеву тужбе за поништај решења тужене СПЦ Е. бр. службени 99 од 10.04.2010. године, будући да се ради о одлуци органа цркве, а црква и њени органи јесу независни од државе, што произилази из одредби Устава РС, Закона о црквама и верским заједницама и Устава СПЦ, где је прокламована независност цркве од државе, као и слобода мисли, савести и вероисповести, те да су у том смислу цркве и верске заједнице равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, оснивају верске школе, социјалне и добротворне установе и да њима управљају у складу са Законом о црквама и верским заједницама да родитељи и законски стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уверењима. Истицане су и околности да је тужени орган, тужене СПЦ, искључиво надлежан да именује и разрешава катихете, да у складу са уставом СПЦ искључиво је надлежан да даје и одузима благослов, односно одлучује која су лица погодна да обављају дужност наставника верске наставе, као и да врши надзор над њиховим радом и да је уставом СПЦ прописана надлежност епархије да се стара о предавању веронауке у својој епархији, да су решења епископије па и решење о именовању и разрешењу катихете интерна црквена акта, која се доносе на основу унутрашњих канонских и црквених правила чију законитост могу оцењивати црквени органи, у конкретном случају цркве-

ни суд епархије Рашко-Призренске и Косовско-Метохијске, односно архијерејски Синод.

Ради правилног расправљања чињеница које јесу битне за правилно одлучивање о тужби, релевантно материјално право представљају одредбе садржане у Уставу Републике Србије, одредбе Закона о црквама и верским заједницама, Устава СПЦ и Закона о основама система образовања и васпитања, који су примењивани у време доношења оспорених одлука.

Према одредбама из чл.11. ст. 2. Устава, цркве и верске заједнице су одвојене од државе. Цркве и верске заједнице су равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, да јавно врше верске обреде, да оснивају верске школе, социјалне и добротворне установе и да њима управљају, у складу са законом.

Одредбама из чл. 6. чл. 7. ст. 1. и чл. 8. ст. 1. и 2., Закона о црквама и верским заједницама прописано је да су цркве и верске заједнице независне од државе и једнаке пред законом, да су слободне и аутономне у одређивању свог верског идентитета и да имају право да самостално уређују и спроводе свој поредак и организацију и да самостално обављају своје унутрашње и јавне послове. Држава не може ометати примену аутономних прописа цркве и верских заједница. За извршење правноснажних одлука и пресуда које издају надлежни органи цркава и верских заједница држава пружа одговарајућу помоћ, на њихов захтев, у складу са законом. Свештенике, односно верске службенике бирају и постављају цркве и верске заједнице, у складу са својим аутономним прописима. Вршење свештеничке, односно верске службе регулише се аутономним прописима цркава и верских заједница.

У смислу одредби из чл. 1. ст. 1. и чл. 5., чл.10. Устава СПЦ, та православна црква своје верско учење јавно исповеда, своје богослужење јавно врши и самостално управља и уређује црквено верске послове. У СПЦ правна су лица патријаршија, епархије, црквене општине, манастири, задужбине, самосталне установе или такви фондови и према црквеној намени, поједини храмови. У СПЦ црквено јерархијске и самоуправне власти, тела и органи јесу Патријарх, Свети Архијерејски сабор и Свети архијерејски синод, Велики црквени суд, Патријаршијски савет, Патријаршијски управни одбор, епархијски Архијереј, Епархијски црквени суд,

Епархијски савет, Епархијски управни одбор, архијерејски намесник, парох Црквеноопштински савет и Црквеноопштински управни одбор и настојатељ и манастирско братство. Организација и послови које обављају наведени органи и тела уређени су одредбама из чл. 70 до чл. 140.

Раније важећим Законом о основама система образовања и васпитања, у чл. 122. ст. 2. 3. и 4. прописано је да листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских заједница, утврђује министар. Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква и верска заједница са утврђене листе за сваку школску годину. За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину. Важећи Закон о основама система образовања и васпитања садржи истоветне одредбе у чл. 132. Одредбе наведених законских прописа не прописују као разлог за престанак радног односа запосленима, односно за отказ уговора о раду случај који је предмет овог спора. У смислу одредби тих законских прописа радни однос запосленог престаје у складу са законом, на основу решења директора и да наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године у којој навршава 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања и у случају изрицања мере престанка радног односа због теже повреде радних обавеза прописаних законом.

Имајући у виду цитирано материјално право, правилно је поступање првостепеног суда кад је избегао оцену законитости решења о разрешењу катихете Е. бр. службени 99 од 10.04.2010. године, односно о одузимању архијерејског благослова за вршење дужности наставника верске наставе-православног катихизиса (веронауке) код тужене због кога је тужена основна школа морала донети оспорену одлуку о престанку радног односа тужиоцу бр. 72 од 14.04.2010. године, јер судови опште надлежности, односно редовни судови у Републици Србији нису надлежни за оцену законитости и правилности одлука које доносе органи СПЦ у складу са Уставом те верске заједнице, односно са Законом о црквама и верским заједницама или другим актима цркве, него да су за то надлежни црквени органи, на које је указивала тужена СПЦ.

С тим у вези правилно је применио одредбе из чл. 16. ст. 1 и 2. ЗПП, када се ставом првим изреке своје одлуке огласио ненадлежним за поступање о захтеву тужбе за поништај решења о разрешењу катихете,

одбацио тај део тужбе и укинуо све спроведене радње у ранијем току поступка.

Кад се ради о одлуци садржаној у ставу другом изреке, а односи се на поништај решења тужене основне школе о отказа уговора о раду тужиоцу насупрот наводима жалбе, правилно је примењено материјално право када је том одлуком усвојен тужбени захтев и оспорено решење о престанку радног односа тужиоцу поништен.

Утврђене чињенице о томе да је тужена СПЦ – Епархија Рашко-Призренска и Косовско – Метохијска, најпре тужиоцу додељен архијерејски благослов за вршење дужности наставника верске наставе – православног катихизиса (веронауке) у туженој ОШ у току школске 2009/10 године решењем о именовању катихете бр. 622 од 10.08.2009. године, да је на основу тог решења тужена установа са тужиоцем закључила уговор о раду ради обављања послова наставника верске наставе под бр. 167 од 08.09.2009. године на одређено време од 01.09.2009. године до 31.08.2010. године, да је пре истека тог рока решењем тужене СПЦ – Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска сл. бр. 99 од 10. априла 2010. године, тужиоцу одузет архијерејски благослов за вршење дужности наставника верске наставе - православног катихизиса (веронауке) код тужене школе, да је након тога оспореним решењем тужене школе утврђен престанак радног односа из разлога што је тужилац разрешен катихете на основу наведеног решења, оправдавају оцену првостепеног суда о неоснованости захтева тужбе да се то решење поништи.

Уговор о раду између тужиоца и тужене школе закључен је у складу са правилима Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 62/2003 до 101/2005) и у складу са одредбама Закона о раду.

Будући да одредбама наведених Закона о основама система образовања и васпитања није предвиђен разлог за отказ уговора о раду, односно за престанак радног односа запосленима у основним и средњим школама, кад се ради о наставницима верске наставе, у случају одузимања катихете, односно благослова за вршење дужности наставника верске наставе – православног катихизиста (веронауке), оцена законитости и правилности оспореног решења о престанку радног односа тужиоцу има се извршити у складу са правилима Закона о раду. По оцени овог суда, тужиоцу

је престао радни однос из наведеног разлога по самом закону, јер се тај разлог може уподобити са разлогом из чл. 176. Закона о раду, којим је у ст. 1. тач. 2. прописано да запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца, ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може му се обезбедити обављање других послова – даном достављања правноснажне одлуке. Овде се има сматрати да решење црквених власти о разрешењу катихете Е. бр. службени бр. 99 од априла 2010. године, јесте коначно јер је тужилац пропустио да тражи оцену његове законитости и правилности у поступку пред надлежним органима Српске Православне Цркве, а оно има правну снагу одлуке којом се забрањује, односно ускраћује обављање посла за који је закључен уговор о раду између њега и тужене школске установе, односно за обављање послова наставника верске наставе.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 7Гж1. 3348/14 од 01.10.2014 године).

Аутор сентенце: Зоран Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу

О НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У СПОРОВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЕЗИВАЊЕ ПОСЛОДАВЦА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ИЗ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

1. Не постоје правне сметње, са аспекта правилне примене правила Закона о парничном поступку и материјалног права да суд опште надлежности одлучује о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање запослених надлежним корисницима тих јавних прихода.

2. О наведеном захтеву стварно је надлежан да одлучује Основни суд.

Из образложења:

Оспорено решење, као првостепени суд, донео је Виши суд примењивши правни став Врховног Касационог суда од 23.03.2010. године о томе да кад се тужбени захтев односи на исплату зараде, накнаде зараде и других примања из радног односа и накнаде штете због изгубљене зараде уз обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања надлежан је Основни суд у првом степену на основу чл. 22. ст. 3. Закона о уређењу судова у вези чл. 105. ст. 2. и чл. 191. ст. 2. Закона о раду. Међутим, одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања не спада у надлежност суда опште надлежности јер се не ради о спору из чл. 1. Закона о парничном поступку.

Насупрот закључку Врховног Касационог суда у коме је заузет цитирани правни став, према правном ставу израженом у одлуци Уставног суда бр. Уж-3506/2012 од 22.03.2013. године, не постоје правне сметње да суд опште надлежности одлучује и о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања.

У наведеној одлуци Уставног суда је изражено правно схватање када се ради о надлежности судова опште надлежности за расправљање о предмету ове тужбе, да није прихватљиво одбијање редовних судова да поступају у споровима о правима из радног односа. Таквом праксом сужава се право на приступ суду као једно од гаранција права на правично суђење из чл. 32. ст. 1. Устава. По начелу "ко може више, може и мање", надлежност за поступање по тужбама за исплату зарада, односно накнада зарада, утолико више обавезује суд да поступа и по тужбама које имају за предмет само обавезу уплате доприноса за обавезно социјално осигурање. Томе у прилог иде и став Уставног суда из ранијих одлука да се права из радног односа, у који корпус улази и право на исплату зараде и уплату доприноса у корист запосленог, као и права на приступ суду, као једног од елемената права на правично суђење, запослени не може одрећи чак ни у случају потписивања споразума са послодавцем којим се одриче потраживања из радног односа, самим тим и права на судску заштиту ових права.

Из изнетих разлога, жалба је оцењена као основана, имајући у виду да се њоме указује на постојање наведене битне повреде поступка.

Зато ће првостепени суд наставити са поступањем по тужби, уколико сматра да је стварно надлежан за поступање у овој парници.

На основу чл. 401. тач. 3. Закона о парничном поступку, решено је као у изреци.

(Из решења Апелационог суда у Нишу 7Гж1. 3439/14 од 15.10.2014 године; из одлуке Уставног суда Уж-3506/2012 од 22.03.2013 године.)

Аутор сентенце: Зоран Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВНИ ОСНОВ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

Суд није везан за правни основ који је означен у тужби, па стога, уколико је тужилац у тужби навео да тражи исплату зараде због незаконитог престанка радног односа, суд није везан за овако постављен захтев јер тужилац има право на накнаду штете због незаконите одлуке о престанку радног односа у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, у смислу чл. 191. Закона о раду, па ће стога суд да цени основаност захтева за накнаду штете и да о томе одлучује.

Образложење

Према чл. 191. ст. 2. Закону о раду послодавац је дужан да запосленом, поред враћања на рад, уколико суд донесе правноснажном одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос, накнади штету у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору о раду и уплати доприносе за обавезно социјално осигурање. Стога, иако је тужилац тужбом тражио исплату зараде за период када је био ван радног односа због незаконите одлуке о престанку радног односа, суд ће одлучивати о захтеву за накнаду штете због незаконите одлуке о престанку радног односа у смислу чл. 191. Закона о раду јер на основу чл. 187. ст. 4. ЗПП ("Сл. гл. РС" бр. 125/04... 43/13), односно чл. 192. ст. 4. ЗПП ("Сл. гл. РС" бр. 72/11... 55/14), суд није везан за правни основ који је означен у тужби.

(Извод из одлуке Апелационог суда у Нишу 20Гж1. бр. 195/12 од 22.03.2012. године која је донета поводом изјављене жалбе против пресуде Основног суда у Нишу – Судска јединица у Алексинцу I 26 П1. 1568/11 од 31.10.2011. године)

Судија Слађана Стојановић,
Апелациони суд у Нишу

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ 18 ЗАРАДА УМЕСТО ВРАЋАЊА НА РАД

Запослени нема право на накнаду штете у износу до 18 зарада када је о његовом захтеву да се врати на рад, због доношења незаконите одлуке о престанку радног односа, правноснажно одлучено.

Образложење

У поступку пред судом запослени је тражио између осталог да се утврди да му је незаконито престао радни однос као и да се послодавац обавезе да тужиоца врати на рад, и са таквим захтевом је успео у спору, а одлука о враћању на рад постала је правноснажна. У истом поступку тужилац је тражио и обавезивање туженика на исплату зараде од момента престанка радног односа, па надаље, и поступак је настављен по том захтеву јер исти у том делу није правноснажно окончан. Након тога, у току тог поступка, тужилац је поднео и захтев да се туженик обавезе да тужиоцу, уместо враћања на рад, исплати 18 зарада. Овакав захтев тужиоца одбијен је као неоснован.

Наиме, одредбом чл. 191. ст. 4. Закона о раду предвиђено да суд може на захтев запосленог да обавезе послодавца да запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 зарада које би запослени остварио да ради, и то у зависности од временаведеног у радном односу и година запосленог, као и број издржаваних чланова породице, и то у случају ако утврди да је запосленом незаконито престао радни однос а запослени не захтева да се врати на рад. Ставом 6. истог члана предвиђено је да запослени овакав захтев може да постави до окончања главне расправе пред судом.

У конкретном случају тужилац је захтевао да се врати на рад и о том захтеву тужиоца правноснажно је одлучено. Осим тога захтев за исплату 18 зарада тужилац је поставио након окончања главне расправе пред судом, односно након што је правноснажно одлучено о захтеву за враћање на рад.

Имајући у виду напред изложено тужбени захтев тужиоца у том делу одбијен је као неоснован уз образложење да је тужилац овакав захтев могао да постави до закључења главне расправе у поступку када је одлучивано о захтеву за враћање на рад. Након тога, па и у случају када је правноснажно одлучено о његовом захтеву за враћање на рад, тужилац не може тражити исплату штете у износу до 18 зарада уместо враћања на рад, а сходно чл. 191. ст. 6. Закона о раду, па је тужбени захтев тужиоца из изнетих разлога, у том делу одбијен као неоснован.

(Извод из одлуке Апелационог суда у Нишу 20Гж1. бр. 195/12 од 22.03.2012. године која је донета поводом изјављене жалбе против пресуде Основног суда у Нишу – Судска јединица у Алексинцу I 26 П1. 1568/11 од 31.10.2011. године.)

Судија Слађана Стојановић,
Апелациони суд у Нишу

